

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Autor:

Priscilla Ramineli Leite



Organizado por CP Iuris

ISBN 978-85-5805-017-3

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1ª edição

Brasília

**CP Iuris
2020**

PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA. Promotora de Justiça aprovada em 2º lugar no XLVIII Concurso do MPRS. Ex-Juíza Substituta do Tribunal de Justiça de São Paulo, aprovada no 187º concurso. Graduada em Direito pela USP e Pós-graduada em Direito Público. Ex-Presidente da Comissão de Direito Processual Penal da Associação Brasileira de Advogados - Sede Porto Alegre/RS. Foi também advogada e tenente da Força Aérea Brasileira.

Capítulo 1 – Introdução ao Direito da Criança e do Adolescente	10
1. O Direito da Criança e do Adolescente.....	10
2. Evolução Histórica	10
2.1. Fase da Absoluta Indiferença.....	10
2.2. Fase da Mera Imputação Criminal ou do Direito Penal Indiferenciado ou do Direito Penal do Menor	11
2.3. Fase Tutelar (fase da Doutrina da Situação Irregular)	11
2.4. Fase da Doutrina da Proteção Integral	12
3. Conceito de Criança e Adolescente.....	14
4. Jurisprudência	14
Questões	15
Gabarito	17
Capítulo 2 – Direitos Fundamentais: Parte 1	18
1. Direito à vida e à saúde.....	18
2. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.....	21
2.1 Direito à liberdade	21
2.2 Direito ao respeito	23
2.3 Direito à dignidade.....	24
2.3.1 Direito à educação sem castigo físico, sem tratamento cruel ou degradante	24
3. Jurisprudência	25
Questões	27
Gabarito	29
Capítulo 3 – Direitos Fundamentais: Parte 2	31
1. Direito à convivência familiar.....	31
1.1. Noções introdutórias sobre a convivência familiar	31
1.2. Entrega de recém-nascido para adoção.....	32
1.3. Programa de Apadrinhamento	33
2. Poder Familiar	33
2.1. Processo judicial e contraditório para perda ou suspensão do poder familiar.....	35
3. Reconhecimento de filho e estado de filiação	36
4. Família Substituta.....	37
4.1. Guarda	38
4.2. Tutela	39
4.3. Adoção	40

4.3.1. Aspectos gerais da adoção	40
4.3.2. Espécies de adoção	40
4.3.3. Quem pode adotar e ser adotado	42
4.3.4. Requisitos para adoção	42
4.3.5. Adoção internacional	43
4.3.6. Efeitos da adoção	45
5. Jurisprudência	46
Questões	49
Gabarito	51
Capítulo 4 – Direitos Fundamentais: Parte 3	52
1. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer	52
2. Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho	54
3. Jurisprudência	54
Questões	57
Gabarito	58
Capítulo 5 – Da Prevenção	59
1. Noções Preliminares sobre Prevenção	59
2. Prevenção Especial referente à informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos (art. 74 a 80)	60
3. Prevenção à venda de produtos e serviços	61
4. Autorização para viajar	61
5. Jurisprudência	62
Questões	64
Gabarito	65
Capítulo 6 — Política de Atendimento e Entidades de Atendimento	66
1. Noções Preliminares	66
2. Entidades de atendimento	66
2.1. Entidades de acolhimento institucional ou familiar	67
2.2. Entidades voltadas à internação	68
2.3. Fiscalização das entidades	69
3. Jurisprudência	70
Questões	70
Gabarito	71
Capítulo 7 — Medidas de Proteção	72
1. Conceito e Princípio	72

2. Acolhimento.....	73
3. Medidas pertinentes aos pais e responsáveis	74
4. Jurisprudência	75
Questões	77
Gabarito	78
Capítulo 8 – O Ato Infracional.....	79
1. Noções introdutórias sobre o Ato Infracional	79
2. Direitos individuais do adolescente suspeito de cometer ato infracional	79
3. Garantias processuais	80
4. Medidas Socioeducativas.....	80
4.1. Medidas socioeducativas em espécie.....	82
4.1.1 Advertência.....	82
4.1.2. Obrigação de reparar o dano	83
4.1.3. Prestação de serviços à comunidade	83
4.1.4. Liberdade assistida	83
4.1.5. Semiliberdade	83
4.1.6 Internação.....	84
5. Remissão.....	86
6. Jurisprudência	87
Questões	91
Gabarito	93
Capítulo 9 – Conselho Tutelar.....	94
Questões	95
Gabarito	97
Capítulo 10 — A Justiça da Infância e da Juventude e seus Procedimentos	98
1. Disposições gerais	98
2. Competência da Justiça da Infância e da Juventude	98
3. Procedimentos	100
3.1. Noções Preliminares	100
3.2. Perda ou suspensão do poder familiar e destituição de tutela	101
3.3. Colocação em família substituta	102
3.4. Habilitação dos pretendentes à adoção	103
3.5. Apuração de irregularidades em entidade de atendimento	105
3.6. Infiltração de Policiais para Investigar Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente	105

3.7. Apuração de ato infracional	106
3.7.1. Apreensão e encaminhamento	106
3.7.2 Formação da convicção do Ministério Público	107
4. Jurisprudência	109
Questões	110
Gabarito	112
Capítulo 11 – Recursos no ECA.....	114
1. Jurisprudência	115
Questões	117
Gabarito	118
Capítulo 12 — Ministério Público, Advocacia e Tutela de Direitos.....	119
1. Ministério Público	119
2. Advocacia.....	120
3. Tutela de direitos individuais, difusos e coletivos	121
3.1 Legitimidade	122
3.2. Competência.....	123
3.3. Especificidades na tutela coletiva	123
4. Jurisprudência	124
Questões	126
Gabarito	127
Capítulo 13 – Crimes e Infrações Administrativas	129
1. Introdução	129
2. Crimes em espécie.....	129
2.1. Art. 228	129
2.2. Art. 229	129
2.3. Art. 230	130
2.4. Art. 231	130
2.5. Art. 232	130
2.6. Art. 234	131
2.7. Art. 235	131
2.8. Art. 236	131
2.9. Art. 237	131
2.10. Art. 238.....	132
2.11. Art. 239.....	132
2.12. Art. 240.....	132

2.13. Art. 241.....	133
2.14. Art. 241-A	134
2.15. Art. 241-B	134
2.16. Art. 241-C.....	135
2.17. Art. 241-D	136
2.18. Norma penal explicativa	136
2.19. Art. 242.....	137
2.20. Art. 243.....	137
2.21. Art. 244.....	137
2.22. Art. 244-A	137
3. Infrações administrativas.....	139
3.1. Art. 245	139
3.2. Art. 246	139
3.3. Art. 247	139
3.4. Art. 249	140
3.5. Art. 250	140
3.6. Art. 251	140
3.7. Art. 252	140
3.8. Art. 253	141
3.9. Art. 254	141
3.10. Art. 255.....	141
3.11. Art. 256.....	141
3.12. Art. 257.....	141
3.13. Art. 258.....	142
3.14. Art. 258-A	142
3.15. Art. 258-B	142
3.16. Art. 258-C.....	142
4. Jurisprudência	143
Questões	147
Gabarito	148
Capítulo 14 — Disposições Finais e Transitórias	149
Capítulo 15 — Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo	153
1. Conceito de SINASE	153
2. Objetivos das medidas socioeducativas.....	153
3. Conceitos básicos da Lei nº 12.594/12 (art. 1º, §§3º a 5º)	153

4. Repartição de competências	154
4.1. União.....	154
4.2. Estados	154
4.3. Municípios	155
5. Plano de Atendimento Socioeducativo	156
6. Programas de Atendimento	156
6.1. Dos programas de meio aberto.....	157
6.2. Dos programas em meio fechado	158
7. Financiamento.....	158
8. Execução das medidas socioeducativas	159
8.1 Procedimentos.....	160
8.2. Plano Individual de Atendimento	161
8.3. Reavaliação e substituição da medida socioeducativa ou Plano Individual de Atendimento (PIA).....	162
8.4. Direito de visita a adolescente em unidade de internação	163
8.5. Extinção de medida socioeducativa	163
8.6. Revisão judicial	164
8.7. Regimes Disciplinares.....	164
9. Jurisprudência	164
Questões	167
Gabarito	168
Súmulas sobre Direito da Infância e Juventude	169

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1. O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Sergio Cavalieri Filho¹ ensina que o século XIX ficou conhecido como “século das grandes codificações”, em alusão ao Código Civil Alemão (BGB) e ao Código Napoleônico, ao passo que o século XX pode ser considerado o “século dos novos direitos”, vide o desenvolvimento do direito do consumidor, direito ambiental, direito das comunicações e biodireito. O direito da criança e do adolescente (antigo direito do menor) também pode ser considerado um “novo direito”, já que sua emergência e desenvolvimento se deram substancialmente ao longo do século XX.

Pode-se conceituar o direito da criança e do adolescente, do ponto de vista formal, como:

o conjunto de princípios e de leis que se direcionam a disciplinar os direitos e obrigações das crianças e dos adolescentes sob o prisma da proteção integral e do melhor interesse”². Já do ponto de vista material, considera-se que o direito da criança e do adolescente “é um dos meios do Estado e da Sociedade de efetivação das políticas voltadas à proteção de seus direitos fundamentais mencionados no ECA”³.

Trata-se de ramo autônomo do direito, ante a existência de legislação específica sobre a matéria, bem como diante de sua constitucionalização. Está inserido no âmbito do direito público.

No que tange à competência legislativa, tem-se uma competência concorrente, ou seja, a União trata de normas gerais e os Estados, DF e Municípios tratam de normas específicas.

O direito da criança e do adolescente também é chamado de “direito da infância e da juventude”, em alusão aos inúmeros Juizados da Infância e da Juventude existentes no âmbito do Poder Judiciário, bem como de “direito menorista”, expressão antiquada relativa à época de existência dos Códigos de Menores (1927 e 1979), quando ainda não vigia o paradigma da doutrina da proteção integral, conforme será explicitado adiante. Por esta razão, não é recomendável a utilização desta última expressão.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

É possível vislumbrar quatro momentos ou fases no que tange ao direito da infância e da juventude. São elas: 1) fase da absoluta indiferença; 2) fase da mera imputação criminal; 3) fase tutelar (também conhecida como Doutrina da Situação Irregular) e 4) fase da Doutrina da Proteção Integral.

2.1. FASE DA ABSOLUTA INDIFERENÇA

Nessa fase, não existiam normas jurídicas destinadas a tratar dos direitos e deveres de crianças e adolescentes, os quais não eram objeto de preocupação ou tutela pelo Estado, tampouco pela sociedade. No geral, cabia ao pai reger de forma absoluta a vida dos filhos.

Na idade antiga, p. ex., o pai em uma família romana possuía poder absoluto sobre seus descendentes, e decidia, inclusive, sobre a vida e a morte deles. Em algumas cidades gregas, mantinham-

¹Sergio Cavalieri Filho. *O Direito do Consumidor no limiar do século XXI: Revista de Direito do Consumidor* - vol. 35/2000. São Paulo: RT. pg.97.

²Valter Kenji Ishida. *Estatuto da criança e do adolescente – Doutrina e jurisprudência*. Salvador: JusPodium, 2019. pg. 30.

³Valter Kenji. Valter Kenji Ishida. *Estatuto da criança e do adolescente – Doutrina e jurisprudência*. Salvador: JusPodium, 2019. pg. 31



se vivos apenas os filhos fortes e saudáveis, sendo que em Esparta o genitor transferia o poder de criar os filhos ao Estado, que os transformavam em guerreiros.

Na idade média houve evolução no tratamento das crianças e adolescentes graças ao influxo da religião sobre o Estado e, por conseguinte, nas normas por ele emanadas. Assim, notou-se um abrandamento na severidade outrora vista no tratamento dos filhos. Ademais, em alguma medida, a Igreja passou a proteger os infantes ao estabelecer penas corporais e espirituais aos pais que maltratavam os filhos.

De toda sorte, ainda não havia normas jurídicas propriamente ditas destinadas à proteção das crianças e dos adolescentes.

A história mais recente traz um caso emblemático que se passou nos EUA, em 1896, envolvendo uma criança chamada Marie Anne, que sofria maus-tratos por seus pais. Uma sociedade Protetora de Animais resolveu intervir buscando decisão judicial em favor da criança, argumentando que se até os animais possuíam proteção, com maior razão deveriam ter as crianças. O fato teve grande repercussão e virou o símbolo de uma nova fase que se iniciava, porque à época ainda não havia normas protetivas às crianças, e não era comum que violações a elas chegassem à justiça.

2.2. FASE DA MERA IMPUTAÇÃO CRIMINAL OU DO DIREITO PENAL INDIFERENCIADO OU DO DIREITO PENAL DO MENOR

Nessa fase preocupa-se primordialmente com a repressão de infratores.

Abrange o período de vigência das Ordenações Filipinas (que previa a imputabilidade penal a partir dos 7 anos de idade), do Código Penal do Império de 1830 (que introduziu o exame da capacidade de discernimento para a aplicação da pena a pessoas entre 7 e 14 anos), do Código Penal de 1890, do 1º Código de Menores do Brasil de 1926 e do Código Mello Mattos de 1927, o qual consolidou a categoria “menor” e lançou as bases da Doutrina da Situação Irregular.

2.3. FASE TUTELAR (FASE DA DOCTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR)

O debate no campo internacional e nacional levou ao desenvolvimento de uma doutrina do Direito do Menor. Nesse período existiam normas sobre crianças e adolescentes, mas elas não os tratavam como sujeitos de direitos, e sim como os objetos do direito. Além disso, tinham uma incidência restritiva. Tem como expoente o Código de Menores de 1976.

A base dessa doutrina tinha relação direta com o binômio carência-delinquência, pois era justamente nessas situações em que incidiam as normas relativas aos infantes. O sistema entrava em ação diante de crianças e adolescentes que estivessem em “situação irregular”⁴, o que geralmente envolvia um desses dois contextos (carência/abandono ou delinquência).

Cabe destacar quatro importantes características dessa fase:

a) abrangência relativa e discriminatória das normas de proteção às crianças e adolescentes:

A rigor, o sistema entrava em ação preponderantemente diante de crianças e adolescentes pertencentes a famílias carentes, pois eram consideradas em situação irregular (carentes e abandonados) ou envolvidas com condutas desviantes (atos infracionais). As leis não se aplicavam a todos de forma indistinta a todos infantes.

b) possibilidade de afastar crianças e adolescentes do convívio com a família natural por dificuldade financeira dessa:

A família, independentemente da sua condição socioeconômica, tinha o dever de prover as necessidades dos jovens à luz de um ideal estabelecido pelo Estado. Se não o fizesse de acordo com os padrões esperados, o menor era considerado em situação irregular e era possível retirá-lo do convívio de sua família. O foco não era preservar a convivência familiar. Atualmente o ECA expressamente proíbe tal comportamento (art. 23).

⁴ O artigo 2º do Código de Menores de 1979 definia o que era “situação irregular” de forma vaga e imprecisa.



Vigorava a cultura da internação tanto para os menores carentes quanto para os “delinquentes”. A segregação era vista como uma das principais soluções.

Veja como isso já foi cobrado em provas:

c) amplos poderes do juiz “de menores”:

A partir do Código Mello Mattos, ficou estabelecido que caberia ao juiz definir o destino dos menores, e para tanto a ele foi conferida uma função judicial e normativa muito forte.

O aspecto referente ao poder normativo é o que mais se cobra em provas, merecendo destaque o dispositivo Código de Menores de 1979 que admitia ao juiz editar atos normativos de caráter geral⁵, o que não mais se admite.

Nesse contexto, era possível se deparar com portarias do juízo que impunham o “toque de recolher”, vedando de forma geral e abstrata a permanência de crianças e adolescentes nas ruas desacompanhadas de responsáveis após determinado horário. Atualmente ainda se tem notícias sobre portarias com esse conteúdo, porém, de acordo com o STJ, elas violam o art. 149, § 2º, do ECA, o qual veda que os atos normativos expedidos pelo juiz da infância contenham caráter geral.

d) direitos menos amplos que os dos adultos:

Crianças e adolescentes tinham menos direitos que os adultos. Argumentava-se que as medidas eram tomadas para protegê-los, e não para punir, e assim não se observavam garantias fundamentais dos jovens. Nessa esteira, em certos casos, não se seguia um processo legal para aplicar medidas aos jovens autores de “conduta desviante”, nem para aferir se estavam em “situação irregular”. Não eram vistos, em verdade, como sujeitos de direito, e sim como objeto desse.

2.4. FASE DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL

A doutrina da Proteção Integral da criança e do adolescente foi adotada pela Constituição Federal de 1988 e pelo ECA. Nessa esteira, o art. 1º do Estatuto diz expressamente que a lei trata da proteção integral da criança e do adolescente. Já o art. 227, *caput*, da Carta Magna conta com a seguinte redação, a partir da qual se infere a adoção da referida doutrina:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 mudou de paradigma, afastando-se da doutrina da situação irregular para adotar a doutrina da proteção integral.

Nesse novo paradigma, crianças e adolescentes passaram a ser tratados como verdadeiros sujeitos de direito, e não objetos de tutela, bem como a contar com um amplo conjunto de mecanismos jurídicos voltados à sua proteção. Daí

As características da Doutrina da Proteção Integral são bastante exploradas em provas de concursos públicos e cinco delas merecem destaque:

a) Generalidade de proteção do Estatuto e demais normas protetivas a todos menores de 18 anos:

Diferente do que se verificava à época da doutrina da situação irregular, agora todas as pessoas com menos de 18 anos⁶ sujeitam-se de forma isonômica às normas sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes. Vedou-se toda sorte de tratamento discriminatório, outrora bastante comum, especialmente em razão de condições econômicas dos jovens e seus familiares.

⁵ “Art. 8º A autoridade judiciária, além das medidas especiais previstas nesta Lei, poderá, através de portaria ou provimento, determinar outras de ordem geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo por abuso ou desvio de poder.”

⁶ Conforme será visto a seguir, aplica-se o ECA em alguns casos a adultos entre 18 e 21 anos.



O Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) reforçou essa ideia ao alterar o art. 3º do ECA, incluindo no parágrafo único que os direitos previstos no estatuto devem ser aplicados a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Buscou-se, assim, evitar discriminações.

b) Prioridade Absoluta:

Diz o art. 4º, parágrafo único do ECA que a garantia de prioridade compreende a i) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ii) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, iii) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, iv) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E o art. 227 da CF, visto alhures, complementa ao dizer que a esse grupo de pessoas também se deve assegurar com prioridade absoluta o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Cumpra mencionar que o Estatuto do Idoso, em seu art. 3º, também assegura absoluta prioridade nas situações acima mencionadas a pessoas de idade igual ou superior a 60 anos, o que leva alguns a refletir sobre qual prioridade deveria preponderar: a das crianças e adolescentes, ou a dos idosos.

A solução deve ser dada à luz do caso concreto. Contudo, no plano abstrato e teórico, há um argumento que pode ser utilizado em favor da prioridade dos infantes: a prioridade desse grupo de pessoas tem sede constitucional, e, portanto, hierarquicamente superior à dos idosos que é apenas legal.

c) Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento:

São assegurados todos os direitos que possuem os adultos e mais outros decorrentes da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Aqui também há nítido contraste com a doutrina da situação irregular, quando crianças e adolescentes tinham menos direitos que os adultos.

Também em razão disso, recebem tratamento especial, com procedimentos diferenciados e até mesmo uso de taxonomia própria.

Crianças e adolescentes, p. ex., não cometem crimes, e sim atos infracionais. Não se sujeitam à pena, mas sim à medida socioeducativa e/ou medida de proteção. Não respondem à ação penal, e sim a ação socioeducativa. Aliás, no âmbito infracional, inúmeros são os julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ao adolescente não pode ser conferido tratamento mais gravoso que ao adulto, em face dessa condição peculiar.

d) Busca do melhor interesse da criança e do adolescente:

Impõe-se que, na análise do caso concreto, o aplicador do direito busque a solução mais vantajosa para a criança ou adolescente, e não, p. ex., a seus pais, guardiães, tutores ou adotantes. Esse princípio se faz muito presente no estudo da colocação em família substituta e é capaz até de relativizar regra expressa do ECA, como no caso em que se admitiu a adoção de criança por seus avós, ainda que em contrariedade ao disposto no art. 42, §1º do ECA.

e) Abandono da expressão “menor”:

A expressão “menor” tornou-se pejorativa e antiquada, uma vez que remete ao Código de Menores, e consequentemente à doutrina da situação irregular, a qual se preocupava primordialmente com a carência-delinquência, e dava tratamento discriminatório aos jovens nessa situação. Daí porque, da mesma forma que se deve evitar o uso do termo “direito menorista”, não se deve referir a “menor”.



3. CONCEITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

O Art. 2º do ECA traz em seu bojo a definição legal de criança e adolescente da seguinte maneira: criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos (de 0 a 11), ao passo que adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade (de 12 a 17).

O ECA, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, passou a tratar da primeira infância, período que vai desde a concepção até o ingresso na educação formal, isto é, 72 meses de vida da criança ou primeiros 6 anos. Considerando a importância da primeira infância para o desenvolvimento do aprendizado e da iniciação social e afetiva, a referida lei, chamada de Marco Legal da Primeira Infância, houve por bem delinear políticas públicas específicas para essas crianças.

Cabe chamar a atenção também para a definição de jovem, que é aquele cuja idade compreende os 15 a 29 anos, conforme previsão no Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013).

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro 1990, por sua vez, estabelece que é criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, não fazendo a distinção com adolescente.

O ECA realiza distinção entre criança e adolescente em razão da necessidade de regulamentação de alguns institutos, como por exemplo, a medida socioeducativa, a qual apenas se aplica aos adolescentes.

Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso ocorre tanto na seara do ato infracional quanto na civil. Assim sendo, se tramita processo de adoção na Vara da Infância e da Juventude relativo a adolescente de 17 anos de idade e, ao longo do curso do processo, ele completa 18 anos, mas já estava sob guarda ou tutela dos adotantes, deverá seguir o trâmite processual nesta vara.

Do mesmo modo, tem-se que, se um adolescente completa 18 anos e está respondendo por um ato infracional cometido enquanto era adolescente, poderá sofrer aplicação de medida socioeducativa até completar 21 anos de idade. Ou seja, é possível que um adulto de 18 anos comece a cumprir uma medida de internação decorrente de ato infracional que praticou quando adolescente. A medida poderá perdurar até os 21 anos.

4. JURISPRUDÊNCIA

HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. MENOR. AÇÃO DE GUARDA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR IMPÚBERE, ÓRFÃO DE MÃE. PAI ANDARILHO. AVÓ PATERNA QUE PLEITEIA A GUARDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. EXCEPCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ILEGALIDADE. PRIMAZIA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de permitir, em situações excepcionais, a superação do óbice da Súmula 691 do STF em casos de ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 2. **O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral e prioritária do menor, torna imperativa a observância do melhor interesse da criança.** 3. Esta Corte Superior tem entendimento assente de que, salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional em detrimento do familiar. 4. Na hipótese, o paciente, com menos de dois anos de vida, órfão de mãe e com pai andarilho e usuário de drogas, está sob os cuidados de sua avó paterna desde o óbito da genitora, tendo a avó requerido a regularização da guarda via ação própria. 5. Nessa senda, **o afastamento da medida protetiva de busca e apreensão atende ao princípio do melhor interesse da criança, porquanto, neste momento, o maior benefício ao menor é mantê-lo com a sua família extensa,** notadamente a sua avó paterna, até ulterior julgamento definitivo da ação de guarda. 6. Ordem de habeas corpus concedida, com liminar confirmada, com ressalva relativa à preservação da integridade física



ou psíquica do infante, em caso de eventual alteração do quadro fático aqui considerado (STJ, HC nº 500782-ES, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araujo, DJ 07/11/2019).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR MOVIDA PELOS ASCENDENTES QUE JÁ EXERCIAM A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. SENTENÇA E ACÓRDÃO ESTADUAL PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MÃE BIOLÓGICA ADOTADA AOS OITO ANOS DE IDADE GRÁVIDA DO ADOTANDO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, § 1º, 41, CAPUT, 42, §§ 1º E 43, TODOS DA LEI N.º 8.069/90, BEM COMO DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO CENTRADA NA VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 42, § 1º, DO ECA. COMANDO QUE NÃO MERECE APLICAÇÃO POR DESCUIDAR DA REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. **PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.** ART. 6º DO ECA. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA NORMA FEITA PELO JUIZ NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes os vícios do art. 535, do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. As estruturas familiares estão em constante mutação e para se lidar com elas não bastam somente as leis. É necessário buscar subsídios em diversas áreas, levando-se em conta aspectos individuais de cada situação e os direitos de 3ª Geração. 3. Pais que adotaram uma criança de oito anos de idade, já grávida, em razão de abuso sexual sofrido e, por sua tenríssima idade de mãe, passaram a exercer a paternidade socioafetiva de fato do filho dela, nascido quando contava apenas 9 anos de idade. 4. A vedação da adoção de descendente por ascendente, prevista no art. 42, § 1º, do ECA, visou evitar que o instituto fosse indevidamente utilizado com intuítos meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscou proteger o adotando em relação a eventual “confusão mental e patrimonial” decorrente da “transformação” dos avós em pais. 5. Realidade diversa do quadro dos autos, porque os avós sempre exerceram e ainda exercem a função de pais do menor, caracterizando típica filiação socioafetiva. 6. Observância do art. 6º do ECA: na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a **condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.** 7. Recurso especial não provido (STJ, RESP nº 1448969-SC, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 21/10/2014).

Extinção de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Decisão favorável ao menor infrator. Não unânime. Complementação de julgamento. Artigo 942 do CPC/2015. **Inaplicabilidade. Procedimento mais gravoso que o adotado no processo criminal. Afronta às normas protetivas que regem o ECA.** (REsp 1694248/RJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Informativo nº 626/2018 – STJ)

A observância do cadastro de adotantes não é absoluta, podendo ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da criança. (STJ, HC 294729/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 29/08/2014)

QUESTÕES

- 1- TJMS – Juiz 2015 (Vunesp) Com relação à retrospectiva e evolução históricas do tratamento jurídico destinado à criança e ao adolescente no ordenamento pátrio, é correto afirmar que:



- a) na fase da absoluta indiferença, não havia leis voltadas aos direitos e deveres de crianças e adolescentes.
 - b) na fase da proteção integral, regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis se limitam ao reconhecimento de direitos e garantias de crianças e adolescentes, sem intersecção com o direito amplo à infância, porque direito social, amparado pelo artigo 6º da Constituição Federal.
 - c) a fase da mera imputação criminal não se insere na evolução histórica do tratamento jurídico concedido à criança e ao adolescente no ordenamento jurídico pátrio porque extraída do direito comparado.
 - d) na fase da mera imputação criminal, regida pelas Ordenações Afonsinas e Filipinas, pelo Código Criminal do Império, de 1830, e pelo Código Penal, de 1890, as leis se limitavam à responsabilização criminal de maiores de 16 (dezesesseis) anos por prática de ato equiparado a crime.
 - e) na fase tutelar, regida pelo Código Mello Mattos, de 1927, e Código de Menores, de 1979, as leis se limitavam à colocação de crianças e adolescentes, em situação de risco, em família substituta, pelo instituto da tutela.
- 2- MPSP – Promotor de Justiça (Vunesp 2017)** Nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.069/90, “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei...”. A partir de tal postulado, é correto afirmar que o dispositivo em comento instituiu o princípio da proteção integral, cujo conteúdo nuclear significa que as crianças e os adolescentes
- a) possuem direitos específicos, assegurados pelo ordenamento infraconstitucional, os quais em boa medida importam em prestações positivas atribuídas às pessoas legalmente incumbidas de defendê-los.
 - b) têm consagrado o princípio da prioridade absoluta, trazido pela Constituição Federal, concorrendo, em termos prioritários, tão somente com os idosos e com as pessoas com deficiência.
 - c) titularizam direitos peculiares, advindos de Tratados e Convenções Internacionais recepcionados pelo ordenamento jurídico interno.
 - d) titularizam direitos específicos, assegurados pelo ordenamento infraconstitucional, os quais integram o vetor da Dignidade da Pessoa Humana, motivo por que não podem ser objeto de retrocesso.
 - e) são titulares de direitos fundamentais específicos, como os direitos à convivência familiar e à inimizabilidade penal.
- 3- MPRO – Promotor de Justiça (FMP 2017)** A legislação brasileira, no que se refere ao tratamento dispensado à criança e ao adolescente, passou por diferentes períodos, marcados, cada um, por concepções distintas. A partir disso, é CORRETO afirmar:
- a) No período que antecedeu a Constituição Federal de 1988, a legislação garantia à criança e ao adolescente direitos fundamentais, embasados no princípio do melhor interesse.
 - b) Com a vigência da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, todos aqueles que não atingiram os dezoito anos passam a ser considerados sujeitos de direitos, prioridade absoluta e pessoas em fase especial de desenvolvimento.
 - c) A doutrina da situação irregular vigorou até a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente.
 - d) A partir do Código Penal de 1890, a idade da responsabilidade penal vem fixada em dezoito anos.



- e) A Declaração dos Direitos da Criança é o primeiro documento internacional com força cogente para os países firmatários.

4- DPE-GO – Defensor Público (CS-UFG 2014) Um conjunto articulado de ações por parte do Estado e da sociedade, desde a concepção de políticas públicas até a realização de programas locais de atendimento implementados por entidades governamentais e não governamentais, é corolário dos princípios estabelecidos no texto da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto,

- a) a criança e o adolescente são objetos do direito e alvos da doutrina jurídica de proteção do menor em situação irregular, nos casos de abandono, prática de infração penal, desvio de conduta, falta de assistência, entre outros.
- b) a doutrina da proteção integral originada através da Convenção dos Direitos da Criança aprovada pela ONU, ratificada no Brasil pela Lei Federal n. 728, de 14 de setembro de 1990, reafirma-se na doutrina do menor em situação irregular.
- c) a Lei n. 8.069/1990 é instrumento de controle social da infância e do adolescente, vítimas de omissões da família, da sociedade e do Estado em seus direitos básicos, dirigindo-se primariamente ao conflito instalado.
- d) a lei abrange uma gama variada de disciplinas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente, com a responsabilidade solidariamente distribuída entre a família, a sociedade e o Estado.
- e) a proteção dos direitos da criança e do adolescente é do Estado, que assume primariamente a responsabilidade, tendo como princípio a adoção do menor em situação irregular.

GABARITO

- 1. A
- 2. A
- 3. B
- 4. D



CAPÍTULO 2 – DIREITOS FUNDAMENTAIS: PARTE 1

Sob o prisma da doutrina da proteção integral, crianças e adolescentes passaram a ser vistos como verdadeiros sujeitos de direitos e, por tal razão, o ECA trouxe explícita previsão no sentido de que os infantes gozam de todos os direitos fundamentais assegurados à pessoa adulta. Fala-se, portanto, no direito dos infantes ao gozo de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Para deixar isso claro, o Estatuto preocupou-se em positivizar de forma expressa os direitos inerentes aos adultos. Nada obstante, o legislador foi além.

Em face da condição especial de pessoa em desenvolvimento, para além dos direitos inerentes aos adultos, há um rol de direitos fundamentais previstos no ECA cuja titularidade é específica às crianças e aos adolescente.

São direitos fundamentais encontrados no ECA, elencados em capítulos específicos: I)Direito à vida e à saúde, II) Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, III) Direito à convivência familiar e comunitária,IV) Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer e V)Direito à profissionalização e à proteção ao trabalho.

1. DIREITO À VIDA E À SAÚDE

O direito à vida, de que é titular todo ser humano e, evidentemente, também os infantes, nos permite a existência, nos anima e nos conserva entre a concepção e a morte encefálica, quando ocorre com a cessação irreversível das funções do tronco cerebral⁷ e se considera, do ponto de vista médico e também jurídico, encerrada a vida humana. É mola propulsora das funções do indivíduo nos seus mais variados aspectos⁸.

Ensina CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA⁹ que tal direito possui conteúdo amplo, contendo inúmeras dimensões, compreendendo a proteção à integridade física e ao corpo, bem como à integridade psíquica, sendo vedados a tortura, os maus-tratos, as penas degradantes, hediondas e assemelhadas. Também, o direito à vida inclui a proteção à privacidade e à intimidade; à honra e à imagem, dentre outros.

Ocorre que a mera existência e a possibilidade de desenvolvimento limitado do indivíduo não bastam. Após os horrores do nazismo verificados durante a 2ª Guerra Mundial, percebeu-se que, muito além de se preservar o existir (ou mesmo o subsistir), é necessário preservar a existência digna, ou seja, a existência com qualidade de vida.

Assim, vem à tona na segunda metade do século XX o princípio da dignidade da pessoa humana como valor supremo e fundamental dos ordenamentos jurídicos que, com a reconstrução dos sistemas democráticos, expande ainda mais o conteúdo do direito à vida para o direito à vida digna.

O direito de viver dignamente, então, completa o direito à vida, tornando a vida um

processo de aperfeiçoamento contínuo e de garantias de estabilidade pessoal, compreendendo, além daqueles acima mencionados, o direito à saúde, à educação, à cultura, ao meio ambiente equilibrado, aos bens comuns da humanidade, enfim, o direito de ser em dignidades e liberdades.

Para os infantes, viver dignamente compreende, dentre outros aspectos, o acesso ao lazer e a brincar, bem como a convivência familiar.

⁷ Luciana Batista Esteves. “(In)disponibilidade da vida?”. *Revista de direito privado*. São Paulo, vol. 24, out., 2005. p. 90.

⁸ Fernando de Almeida Pedroso. *Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto*. 1º ed..Rio de Janeiro: Aide, 1995. p. 25.

⁹ Cármem Lúcia Antunes Rocha, op cit. p. 14-15.



O direito à saúde, reflexo da vida, consiste na preservação da integridade físico-corpóreo e mental da pessoa humana, mediante a prevenção e proteção contra doenças e seu tratamento, quando necessário for.

Diz o legislador que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (art. 7º).

Aqui, direito à vida não se confunde com o direito de sobreviver. Implica, em verdade, o reconhecimento do direito à vida digna. E para assegurar a vida digna, há necessariamente de se reconhecer o direito à saúde. Assim, não basta garantir o direito à vida, é necessário garantir o direito à vida com saúde.

Visando atingir esse fim, o legislador, preocupado que está com o devido planejamento familiar e com a existência de uma gestação saudável para o nascimento de crianças saudáveis, houve por bem criar direitos às mulheres em geral, às gestantes e às mães de crianças. Em alguma medida, disciplinaram-se direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, justamente com o objetivo de fazer com que as crianças nasçam e se desenvolvam com saúde.

A esse respeito, merecem destaque os seguintes direitos:

- As mulheres em geral passaram a ter direito ao acesso a programas e políticas de saúde específicos da mulher e de planejamento reprodutivo;
- Às gestantes deve ser assegurada a nutrição adequada e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério;
- Os locais onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável¹⁰ e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a grupos de apoio à amamentação;
- As gestantes têm direito de escolher o estabelecimento em que o parto será realizado e de serem a ele vinculado nos três últimos meses de gestação. Trata-se de medida que visa dar atenção humanizada à gravidez e ao parto, viabilizando que a mulher se familiarize com a equipe médica que o irá realizar, bem como o local em que ele se dará;
- Às gestantes e às mães de recém-nascidos é assegurada a assistência psicológica até no pós-natal como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, inclusive às mulheres privadas de liberdade¹¹ e às mães que desejam entregar seus filhos à adoção;
- As gestantes têm o direito de serem acompanhadas em todas as etapas por uma pessoa de sua preferência (direito a um acompanhante);
- Criou-se, por fim, o dever de buscar-se ativamente a gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.

Veja-se, ainda, que o tratamento pré-natal e perinatal se constituem em verdadeiros direito do nascituro. Por isso, em caso de omissão da gestante, é possível, segundo parte da jurisprudência, ajuizar ação de obrigação de fazer contra a gestante, com a finalidade de que esta realize todo o tratamento pré-natal.

¹⁰ O conceito de alta hospitalar responsável consta do art. 16 da PORTARIA Nº 3.390/2013 do Ministério da Saúde, o qual tem o seguinte teor:

A alta hospitalar responsável: é a transferência do cuidado, realizada por meio de:
I - orientação dos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento, reforçando a autonomia do sujeito, proporcionando o autocuidado;
II - articulação da continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, em particular a Atenção Básica; e
III- implantação de mecanismos de desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares pactuados na RAS.

¹¹ No que tange à mulher gestante presa, cabe lembrar que é vedado o uso de algema durante o parto, conforme disposto no art. 292, parágrafo único do Código de Processo Penal.



Além de direitos às mulheres, o legislador também criou diversos deveres ao poder público, às instituições e empregadores privados, bem como aos hospitais, igualmente visando assegurar o direito de crianças e adolescentes terem uma vida com saúde.

Assim, o ECA passou a exigir de forma expressa, por exemplo, que o poder público, as instituições e os empregadores propiciem condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade (art. 9º), o que pode ser rotulado de direito de amamentar. Cabe destacar, porém, que se trata mais de mais um direito do recém-nascido do que da gestante, uma vez que se visa primordialmente à saúde daquele.

Nessa linha, vale lembrar que o constituinte originário também teve essa preocupação com os recém-nascidos cujas mães sejam presidiárias, pois, no art. 5º, inc. L, da CF, estabeleceu que devem ser asseguradas condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.

Frise-se, ainda, que a Lei do SINASE (Lei 12.594), no § 2º do art. 63, trouxe previsão semelhante para proteger os filhos das adolescentes submetidas à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade, com fulcro de assegurar condições para que ela permaneça com o seu filho durante o período de amamentação. Nada obstante o oferecimento de apoio à gestante e mãe adolescente, o ECA deixa clara a necessidade de prevenir a gravidez de menores de idade, instituindo a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência (art. 8º-A).

Quanto aos hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam públicos ou particulares, merecem destaque as seguintes obrigações, dispostas no art. 10 do ECA:

- Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
- Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Essa previsão tem a finalidade de evitar eventual troca de bebês nos hospitais.
- Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Dessa disposição legal decorre a obrigatoriedade do “teste do pezinho”, realizado por meio de punção no calcanhar do recém-nascido, visando detectar a existência da fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.

A incorreta identificação do neonato e da parturiente, bem como não realização do “teste do pezinho” configuram crime, vide art. 229 do ECA.

- Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. A declaração de nascimento é o documento base (chamado de “declaração de nascido vivo”) para a lavratura do assento de nascimento junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.
- Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
- Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente.

Após tratar desses direitos inerentes à proteção da saúde da gestante e do neonato, o legislador, no art. 11 do ECA, trata do acesso à saúde de crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isso inclui a obrigatoriedade no fornecimento de medicamentos, próteses, órteses e outras tecnologias assistivas, da realização de vacinação de crianças, promoção à saúde bucal mediante odontologia.

Remanesce o direito de acompanhamento de um dos pais ou responsáveis ao infante nos estabelecimentos de atendimento de saúde em geral em casos de internação, segundo dispõe o art.



12 do ECA. Por mais que haja silêncio, evidente que esse direito também se aplica nos casos de consultas médicas e de saúde em geral, ainda que não se trate de caso de internação.

Por responsável, entenda-se: *“a pessoa que, não sendo pai nem mãe, zela pela criação e educação do menor, suprindo-lhe com regularidade suas necessidades básicas, mesmo que não tenha assumido em juízo encargo de tal envergadura”*¹². Incluem-se aí o tutor, guardião legal e também guardião de fato. Não se confunde com a figura de representante legal, munido do poder familiar, abrangendo somente a figura dos pais ou tutor.

Por fim, os últimos pontos a serem destacados quanto ao capítulo do direito à vida e à saúde no ECA diz respeito a procedimentos a serem adotados em caso de suspeitas de maus tratos de crianças e adolescentes e em caso de interesse da gestante ou mãe em entregar filho para a adoção.

Se houver suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante ou de maus-tratos contra criança ou adolescente, o Conselho Tutelar deve ser comunicado obrigatoriamente¹³, vide art. 13 do ECA. A atual redação de tal dispositivo foi dada pela Lei nº 13.010/2014, conhecida como Lei Menino Bernardo, que estabelece o direito de infantes serem educados e cuidados sem uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante.

Em se tratando de mães e gestantes que quiserem entregar seus filhos à adoção, devem ser conduzidas à Justiça da Infância e Juventude, sem constrangimento, conforme será visto adiante.

A adoção, enquanto forma de colocação em família substituta, é uma exceção à regra de que a criança deve ser preservada em sua família natural. A despeito disso, no caso de entrega voluntária de recém-nascidos para adoção, a Lei nº 13.509 de 2017 houve for bem disciplinar os termos dessa entrega para resguardar que a opção da genitora seja acompanhada por profissionais de múltiplas áreas, oferecendo a ela o devido apoio, tanto do ponto de vista jurídico, quanto psicológico e social. O procedimento para entrega voluntária está disposto no capítulo que trata do direito à convivência familiar e comunitária.

2. DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

Nesse capítulo do ECA, é evidenciado que liberdade, respeito e dignidade, direitos que são titularizados por todas pessoas, também o são pelos menores de idade. Confere-se, contudo, a estes direitos especiais contorno em razão do estágio de desenvolvimento físico, psicológico e moral dos infantes, inclusive ensejando direitos próprios, como o de brincar, praticar esportes e divertir-se.

Alguns autores denominam os direitos desse capítulo como “trilogia da proteção integral da criança e do adolescente”.

Referem-se, basicamente aos três pilares destacados.

2.1 DIREITO À LIBERDADE

Dando concretude ao seu teor, o legislador enumera, de forma exemplificativa, uma série de aspectos sobre a liberdade dos infantes no art. 16 do ECA:

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

- I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
- II - opinião e expressão;
- III - crença e culto religioso;
- IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

¹² José Luiz Monaco da Silva. *Estatuto da Criança e do Adolescente*. São Paulo, Saraiva, 1994. pg. 29.

¹³ A obrigação se dirige aos mais diversos agentes públicos e privados, porém é muito comum que essa obrigação surja para professores e médicos. As entidades públicas e privadas devem contar com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes (art. 70-B ECA). E são igualmente responsáveis pela comunicação as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes (§ único do 70-B).



- V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
- VI - participar da vida política, na forma da lei;
- VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

Note-se que é bem mais amplo do que o mero direito de ir e vir. É importante memorizar o conteúdo desse direito para não confundir com o direito ao respeito. Vê-se em provas de concurso público a tentativa de confundir os candidatos misturando o conteúdo deles.

No que diz respeito ao direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, vale lembrar que o juiz pode disciplinar a entrada e permanência de crianças e adolescentes em diversos espaços, desde que não o faça de modo geral e abstrato, conforme previsão no art. 149. Conforme visto alhures, atualmente o ECA e o STJ não admitem as portarias que criem “toque de recolher”, vedando genericamente a permanência de crianças nas ruas no período noturno desacompanhada dos responsáveis.

Como a própria lei ressalva, há restrições da liberdade deambulatória quando assim for necessário para a preservação da integridade do infante, amplamente considerada. Veja-se, por exemplo, que há uma série de restrições dispostas nos arts. 83 a 85, que versam sobre a necessidade de autorização para viajar, existindo inúmeras hipóteses em que crianças e adolescentes não podem viajar sozinhos, limitando sua liberdade de ir e vir. Da mesma forma, há locais cujo acesso é proibido a crianças e adolescentes.

No que tange à liberdade de opinião e expressão, não há diferenças significativas relativamente aos infantes. A opinião compreende tanto o pensamento quanto a manifestação desse, ao passo que expressão abrange a atividade intelectual, artística e de comunicação. Vale lembrar que, para participação de menores de idade em espetáculos públicos e concursos de beleza, como forma de exercício da liberdade de opinião e expressão, é necessário obter alvará judicial autorizando, vide art. 179, inciso II do ECA.

A liberdade de crença e culto, por sua vez, compreende o direito de escolha da própria religião, bem como não ter nenhuma fé ou crença. Aliás, cabe aos pais ou responsável, dentro da própria educação, a orientação religiosa de seus filhos, o que inclusive decorre do chamado pátrio poder, previsto nos arts. 1630 a 1638 do Código Civil. Um dos âmbitos do poder familiar é dirigir a criação e educação dos filhos. Faz parte da criação, evidentemente, o ensino da moral, dos bons costumes e, se assim desejarem os pais, da religião. Esse poder familiar, evidentemente, é calibrado conforme a idade e maturidade dos filhos, os quais poderão deixar de seguir o credo dos pais assim que tiverem a devida maturidade para realizar sua própria escolha.

Polêmica é a situação dos fiéis da religião Testemunha de Jeová, os quais, por convicção religiosa, não aceitam receber transfusão de sangue, ainda que em caso de risco de vida¹⁴.

O dever de educar dos pais, que inclui o ensino da religião, como já visto, não pode se sobrepor à própria obrigação de criar seu filho, resguardando os direitos fundamentais deste à vida e à integridade física. Portanto, não se pode admitir que a religião dos pais afete a própria existência dos filhos, fato este que configuraria verdadeiro abuso.

Destarte, o direito dos pais de educar os filhos na religião dos Testemunhas de Jeová não chega a ponto de ceifar a vida dos menores, na emblemática situação de ser necessária uma transfusão de sangue. Os pais, na qualidade de terceiros, não podem dispor da vida de seus filhos em nome de sua crença religiosa. Neste caso, há de prevalecer a vida do menor, o qual goza de especial proteção do Estado.

JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL, amparada em CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA, leciona que o autor

ao estudar um caso envolvendo a negativa em realizar transfusão de sangue em menor de idade, em virtude da religião da família, consigna que o exercício do pátrio poder não dá aos pais o direito de tomar decisões irreversíveis, que possam

¹⁴Priscilla Ramineli Leite Pereira. *Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová: implicações penais*. São Paulo, Ed. Spessotto. 2018.



colocar em risco a vida de seus filhos menores, e o credo professado não fica de fora disso. Ele tem razão, o pátrio poder não chega a tanto.¹⁵

Há uma parte minoritária da doutrina, por sua vez, que entende que não cabe aos pais somente, mas sim aos próprios filhos, eles mesmos, consentir com a não realização de transfusão de sangue, se essa for sua vontade. Esta doutrina é amparada na Teoria do Menor Amadurecido, pela qual o menor que demonstrar maturidade e capacidade decisória deve ter sua vontade respeitada, independentemente de sua idade, de tal sorte que a capacidade decisória depende da maturidade de cada um.

Todavia, verificar se o menor é ou não amadurecido exige disponibilidade de uma equipe interdisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, dentre outros, além de tempo para fazer uma análise profunda, tal como ocorre nos processos judiciais nas varas da infância e da juventude. Some-se a isso o fato de que, na imensa maioria das vezes, a decisão de realizar ou não transfusão de sangue deve ser tomada rapidamente, sem a possibilidade de tantas delongas.

Para não correremos o risco de por a cabo à vida de alguém vulnerável que não possui pleno discernimento, preferível optar pela vida, sendo esta indisponível para seus próprios titulares, quando estes forem incapazes, ou seja, quando menores de 18 anos, idade em que o legislador presumiu que há devida maturidade para tomada de decisões.

Sobre o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, como já dito, trata-se de um desdobramento da liberdade especialmente destinado aos infantes. Com efeito, desse direito decorre uma obrigação aos poderes públicos de criar espaços lúdicos. Destaque-se, por fim, que incumbe aos pais ou responsáveis dosar os limites de tal direito, intercalando-o, por exemplo, com a atividade de estudar.

A participação da vida familiar compreende tanto a família natural quanto a extensa, enquanto que a participação na comunidade representa que os adolescentes e as crianças tem voz e merecem ter atenção da comunidade, desfrutando desta.

A participação da vida política, por sua vez, formalmente depende de o adolescente completar 16 anos, idade a partir da qual a capacidade eleitoral ativa (possibilidade de votar) é adquirida. Lembre-se que o exercício do direito de sufrágio é facultativo em tal idade.

Finalmente, a liberdade ao refúgio, ao auxílio e à orientação representam que os infantes devem ser postos a salvo de qualquer violência, podem buscar refúgio para livrar-se dessa situação indevida, além de auxílio e orientação para propiciar seu desenvolvimento esclarecido.

Um exemplo de direito à liberdade fora do rol previsto no ECA, segundo VALTER KENJI ISHIDA, é o direito de visitas dos netos aos avós.

2.2 DIREITO AO RESPEITO

Segundo consta do art. 17 do ECA que “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.

Verifica-se que o direito ao respeito guarda estreita relação com os direitos da personalidade e, por esta razão, eventuais violações ao direito ao respeito podem levar à indenização por danos morais, inclusive por crianças de tenra idade, que não possuem ainda consciência e percepção.

Relativamente à proteção da imagem, importante julgado sobre o tema foi objeto do Informativo 511 do STJ. Restou estabelecido ser vedada a veiculação de material jornalístico com imagens que envolvam criança em situações vexatórias ou constrangedoras, ainda que não se mostre o rosto da vítima, e que o Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública com o intuito de impedir a veiculação de vídeo, em matéria jornalística, com cenas de tortura contra uma

¹⁵ Janaina Conceição Paschoal. *Ingerência indevida*. Tese (Livre docência em Direito) – Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 207-208.



criança, ainda que não se mostre o seu rosto. Embora o julgado tenha se referido especificamente à legitimidade do Ministério Público, o mesmo raciocínio pode ser utilizado para legitimar ação similar por parte da Defensoria Pública, ajuizando ação em nome do infante.

Outro ponto correlato diz respeito à vedação de divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Atenção! Não confunda com a divulgação da notícia sobre o fato, o que é admissível com ressalvas. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome (Art. 143 do ECA).

2.3 DIREITO À DIGNIDADE

A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e, no âmbito da infância e juventude, consiste em verdadeiro cumprimento à doutrina da proteção integral, especialmente no que tange à proibição de expor crianças e adolescentes a tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Tratamento desumano é aquele que impinge sofrimento físico ou mental; violento, é aquele que se fale de força física contra infantes; aterrorizante é aquele que embute medo, pavor ou terror, pensando-se, por exemplo, em casos de adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação; vexatório é aquele que impõe vergonha ou humilhação, como é o caso do bullying e, finalmente, constrangedor é o tratamento que implica embaraço, semelhante ao vexatório.

2.3.1 DIREITO À EDUCAÇÃO SEM CASTIGO FÍSICO, SEM TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE

Diz o art. 18-A que

a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-lo.

A Lei nº 13.010/2014 inseriu referido dispositivo no ECA e ficou conhecida como Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo, em homenagem à criança chamada Bernardo Uglione Boldrini que teria sido morta pelo pai e pela madrasta.

Castigo físico, para os fins do ECA, é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física que cause na criança ou adolescente sofrimento físico ou lesão.

Portanto, a “palmada” dada em uma criança, mesmo que não cause lesão corporal, deixando vestígios da agressão, poderá ser considerada castigo físico se gerar sofrimento físico. Todavia, cabe destacar que a lei não proíbe toda e qualquer palmada nas crianças e adolescentes. Somente é veda aquela que gere sofrimento físico ou lesão. Caso a palmada seja leve e não cause sofrimento nem lesão, em tese estará fora da incidência da lei. Frise-se que o projeto original da lei proibia expressamente qualquer palmada. Porém, houve um abrandamento com o texto final.

De toda forma, a lei se alinha com a moderna teoria educacional, a qual privilegia o ensinamento construtivo mediante diálogo e orientação, desprestigiando o uso de castigo físico. É a chamada educação não violenta.

Cabe lembrar que a abrangência da lei não se limita aos pais ou responsáveis, mas também incide sobre todos aqueles que cuidem, eduquem ou os protejam. Nisso se incluem os familiares, tutores, guardiães, professores, agentes públicos encarregados da execução de medida



socioeducativa, monitores em geral, cuidadores de entidades de acolhimento institucional, conselheiros tutelares, babás, dentre outros a serem aferidos mediante interpretação analógica.

Tratamento cruel ou degradante, por sua vez, é aquele que humilha, ameaça gravemente, ou ridiculariza a criança ou o adolescente. Perceba, portanto, que a Lei nº 13.010/2014 proíbe, além da violência física, qualquer forma de tratamento cruel ou degradante, o que pode acontecer mesmo sem contato físico, como no caso de agressões verbais.

Ainda sobre o tema, destaque-se importante julgado do STJ, veiculado no Informativo 598, onde se decidiu que a conduta da agressão, verbal ou física, de um adulto contra uma criança ou adolescente, configura elemento caracterizador da espécie do dano moral *in re ipsa*. Em outras palavras, é possível concluir que, segundo o STJ, o tratamento cruel ou degradante de uma criança ou adolescente, bem como o seu castigo físico, caracteriza o dano moral *in re ipsa*.

Em caso de alguém se utilizar de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de educação contra a criança ou adolescente, estará sujeito, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (inclusive na seara criminal), às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; V - advertência. As medidas previstas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.

Note-se que o castigo físico com lesão corporal sempre foi punido. Pode enquadrar-se nos tipos dos arts. 129 ou 136 do Código Penal, a depender do caso concreto. A Lei nº 13.010/2014 não prevê nenhum crime. No entanto, a depender do caso concreto, o castigo físico aplicado ou o tratamento cruel ou degradante empregado poderá configurar algum crime previsto no Código Penal ou no ECA.

Assim, se o castigo físico provocar lesão corporal, haverá punição com base no art. 129 do CP. Por outro lado, se ele consistir em “expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”, restará caracterizado o crime previsto no art. 136 do CP.

Por fim, eventualmente, a conduta que importe em tratamento cruel ou degradante, a depender do caso concreto, amoldar-se-á ao tipo do art. 232 do ECA: “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”.

O pai ou mãe agressor poderão perder o poder familiar por conta dessa conduta, conforme disposto no art. 1.638 do Código Civil.

No mais, cabe ressaltar que a Lei nº 13.010/2014 não viola o Direito de Família Mínimo, e, desta feita, não importa em uma interferência indevida do Estado nas relações familiares. Isso porque a CF/88 diz ser dever também da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, e ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão (art. 227). Essa lei contribuiu para esse fim.

3. JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. **MENOR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. ART. 19-T DA LEI 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.** 1. O entendimento a quo está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar no



polo passivo de demanda que objective o acesso a medicamentos (AgInt no REsp 1.597.299/PE, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/11/2016; AgRg no REsp 1.584.691/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/11/2016). 2. O art. 19-T da Lei 8.080/1990, que veda a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa, reproduz regra geral, que não deve ser aplicada de forma isolada dos fatos, acabando por violar direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde. 3. Com efeito, in casu, o fornecimento do fármaco não registrado na Anvisa foi autorizado pela Corte de origem em caráter excepcional e não para a comercialização, visando ao atendimento de necessidade de menor portador de moléstias de natureza grave. 4. **Ademais, em se tratando de criança, com apenas 10 (dez) anos na data da distribuição da demanda, "não há dúvida de que a plausibilidade do fornecimento do remédio por ela solicitado, a cargo do Poder Público, decorre diretamente das promessas da proteção integral e da prioridade absoluta, ambas positivadas no art. 227 da Constituição Federal; especificamente no tocante à saúde, o pleito encontra conforto nos arts. 11 e seguintes do ECA e, mais, no art. 24 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU/1989), ratificada pelo Decreto Presidencial 99.710/90"** (AgRg no AgRg no AREsp 685.750/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 9/11/2015). 5. Recursos Especiais não providos (STJ, REsp 1645067/RS, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ 07/03/2017).

Ação civil pública. Dignidade de crianças e adolescentes ofendida por quadros de programa televisivo. Dano moral coletivo. Existência. A conduta de emissora de televisão que exhibe quadro que, potencialmente, poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes configura lesão ao direito transindividual da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo (REsp 1.517.973-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018 – Informativo n. 618)

IMAGENS CONSTRANGEDORAS. É vedada a veiculação de material jornalístico com imagens que envolvam criança em situações vexatórias ou constrangedoras, ainda que não se mostre o rosto da vítima. A exibição de imagens com cenas de espancamento e de tortura praticados por adulto contra infante **afronta a dignidade da criança exposta na reportagem, como também de todas as crianças que estão sujeitas a sua exibição.** O direito constitucional à informação e à vedação da censura não é absoluto e cede passo, por juízo de ponderação, a outros valores fundamentais também protegidos constitucionalmente, como a **proteção da imagem e da dignidade das crianças e dos adolescentes** (arts. 5º, V, X, e 227 da CF). Assim, esses direitos são restringidos por lei para a proteção dos direitos da infância, conforme os arts. 15, 17 e 18 do ECA. (Informativo 511 - REsp 509.968-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/12/2012).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECUSA DE CLÍNICA CONVENIADA A PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS. **DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VÍTIMA MENOR. IRRELEVÂNCIA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE.** - A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Precedentes - **As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02.** - Mesmo quando o prejuízo impingido ao menor decorre de uma relação de consumo, o CDC, em seu art. 6º, VI, assegura a efetiva reparação do dano, sem fazer qualquer distinção quanto à condição do consumidor, notadamente sua idade. (...) **Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira peculiar de se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a cerca, estando**



igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a angústia. - Na hipótese específica dos autos, não cabe dúvida de que a recorrente, então com apenas três anos de idade, foi submetida a elevada carga emocional. Mesmo sem noção exata do que se passava, é certo que percebeu e compartilhou da agonia de sua mãe tentando, por diversas vezes, sem êxito, conseguir que sua filha fosse atendida por clínica credenciada ao seu plano de saúde, que reiteradas vezes se recusou a realizar os exames que ofereceriam um diagnóstico preciso da doença que acometia a criança. Recurso especial provido. (STJ, REsp nº 1037759-RJ, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 23/02/2010).

CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. **AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. INJUSTIÇA. CRIANÇA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA.** ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 01.04.2014. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 04.07.2016. Julgamento: CPC/2015. (...) 4. **As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02.** 5. A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral in re ipsa. 6. Sendo presumido o dano moral, desnecessário o embate sobre a repartição do ônus probatório. 7. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. (STJ, REsp nº 1642318-MS, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 07/02/2017).

QUESTÕES

1- Juiz de Direito – TJMS/2020 (FCC) O acompanhamento domiciliar é previsto expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente

- a) para o atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, se necessário.
- b) nas hipóteses de desistência dos genitores da entrega de criança após o nascimento, pelo prazo de 180 dias.
- c) para crianças e adolescentes reintegrados à sua família natural ou extensa após a permanência em serviços de acolhimento institucional.
- d) às gestantes que apresentem gravidez de alto risco à saúde e ao desenvolvimento do nascituro.
- e) às crianças detectadas com sinais de risco para o desenvolvimento biopsicossocial por meios dos protocolos padronizados de avaliação.



2- Juiz de Direito – TJRS/2019 (VUNESP) Quanto ao direito à saúde e à vida da criança e do adolescente, à luz dos artigos 7º e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

- a) assistência odontológica, com o fito de garantir a saúde bucal de crianças e adolescentes, representa medida de respeito à integridade física da pessoa em desenvolvimento, e, por isso, não se aplica à gestante, que será inserida em programa específico voltado à saúde da mulher.
- b) o descumprimento das obrigações impostas pelo artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente configura ilícito de natureza administrativa, nos termos do artigo 228 do mesmo diploma legal.
- c) as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos à adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude.
- d) a obrigação de manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, terá seu prazo de dezoito anos reduzido ou dispensado, se as entidades hospitalares fornecerem declaração de nascimento vivo, em que constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
- e) o fornecimento gratuito de medicamentos, próteses e outros recursos necessários ao tratamento, habilitação ou reabilitação de crianças e adolescentes constitui obrigação do Poder Público e a reserva do possível afasta interferência judicial no desempenho de políticas públicas na área da saúde, em caso de descumprimento.

3- Juiz de Direito – TJPA/2019 (VUNESP) O pai que usa de força física contra seu filho menor de idade para discipliná-lo incide no que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) denomina

- a) tratamento degradante.
- b) tratamento cruel.
- c) vexame.
- d) violência doméstica.
- e) castigo físico.

4- Promotor de Justiça – MPE/MT – 2019 (FCC) O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade,

- a) inclusive o da preservação da imagem.
- b) inclusive o de trabalhar em qualquer idade.



- c) exceto o de participar da vida política, na forma da lei.
- d) exceto o de brincar, praticar esportes e divertir-se.
- e) exceto o de buscar refúgio, auxílio e orientação.

5- Promotor de Justiça – MPMG – 2017 Assinale a alternativa INCORRETA: São direitos das gestantes e parturientes, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente:

- a) Atendimento pré-natal no estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.
- b) Um acompanhante, de sua preferência, durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
- c) Alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio e amamentação.
- d) Acompanhamento saudável durante toda a gestação, parto natural cuidadoso, aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.

6- Defensor Público – DPE/RO – 2017 (VUNESP) No tocante aos direitos fundamentais, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

- a) se entende por família extensa ou ampliada aquela formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
- b) a atenção primária à saúde deverá prestar apoio à gestante, exceção feita àquelas que abandonarem as consultas de pré-natal.
- c) será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas, promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, que dependerá de autorização judicial.
- d) o Conselho Tutelar poderá aplicar a medida de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico aos agentes públicos executores de medidas socioeducativas que utilizarem tratamento degradante como formas de educação.
- e) a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana quando desejar.

GABARITO

- 1. A
- 2. C



3. E

4. A

5. A

6. D

CAPÍTULO 3 – DIREITOS FUNDAMENTAIS: PARTE 2

1. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

1.1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE A CONVIVÊNCIA FAMILIAR

Trata-se do direito fundamental da criança e do adolescente de viver e ser criado junto de sua família natural ou, subsidiariamente, de família extensa, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Referido direito é uma ampliação daquilo que está previsto na Convenção dos Direitos da Criança (1989), que dispõe que a criança não pode ser separada dos pais contra sua vontade.

A entidade familiar goza de proteção constitucional, vide art. 226 da Lei Maior, incluindo-se no conceito de entidade familiar tanto as uniões estáveis homoafetivas, segundo decidido pelo STF no bojo da ADI 4277/DF, quanto a comunidade formada por qualquer de seus pais e seus descendentes.

De acordo com o art. 25 do ECA, a família natural (*caput*) é aquela composta pelos pais (ou um deles) e os descendentes, e família extensa ou ampliada (parágrafo único) é a formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade (p. ex., tio/sobrinho, avô/neto, que tenham convívio).

A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família – natural ou extensa – terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que esta criança ou adolescente será incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção.

A prioridade da família natural persiste ainda nas hipóteses em que os pais estejam privados de sua liberdade. Nesse sentido, prevê o ECA que será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial.

Excepcionalmente, caso a manutenção ou reintegração em família natural não atenda ao melhor interesse da criança e do adolescente, haverá sua interseção em família substituta, que deverá levar em consideração o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.

A colocação em família substituta dá-se mediante guarda, tutela ou adoção, vide art. 28 do ECA, especialmente quando os direitos fundamentais dos infantes são ameaçados ou violados, ou ainda quando os genitores não podem mais exercer o poder familiar, por exemplo, em caso de morte.

Quando se tratar de colocação em família substituta estrangeira, a única modalidade aceita é a adoção.

Ademais, a colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial.

Paralelamente à ideia de família natural e família substituta, há os institutos do acolhimento familiar e acolhimento institucional. Com efeito, se a criança ou o adolescente estiver em situação de risco (art. 98), o juiz da infância e juventude poderá aplicar medidas de proteção elencadas no art. 101. Dentre elas, temos o acolhimento institucional (art. 101, VII) e o acolhimento familiar (art. 101, VIII).

Ambas dependem de autorização judicial, porém, as entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação judicial, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. É o caso, por exemplo, de acolhimento gerado por meio de decisão do Conselho Tutelar, que encaminha o infante diretamente à instituição de acolhimento. São medidas provisórias e excepcionais, sendo preferível o acolhimento familiar, tratando-se de mecanismos de transição para reintegração familiar ou, não



sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade (art. 101, § 1º).

O acolhimento familiar consiste na entrega de criança ou adolescente em situação de risco a uma família previamente cadastrada junto ao Poder Público com o objetivo de ampará-lo temporariamente até que seja reintegrado ao convívio familiar ou colocado em família substituta. Neste período, a família acolhedora recebe uma ajuda de custo (normalmente em torno de 1 salário mínimo). Segundo KÁTIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE MACIEL, se trata de uma modalidade de guarda. Segundo o art. 19, §1º do ECA, a cada 3 meses a situação da inserção em acolhimento familiar deverá ser reavaliada pelo juízo da infância.

O acolhimento institucional, por sua vez, presta-se ao mesmo fim, mas ao em vez de entregar a criança ou o adolescente a uma família, entrega-se a uma entidade de atendimento (antigamente chamada “abrigo”) a fim de que ali ele fique protegido de situações de maus tratos, desamparo ou qualquer outra forma de violência (física ou moral) que estava sofrendo. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.

A permanência em acolhimento institucional deve ser reavaliado a cada 3 meses pela autoridade judiciária competente e não se prolongará por mais de 18 meses, salvo necessidade comprovada que atenda ao superior interesse da criança e adolescente, devidamente fundamentada.

Em síntese, o objetivo do acolhimento familiar ou institucional é propiciar a volta da criança à família natural em algum momento. E quando isso não é possível, deve viabilizar sua colocação em família substituta. Caberá ao juiz competente, fundado no relatório da equipe interprofissional ou multidisciplinar, ouvindo previamente o Ministério Público, decidir pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta.

1.2. ENTREGA DE RECÉM-NASCIDO PARA ADOÇÃO

Casos há em que gestantes engravidam sem efetivamente estarem preparadas para criar um filho. Independente de qual seja o motivo, como no Brasil não se admite o abortamento, salvo hipóteses excepcionais previstas no Código Penal, o legislador preocupou-se em normatizar a entrega de recém-nascido para adoção para privilegiar a legalidade do ato e garantir uma convivência familiar saudável ao infante. A Lei nº 13.509/2017 houve por bem acrescentar o art. 19-A no ECA, estabelecendo o procedimento para tanto, evitando-se, desta forma, expedientes irregulares, como a entrega da criança para determinado casal.

Com efeito, a gestante ou mãe que manifeste interesse em encaminhar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Após seu encaminhamento, será ouvida pela equipe interprofissional do juízo, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal.

O relatório da equipe interprofissional subsidiará não só futura decisão do juiz quanto à adoção, como também quanto à necessidade de encaminhar a mãe ou gestante a atendimento especializado de saúde ou assistência social.

A despeito da vontade da genitora, como a adoção é forma de colocação em família substituta e, portanto, excepcional, o setor técnico deve realizar busca à família extensa, para promoção da manutenção dos vínculos bebê com a família natural, conforme definido nos termos do parágrafo único do art. 25 do ECA. A busca respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, tendo em vista a necessidade de o procedimento ser célere.

Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional ou de quem estiver habilitado a



adotá-la, que terá o prazo de 15 dias para propor ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência.

Cabe ressaltar que, após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada em audiência.

Na hipótese de desistência pelos genitores - manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional do juízo - da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Finalmente, deve ser destacado que a lei garante à mãe o direito de ser encaminhada sem constrangimento ao juizado da infância, bem como o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei, que trata do direito ao adotado de conhecer sua origem biológica.

1.3. PROGRAMA DE APADRINHAMENTO

Além de disciplinar a entrega de recém-nascido, a Lei nº 13.509/17 também foi responsável por disciplinar o instituto do apadrinhamento para crianças e adolescentes que estejam acolhidas institucionalmente ou em acolhimento familiar e que possuam remotas chances de adoção. O apadrinhamento, por sua vez, pode ser de duas espécies: afetivo e financeiro.

O apadrinhamento afetivo tem como finalidade incentivar a formação de vínculos afetivos entre crianças e adolescentes acolhidos e voluntários não relacionadas ao acolhimento institucional ou familiar, que são os padrinhos.

Segundo VALTER KENJI ISHIDA: “o apadrinhamento afetivo tem por objetivo promover vínculos afetivos seguros e duradouros entre eles e pessoas da comunidade que se dispõe a ser padrinhos e madrinhas.”¹⁶

Para tanto, espera-se que o padrinho exerça uma função semelhante à de um parente ou amigo próximo da família, podendo inserir o acolhido em seu meio sociofamiliar por meio da participação em festas familiares (Ano Novo, Natal, Páscoa, etc.), convívio em datas comemorativas (aniversário, dia das crianças, etc.) e realização de atividades recreativas (cinema, parques, etc.).

Cabe ressaltar que não se trata de modalidade de guarda, uma vez que a responsabilidade pela guarda remanescerá com o estabelecimento acolhedor ou família acolhedora.

O apadrinhamento financeiro, de outro lado, se caracteriza pela contribuição financeira à criança, de acordo com suas necessidades, por meio do custeio de cursos, materiais, consultas e tratamentos médicos, roupas, brinquedos, por exemplo. O apadrinhamento financeiro também pode ser realizado por pessoa jurídica

É possível que o padrinho ou madrinha afetivos também sejam concomitantemente financeiros.

Em suma, os padrinhos devem viabilizar a convivência familiar e comunitária desses jovens para contribuir com sua formação social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.

O ECA estabelece algumas regras sobre quem pode ser padrinho ou madrinha:

a) pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte.

b) pessoas jurídicas também podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento.

2. PODER FAMILIAR

A família terá sobre a criança poder familiar, exercido pelo pai e a mãe, em igualdade de condições, consoante o que preleciona o art. 226, §5º da CF e art. 21 do ECA.

¹⁶ Valter Kenji Ishida. *Estatuto da criança e do adolescente – Doutrina e jurisprudência*. Salvador: JusPodium, 2019. Pg. 92.



O poder familiar (antigo pátrio poder) é o conjunto de direitos e deveres que tem por finalidade, no que toca ao interesse da criança e do adolescente, a proteção da sua segurança, moralidade, educação, permitindo o desenvolvimento do infante. Assim, o poder familiar deve ser exercido em favor dos filhos, tratando-se de uma missão confiada aos pais para a regência da pessoa e dos bens dos filhos, desde a concepção até a idade adulta¹⁷.

Aliás, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação¹⁸. O poder familiar, portanto, é exercido da mesma maneira, independente da origem da filiação.

São características do poder familiar: a) é um *múnus* público (poder-dever), b) irrenunciável;/ os pais não podem abrir mão do poder familiar, c) inalienável: não pode ser transferido a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso, d) imprescritível: o não exercício do poder familiar ao longo do tempo não implica sua perda, e) é incompatível com a tutela.

Caso haja discordância entre os responsáveis pelo poder familiar, será assegurado a qualquer deles o direito de recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

Muito embora o ECA contenha em seu bojo previsão de alguns deveres de que são incumbidos os pais, tais como o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, o Código Civil, em seu art. 1634, prevê rol extenso dos deveres dos pais no exercício do poder familiar. Veja-se:

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

- dirigir-lhes a criação e a educação;
- exercer a guarda unilateral ou compartilhada;
- conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para: casarem, viajarem ao exterior, para mudarem sua residência permanente para outro Município;
- nomear-lhes tutor por testamento, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivente não puder exercer o poder familiar;
- representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
- reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
- exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.

Referido rol é meramente exemplificativo, ante a ampla gama de aspectos que decorrem do poder familiar. Os pais que descumprem a obrigação que tem com seus filhos poderão sofrer sanções de natureza civil ou penal.

Inúmeras são as sanções de natureza civil, tais como o afastamento liminar do pai do convívio com o filho, quando for o agressor; acolhimento institucional ou familiar da criança ou do adolescente, caso não se resolva a situação com a retirada do agressor de casa e mantendo a criança, promovendo-se a reavaliação no prazo máximo de 3 meses; responsabilização civil por danos morais e materiais, suspensão ou perda do poder familiar.

Interessante é a questão do dano moral decorrente de abandono afetivo. O tema é polêmico e oscilante. De acordo com decisão paradigmática do STJ de lavra da Ministra Nancy Andrighi, o abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar da prole constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral compensável (Informativo 496/2012). Em seu voto, a ministra afirmou a seguinte frase, que se notabilizou no campo do direito das famílias e da infância: “Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever”. Há também decisões entendendo que a omissão quanto aos cuidados materiais também é capaz de gerar dano moral, vide informativo 609/2017.

¹⁷ Carlos Alberto Bittar Filho. *Pátrio Poder: Regime Jurídico*. RT 676/78, pg. 80.

¹⁸ No bojo do Código Civil de 1916, havia diferenciações entre filhos. Referido código previa a figura da filiação ilegítima, aquela que não decorria de justas núpcias, concebidos por homem e mulher não casados ou que não se casassem após o nascimento. Os filhos ilegítimos poderiam ser naturais ou espúrios. Naturais são aqueles nascidos de casal sem impedimento ao matrimônio, ao passo que nos espúrios há impedimento ao matrimônio. Os espúrios ainda se subdividem em adulterinos (um dos pais já é casado) ou incestuosos (impedimento motivado por parentesco).



No que tange à seara criminal, o descumprimento do poder familiar poderá caracterizar diversos crimes, tais como lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar (art. 129, §9º do CP), abandono de incapaz (art. 133 do CP), exposição ou abandono de recém-nascido (art. 134 do CP), maus-tratos (art. 136 do CP), tortura (art. 1, inciso II da lei 9455/97), etc.

Aliás, é efeito penal da condenação a incapacidade para o exercício do poder familiar quando o crime for doloso sujeito à pena de reclusão cometido contra filho ou filha ou outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, outro descendente ou outro tutelado ou curatelado, vide art. 92, inciso II do CP, com redação dada pela Lei nº 13.715/2018, devendo tal efeito ser declarado em sentença.

Há forte linha doutrinária no sentido de que a incapacidade para o exercício do poder familiar decorrente de condenação contra um filho se estende para todos os demais, corrente essa que foi reforçada pelo teor da nova lei. Nesse sentido, afirma CLEBER MASSON:

Essa incapacidade pode ser estendida para alcançar outros filhos, pupilos ou curatelados, além da vítima do crime. Não seria razoável, exemplificativamente, decretar a perda do poder familiar somente em relação à filha de dez anos de idade estuprada pelo pai, aguardando fosse igual delito praticado contra as outras filhas mais jovens, para que só então se privasse o genitor desse direito¹⁹.

Seguindo a mesma linha, referida lei criou parágrafo único do art. 1.638 do Código Civil, o qual diz que:

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que:

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher;

b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão;

II – praticar contra filho, filha ou outro descendente:

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher;

b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão.

Portanto, frise-se que a condenação criminal do pai ou da mãe, por si só, não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente.

2.1. PROCESSO JUDICIAL E CONTRADITÓRIO PARA PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

As falhas e violações dos deveres inerentes ao poder familiar poderão ensejar tanto a suspensão quanto a perda do poder familiar.

Para ser decretada a perda do poder familiar, que consiste na definitiva destituição de tal poder, deve haver alguma das hipóteses previstas no art. 1638 do Código Civil, que trata de situações graves de violação do poder familiar em prejuízo aos filhos, como é o caso de castigar imoderadamente o filho e deixá-lo em abandono (material ou psicológico).

Nesse ponto, é importante destacar que a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou mesmo a suspensão do poder familiar, ocasião em que a família

¹⁹ Cleber Masson, *Direito Penal Esquematizado – Parte Geral*. 2ª ed. São Paulo: Método, 2009, p. 798



será obrigatoriamente incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção, normalmente no âmbito da assistência social. São exemplos de programas oficiais de proteção, o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC, também conhecido como LOAS), Renda Cidadã, dentre outros.

Há decisões judiciais no sentido de que a perda do poder familiar não permite que os genitores biológicos possam obter o direito de visitas aos filhos, diante de sua incompatibilidade lógica e jurídica.

É pressuposto lógico para a adoção a decretação da perda do poder familiar, eis que na adoção surge um novo vínculo familiar, rompendo completamente o anterior, ressalvados os efeitos para fins de impedimentos matrimoniais, consoante as hipóteses da lei civil. Aliás, o STJ entende que é possível haver pedido de perda de poder familiar no processo de adoção.

A suspensão do poder familiar, por sua vez, é temporária e permite o retorno ao *status quo ante*. De acordo com o art. 1637 do Código Civil,

se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.

Tanto a perda quanto a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22, ou seja, dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores e a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais).

Finalmente, além da perda do poder familiar, há outras causas para a extinção deste, que acontecem em razão de algum fenômeno natural, como a morte dos genitores, ou jurídico, como a emancipação. São ainda hipóteses de extinção do poder familiar, vide art. 1635 do CC: a morte do filho, a maioridade e adoção.

3. RECONHECIMENTO DE FILHO E ESTADO DE FILIAÇÃO

A criança e o adolescente possuem direito à filiação, o que significa tradicionalmente ter reconhecidos como seus um pai e uma mãe, sejam eles casados ou não. Aliás, já decidiu o STJ que “o reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado sem qualquer restrição, fundamentado no direito essencial à busca pela identidade biológica” (Jurisprudência em teses, item “8”, nº 27).

Nesse sentido, dispõe o art. 26 do ECA que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, qualquer que seja a origem da filiação: no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura, por outro documento público. O ECA nada menciona a respeito de *documento privado*.

Por outro lado, a Lei 8560/92 também dispõe sobre o mesmo tema, informando ser possível o reconhecimento de filiação em registro de nascimento, escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório, por testamento e por manifestação direta e expressa perante juiz. No mesmo sentido é o art. 1609 do Código Civil.

Tendo em vista que o escopo do ECA é justamente facilitar o reconhecimento de filhos, especialmente em se tratando de filhos fruto de relações ocasionais ou extraconjugais, uma leitura primada pelo diálogo de fontes e guiada pelo princípio do melhor interesse da criança deve justificar o reconhecimento da filiação em documento privado arquivado em cartório.

O reconhecimento do estado de filiação pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. A existência de condição para o reconhecimento de filiação *post mortem* dá-se para evitar que o ato seja motivado meramente por interesse patrimonial



decorrente de sucessão, uma vez que, em havendo descendentes do *de cujus*, seu ascendente fica excluído da sucessão.

Quanto à natureza jurídica do reconhecimento de filho, trata-se ato jurídico em sentido estrito, produzindo os efeitos dispostos na lei, tais como deveres inerentes ao poder familiar, obrigação alimentar, sucessão hereditária, dentre outros.

São características do reconhecimento da filiação: a) irrevogabilidade: ainda que tenha sido feito por testamento; o testamento é revogável, mas, no tocante ao reconhecimento do filho, será irrevogável, b) personalíssimo: via de regra, somente o seu titular poderá exercer, ressaltando-se a hipótese do art. 102 do ECA, o qual prevê que se a paternidade não estiver definida, o próprio Ministério Público deverá ingressar com a ação de investigação de paternidade, salvo se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade, a criança for encaminhada para adoção; c) indisponível: não se pode vender, dispor ou abrir mão ao direito de filiação; d) imprescritível: durante a vida toda é possível exercer o direito de estado de filiação, não havendo prazo para ser exercício. Sobre esse último ponto, cabe destacar apenas que o direito à petição da herança está sujeito à decadência.

O assunto do reconhecimento do estado de filiação normalmente está relacionado à filiação biológica ou consanguínea. No entanto, a própria lei reconhece que a filiação pode ter mais de uma origem.

A socioafetividade, consistente na relação de convívio diário que induz um “estado de filho”, também é passível de gerar filiação e por consequência parentalidade. Em que pese não seja expressamente disposta na lei, já é plenamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência.

Segundo já decidiu o STJ:

A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico *de* vida e a condição social ostentada, valorizando, além *dos* aspectos formais, como a regular adoção, a verdade real *dos* fatos. A posse *de estado de filho*, que consiste no desfrute público e contínuo da condição *de filho* legítimo, restou atestada pelas instâncias ordinárias.

Por fim, cabe lembrar que a adoção também gera estado de filiação, promovendo um novo vínculo jurídico entre adotante e adotado.

4. FAMÍLIA SUBSTITUTA

Consoante já estudado no tópico 1 do presente capítulo, são três as espécies de colocação em família substituta: a guarda, tutela e adoção.

Sempre que possível, antes da colocação em família substituta, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Em se tratando especificamente de adolescente, serão obrigatórios sua oitiva em audiência e seu consentimento.

Além disso, para a inserção em família substituta ser menos traumática, deve-se levar em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade com o infante, da mesma forma que, na medida do possível, grupos de irmãos serão inseridos na mesma família substituta. Essa regra pode ser excepcionada em caso de comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa. De todo modo, em qualquer caso, deve-se procurar evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Ex.: colocá-los em famílias que moram na mesma cidade.

Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, dadas as suas peculiaridades de natureza sociocultural, o ECA estabelece que é ainda obrigatório: a) que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural,



seus costumes, suas instituições, desde que compatíveis com os direitos fundamentais; b) que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia e c) a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar.

Dispõe o art. 29 do ECA que não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. A referida incompatibilidade pode ter fundamento jurídico, como por exemplo, no caso de avô que deseja adotar neto, em face da expressa proibição legal²⁰ ou em razão de circunstância fática inadequada ao crescimento e desenvolvimento sadio dos protegidos.

4.1. GUARDA

Conceitualmente, trata-se de modalidade de colocação em família substituta, que confere ao guardião alguns atributos do poder familiar (como os deveres de assistência material, moral e educacional), bem como o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais (art. 33, caput).

Nas palavras de RUBENS LIMONGI FRANÇA: “guarda é o conjunto de relações jurídicas que existe entre uma pessoa e a criança ou adolescente, dimandas do fato de estar esta sob o poder ou companhia daquela, e da responsabilidade daquela em relação a este, quanto à vigilância, direção e educação”²¹.

Ademais, serve para regulamentar uma situação de fato consolidada (33, § 1º), possui caráter provisório (revogável a qualquer tempo), e não suspende nem cessa o poder familiar, de modo que a guarda e o poder familiar não são institutos excludentes entre si. Por expressa vedação legal, não se admite a guarda em caso de adoção por estrangeiros.

A doutrina classifica a guarda em algumas espécies:

a) Guarda de fato: também chamada de informal, é aquela na qual o menor de 18 anos encontra-se assistido por pessoa que não detém qualquer atribuição legal ou deferimento judicial para tal encargo. Não há, portanto, vínculo jurídico estabelecido pelo Poder Judiciário. De acordo com KATIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE MACIEL, quem é guardião de fato de uma criança ou adolescente não pode ser considerado formalmente seu responsável²².

b) Guarda provisória: poderá surgir de uma demanda com pedido de adoção ou tutela. Tem caráter provisório, sendo uma espécie de transição para a futura adoção ou tutela.

c) Guarda definitiva: também chamada de permanente concedida ao final de processo autônomo, destinando-se a atender situações peculiares, onde não se logrou uma adoção ou tutela, mas em que busca tão somente a guarda. Atenção, no bojo destes processos autônomos de guarda, é possível que a título de tutela antecipada seja conferida a guarda provisória. Cite-se, por exemplo, caso de avós que criam os netos e buscam regularizar tal situação judicialmente.

d) Guarda subsidiada: trata-se da guarda concedida a pessoas que aceitam participar de programas de acolhimento familiar, nos termos do art. 34 do ECA, as quais inclusive podem receber subsídios oriundos de recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção do acolhimento.

e) Guarda derivada: deferida por ocasião da concessão de um pedido de tutela. Quem tem a tutela necessariamente terá a guarda.

f) Guarda que recai sobre o dirigente de entidade de acolhimento institucional: a lei equipara o dirigente de entidade de acolhimento institucional ao guardião. Será o guardião das crianças acolhidas na entidade.

²⁰ Há caso excepcional de julgado do STJ em que se permitiu tal espécie de adoção, mesmo em contrariedade ao texto expresso do ECA, por atender ao melhor interesse da criança. Veja-se na seção de jurisprudência deste capítulo.

²¹ Rubens Limongi França. Instituições de direito civil – volume 2. São Paulo: Saraiva, 1972, pg. 45.

²² Katia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel. Curso de Direito da Criança e do Adolescente – Aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva, 7ª Ed., 2014, pg. 223.



g) Guarda para acolher estrangeiro refugiado: caso os pais do estrangeiro criança ou adolescente estiverem mortos ou não conseguirem entrar no país, ela será colocada sob a guarda de um adulto de sua nacionalidade, com o objetivo de facilitar sua adaptação.

h) Guarda protetiva ou estatutária: é a guarda confiada a alguém no bojo de um processo de aplicação de medida protetiva à criança e ao adolescente em situação de risco, em trâmite na Vara da Infância. Prevista o art. 101, inciso IX do ECA.

i) Guarda peculiar: prevista no art. 33, §2º do ECA, visando suprir falta eventual dos pais, permitindo-se que o guardião represente o guardado em determinada situação específica.

Majoritariamente, não se entende possível a concessão da guarda à pessoa jurídica, como por exemplo, à entidade abrigadora do infante.

Há previsão expressa no ECA de que o menor sob guarda de alguém é considerado seu dependente para todos os fins, inclusive previdenciários. Essa previsão (que possui redação original desde a promulgação do ECA no ano de 1990), colide com o disposto na Medida Provisória nº 1523/1997, convertida na Lei nº 9528/1997, que excluiu o menor sob guarda da condição de beneficiário para fins previdenciários do art. 16 da Lei 8213/91 (Lei de Benefícios do Regime Geral Previdência Social). Essa previsão decorre de fraudes que ocorreram, por exemplo, quando avós se tornavam guardiões de seus netos a fim de deixar pensão por morte a eles, sem que de fato exercessem a guarda.

Neste ponto, a jurisprudência foi bastante oscilante, nada obstante, as mais recentes decisões do STJ são no sentido de reconhecer ao menor sob guarda a posição de dependente para fins previdenciários (REsp. nº 1141788, DJE 07.12.2016). Veja-se, nesse sentido, os informativos Informativos 546/2014 e 595/2017 do STJ.

Desta forma, prevalece que, em atenção à doutrina da proteção integral, ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei 9.528/97 na Lei 8.213/91, que deu a redação do §2º do art. 16

Cabe destacar, ademais, que a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4878) junto ao STF para pedir interpretação conforme à atual redação do art. 16, §2º da Lei de Benefícios, incluindo-se a criança e o adolescente sob guarda em seu âmbito de incidência.

Prosseguindo na análise da guarda, deve-se lembrar que ela não é incompatível com o poder familiar e, como regra geral, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos.

Evidente que, se a guarda foi deferida com forma de medida protetiva em desfavor dos pais, diante de alguma situação de risco ou vulnerabilidade social, é possível que a autoridade judicial proíba as visitas. Além desta exceção, se a guarda for aplicada em preparação para adoção, também não há que se cogitar de visitas.

Finalmente, consoante dispõe o art. 35 do ECA, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Assim, ainda que haja a guarda chamada definitiva decorrente de ação judicial própria para tanto, será possível revogá-la em havendo motivos para tanto.

4.2. TUTELA

Por meio da tutela, uma pessoa maior de idade assume dever de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente que não esteja sob o poder familiar dos seus pais. Desta feita, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.

A hipótese mais comum de tutela ocorre quando os genitores do infante são falecidos. Também é cabível a tutela no caso de pais ausentes e pais destituídos do poder familiar.



Ademais, a tutela tem como finalidade suprir a carência de assistência e representação legal ante alguma das situações supradescritas. Além disso, o tutor administra os bens do tutelado.

A nomeação do tutor poderá decorrer de declaração de vontade, manifestada pelos pais, através de testamento (tutela testamentária), ou mesmo por outro documento idôneo. Neste caso, o tutor nomeado deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato.

Essa nomeação não tem caráter obrigatório. O juiz decidirá conforme o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Não deve haver outra pessoa em melhores condições de assumir a tutela.

Chama-se legítima, por sua vez, a tutela incumbida a parentes próximos, na falta de indicação testamentária. Já a tutela dativa ocorre quando não houver tutor testamentário ou legítimo, recaindo o múnus a pessoa estranha aos laços consanguíneos.

Através da tutela, a criança ou adolescente obterão direitos previdenciários ligados ao tutor.

Destaque-se, por fim, que à destituição da tutela é aplicável o disposto no art. 24, ou seja, a perda e a suspensão da tutela serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório.

4.3. ADOÇÃO

4.3.1. ASPECTOS GERAIS DA ADOÇÃO

Cuida-se de forma de colocação em família substituta que estabelece vínculo jurídico definitivo e irrevogável entre adotante e adotado, rompendo os vínculos familiares anteriores. Trata-se de medida excepcional, que só deve ser deferida se realmente não for possível a manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa e ainda ficar demonstrado que a adoção apresenta reais vantagens para o adotando. Além disso, deve fundar-se em motivos legítimos.

Em última análise, a adoção é ato que outorga a condição de filho e todos seus consectários legais ao adotado.

Quanto à sua natureza jurídica, é considerado um ato jurídico em sentido estrito, conferindo direito ao nome, direito à herança, além de realizar a formação de vínculo irrevogável. Não é possível conferir certos efeitos à adoção e excluir outros, como por exemplo, pretender a exclusão do adotado à herança.

A despeito da irrevogabilidade expressa no art. 39, §1º do ECA, já houve casos em que o STJ mitigou referida regra. Foi veiculado no informativo 608 do Tribunal da Cidadania que no caso de adoção unilateral, a irrevogabilidade prevista no art. 39, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser flexibilizada no melhor interesse do adotando. Ex.: filho adotado teve pouquíssimo contato com o pai adotivo e foi criado pela família de seu falecido pai biológico.

Toda a adoção decorre de processo judicial, não se admitindo, portanto, adoção extrajudicial. Ademais, é vedada a adoção por procuração.

Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. A finalidade de tal regra é buscar facilitar a adoção desses que, usualmente, são grupos com chances remotas de serem adotados.

4.3.2. ESPÉCIES DE ADOÇÃO

A doutrina trata de algumas espécies de adoção. São elas:

a) Adoção conjunta ou bilateral: quando existe o rompimento do vínculo de filiação com o pai e com a mãe. O casal se apresenta como postulante à adoção. O ECA exige que o casal esteja casado ou em união estável. Há, contudo, exceções. É possível que ex-casal, já divorciado ou com a união estável dissolvida, realize a adoção conjunta, desde que: haja prévio acordo sobre a guarda e um regime de visitação; o estágio de convivência do adotando tenha se iniciado antes do fim da sociedade conjugal ou união estável; e seja comprovado que o adotando guarda vínculo de



afetividade e afinidade com aquele que não vá deter a guarda. O STJ já decidiu que não há óbice à adoção feita por casal homoafetivo, desde que a medida represente reais vantagens ao adotando.

Já houve caso em que o STJ relativizou a exigência do § 2º do art. 42 (casamento/união estável) e permitiu a adoção por duas pessoas que não eram casadas nem viviam em união estável. No caso, eram dois irmãos (um homem e uma mulher) que criavam um infante há alguns anos e, com ele, desenvolveram relações de afeto (REsp 1.217.415-RS).

Sustentou-se que a interpretação do ECA deve atender ao princípio do melhor interesse do menor. Assim, decidiu-se que conceito de núcleo familiar estável não deve ser restrito às formas tradicionais de família. No caso, entendeu que o núcleo familiar formado pelos irmãos postulantes da adoção atendia os fins legais, que é assegurar ao adotando a inserção em um núcleo familiar no qual pudesse desenvolver relações de afeto, aprender valores sociais, receber e dar amparo nas horas de dificuldades, entre outras necessidades materiais e imateriais supridas pela família. A interpretação literal do dispositivo seria solução anacrônica, e está em desacordo com os objetivos do ECA.

b) Adoção unilateral: quando um dos cônjuges ou companheiros adota o filho do outro cônjuge ou companheiro. Neste caso, o adotado mantém o vínculo com o cônjuge ou companheiro do adotante, ou seja, existe a manutenção do vínculo de adoção com um dos genitores.

c) Adoção póstuma: levada a efeito ainda que o adotante venha a morrer no curso do procedimento. Para tanto, exige-se que tenha havido manifestação inequívoca do adotante da vontade de adotar. Os efeitos da adoção retroagem à data do óbito.

De acordo com o STJ, utilizam-se as mesmas regras para a comprovação da filiação socioafetiva para que se afira a manifestação inequívoca da vontade de adotar, ou seja, tratamento do adotante como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição (RESP 1.326.728/RS).

Consoante a literalidade do ECA, não é possível a adoção póstuma (adoção nuncupativa) quando a morte do adotante ocorreu antes do início do processo de adoção, já que o art. 42, §6º fala em falecimento no “curso do procedimento”. Mas segundo o STJ, é possível.

No mesmo julgado em que admitiu a adoção conjunta de uma criança por dois irmãos (REsp 1.217.415-RS), admitiu também a adoção póstuma mesmo tendo a morte de um dos adotantes ocorrido antes do início do processo de adoção. Entendeu que se o adotante, ainda em vida, manifestou de forma inequívoca a vontade de adotar a criança, poderá ocorrer a adoção *post mortem* mesmo que não tenha iniciado o procedimento de adoção quando vivo. Lembre-se de que manifestação inequívoca da vontade de adotar é: a) o adotante trata o menor como se fosse seu filho; b) conhecimento público dessa condição, ou seja, a comunidade sabe que o adotante considera o menor como se fosse seu filho.

d) Adoção intuito personae: é a hipótese de adoção em que os pais biológicos vão influenciar diretamente na escolha da família substituta. Os pais decidem que não querem o poder familiar e vão entregar o filho à adoção, mas ajudarão no processo de escolha da família substituta. A Lei 12010/09, visando evitar manipulações, favorecimentos indevidos e burla no cadastro de adoção, restringiu essa espécie de adoção, permitindo-a somente nos casos disposto no art. 50, §13 do ECA. Nada obstante, o STJ também tem admitido a não observância da ordem cronológica dos cadastrados para adotar, o que, em alguma medida, seria uma adoção *intuito personae* (informativo 508), conforme veremos adiante.

e) Adoção internacional: quando o postulante é domiciliado fora do Brasil. Este postulante poderá ser brasileiro e a adoção ser internacional

f) Adoção à brasileira: quando o sujeito comete o crime de registrar filho de outrem como próprio, tipo penal este previsto no art. 242 do CP. Nada obstante, se passaram muitos anos da adoção à brasileira, o vínculo será irrevogável, pois já existente paternidade socioafetiva. Todavia, o STJ entendeu que o filho tem direito de desconstituir a denominada “adoção à brasileira” para fazer constar o nome de seu pai biológico em seu registro de nascimento, ainda que preexistia vínculo socioafetivo de filiação com o pai registral (Informativo 577).



4.3.3. QUEM PODE ADOTAR E SER ADOTADO

O ECA prevê algumas regras a respeito de quem pode adotar. Em primeiro lugar, deve o adotante ter, ao menos, 18 anos completos e a diferença de idade entre adotante e adotado deve ser de pelo menos 16 anos, para que, de fato, haja a aparência de 2 gerações diferentes: pais e filhos.

De acordo com a doutrina majoritária, não pode ser o nascituro adotado. Aliás, as regras de entrega de criança recém-nascida à adoção parecem deixar evidente tal posição, uma vez que o consentimento da genitora deve ser confirmado após o nascimento mediante seu encaminhando à justiça da infância, onde contará inclusive com apoio da equipe multidisciplinar do juízo. Não bastasse isso, é obrigatório o estágio de convivência na adoção (com exceção de casos dispostos no ECA), o que não é factível no caso do nascituro.

Não é permitida a adoção por irmãos ou por ascendentes, nada obstante, já houve casos em que o STJ relativizou a aplicação destas regras em face do melhor interesse da criança.

Se o adotando for menor de 18 anos, o processo tramitará perante a Vara da Infância e Juventude, aplicando-se o ECA no que couber, ao passo que, se for maior de 18 anos, o processo de adoção irá correr na Vara da Família, salvo se a maioria for atingida durante o curso do processo da Vara da Infância e o adotando já estava sob guarda ou tutela dos adotantes, caso em que continuará tramitando nesta vara.

Não se aplica a exigência de consentimento dos pais ou do representante legal do adotando caso este seja maior de 18 anos. Ademais, o consentimento dos pais é dispensado, ainda que quando menor de idade, caso ele tenha sido destituído do poder familiar.

Não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado enquanto não prestar contas de sua administração e saldar o seu alcance. Após, poderá adotar.

4.3.4. REQUISITOS PARA ADOÇÃO

O ECA também estabelece alguns requisitos para a adoção. São eles:

a) Consentimento dos pais e do adolescente: é preciso que os pais biológicos deem o seu consentimento (art. 45). Tal consentimento é dispensado quando os pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar (ex.: morte dos pais, perda do poder familiar etc.). Como o poder familiar é extinto com a maioria, não se exigirá consentimento dos pais para a adoção do maior de idade. Se o adotando for adolescente, é indispensável o seu consentimento para fins de perfectibilizar a adoção. Em sendo criança, é recomendado que seja ouvida, desde que possível.

b) Estágio de convivência: trata-se do período em que o adotando e adotante passam por uma convivência, acompanhado e relatado por equipe interprofissional do juizado. O prazo máximo do período de convivência é de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso, e pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Esse prazo máximo foi criado pela Lei 13.509/17, e teve por objetivo imprimir celeridade ao processo de adoção. Antes de tal lei, não havia prazo máximo de estágio de convivência.

Se o adotando estiver sob guarda ou tutela do adotante, o período de estágio de convivência poderá ser dispensado. A simples guarda de fato não dispensa estágio de convivência. Se a adoção é internacional, o prazo será de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45, prorrogável por até igual período, uma única vez.

O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe. Ao final do período de convivência, a equipe técnica do juízo emitirá laudo fundamentado, recomendando ou não a adoção.

c) Cadastro Prévio: é necessário elaborar um cadastro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados, bem como um cadastro de pessoas interessadas em adotar, no âmbito de cada comarca. A partir desses cadastros locais, são feitas outras listagens em âmbito



estadual e em âmbito nacional. Fundamento de existência de outros cadastros: aumenta-se a chance da criança ou adolescente ser adotado.

O Cadastro Nacional de adoção é administrado pelo CNJ, podendo ser alimentado pelas Corregedorias Gerais de Justiça e pelos juízes das Varas da Infância e da Juventude.

No momento em que será buscado um adotante, primeiramente, é preciso verificar a possibilidade de ele ser adotado na sua comarca de origem, minimizando-se o trauma da adoção.

Não sendo possível na comarca de origem, a autoridade judiciária inscreverá a criança e o adolescente nos Cadastros Estadual e Nacional.

O cadastro de postulantes domiciliados no exterior (adoção internacional) somente será consultado após o esgotamento das possibilidades de se encontrar postulantes residentes no Brasil.

A manutenção e alimentação desses cadastros são de competência da Autoridade Central Estadual, que normalmente é definida nas leis de organização do poder judiciário estadual, chamadas de Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (CEJAI) ou Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA). Essa autoridade comunica à Autoridade Central Brasileira. A fiscalização dos órgãos e das autoridades centrais é de atribuição do Ministério Público.

Antes de inseridos nos cadastros de postulantes à adoção, aqueles que pretendem adotar deverão passar por preparação psicológica e jurídica, a fim de compreender os efeitos jurídicos da adoção. Além disso, passarão a ter contatos com crianças e adolescentes que estão em acolhimento, seja institucional, seja familiar.

Após superar essas etapas de forma satisfatória, os postulantes terão suas habilitações deferidas pelo juízo da infância, inscrevendo-se o nome dos postulantes no Cadastro de Postulantes à Adoção. Cabe ressaltar que o pedido para inclusão no cadastro de adoção da comarca não demanda capacidade postulatória, ou seja, os pretendentes não precisam de advogado.

Há algumas hipóteses de adoção fora do cadastro de postulantes, vide art. 50, §13º do ECA, sendo hipóteses que acabam se aproximando da chamada adoção *intuito personae*. Existe, todavia, uma condição legal para que ocorra a adoção fora do cadastro de postulantes: adotante domiciliado no Brasil. São hipóteses de adoção fora do cadastro: a adoção for unilateral (adotante que adota filho do seu cônjuge); adoção entre parentes que mantenham vínculos de afetividade e afinidade (pai morreu e o tio adota o sobrinho) e no caso de guarda legal e tutela deferida anteriormente à adoção.

Nesse último caso, é necessário ser criança maior de 3 anos ou adolescente, pois se confere a guarda legal ou a tutela previamente para posteriormente o tutelado ser adotado, desde que prestadas as contas.

A despeito das estritas hipóteses legais, o STJ já decidiu que a observância de tal cadastro não é absoluta, podendo a regra legal deve ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da criança, base de todo o sistema de proteção ao menor (STJ, informativo 508).

4.3.5. ADOÇÃO INTERNACIONAL

O ECA está afinado com a Convenção de Haia, normativa internacional que protege a criança e o adolescente e a cooperação em matéria de adoção internacional. Essa Convenção de Haia foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro (Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999)

Lembre-se, novamente, que a adoção é a única forma de colocação em família substituta residente no exterior. Tanto é que, no curso de um processo de adoção, não pode ser concedida a guarda aos adotantes, pois não se defere guarda ou tutela, nem mesmo em caráter provisório no processo de adoção ao sujeito residente no exterior. Somente será deferida a adoção internacional se forem esgotadas as possibilidades de adoção em família adotiva brasileira residente no país.

A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais, cuja atribuição é residual, e Federal em matéria de adoção internacional. No Brasil, a Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF) é a Secretaria de Direitos Humanos.

Pelo Decreto 3.174/99, compete à Autoridade Central Federal: representar os interesses do Estado brasileiro na preservação dos direitos e das garantias individuais das crianças e dos



adolescentes dados em adoção internacional; receber todas as comunicações oriundas das Autoridades Centrais dos Estados contratantes e transmiti-las, se for o caso, às Autoridades Centrais dos Estados federados brasileiros e do Distrito Federal; cooperar com as Autoridades Centrais dos Estados contratantes e promover ações de cooperação técnica e colaboração entre as Autoridades Centrais dos Estados federados brasileiros e do DF, a fim de assegurar a proteção das crianças e alcançar os demais objetivos da Convenção; tomar as medidas adequadas para: fornecer informações sobre a legislação brasileira em matéria de adoção; fornecer dados estatísticos e formulários padronizados; informar-se mutuamente sobre as medidas operacionais decorrentes da aplicação da Convenção e, na medida do possível, remover os obstáculos que se apresentarem; promover o credenciamento dos organismos que atuem em adoção internacional no Estado brasileiro, verificando se também estão credenciadas pela Autoridade Central do Estado contratante de onde são originários, comunicando o credenciamento ao Bureau Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado; gerenciar banco de dados, para análise e decisão quanto: aos nomes dos pretendentes estrangeiros habilitados; aos nomes dos pretendentes estrangeiros considerados inidôneos pelas Autoridades Centrais dos Estados e DF; aos nomes das crianças e dos adolescentes disponíveis para adoção por candidatos estrangeiros; aos casos de adoção internacional deferidos; as estatísticas relativas às informações sobre adotantes e adotados, fornecidas pelas Autoridades Centrais de cada Estado contratante, dentre outras.

Conforme já estudado, adoção internacional é aquela em que o postulante possui residência habitual fora do Brasil, independentemente da nacionalidade. O art. 51, §1º, ECA prevê os requisitos para a concessão da adoção internacional: necessidade de colocação da criança ou do adolescente em família substituta; esgotamento das tentativas de colocação da criança ou adolescente em família substituta no Brasil; adolescente ter sido consultado sobre a adoção e estar demonstrado que ele se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional.

Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro.

A habilitação para adoção internacional se dará pelo mesmo procedimento da habilitação nacional, com algumas peculiaridades. O procedimento de habilitação irá se iniciar no país de origem, onde os postulantes residem: a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar, deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual.

Deferida a habilitação no país de origem dos adotantes, que demandará um estudo psicossocial, a Autoridade Central do país de acolhida emitirá relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional.

A Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira e o referido relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente.

Ressalte-se que Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.

A Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. Assim sendo, verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento pelos postulantes dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, com validade máxima de 1 ano.

De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela Autoridade Central Estadual.



Em face de sua maior complexidade, a adoção internacional poderá ser intermediada por organismos credenciados, podendo ser nacionais ou estrangeiros. Para tanto, é necessário que a legislação do país de origem admita tais entidades e que elas tenham sido credenciadas no país de origem, junto às autoridades centrais do país, e credenciadas também pela autoridade central brasileira. Destaque-se que o organismo internacional de adoção não poderá ter finalidade lucrativa, já que o legislador considera tal finalidade pecuniária incompatível com os fins sociais da adoção.

O credenciamento do organismo de adoção internacional não é ato jurídico vinculado, mas discricionário, podendo a Autoridade Central Federal limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos, podendo a Autoridade Central Federal solicitar, a qualquer tempo, informações sobre esses organismos credenciados, mais precisamente sobre crianças e adolescentes adotados e sobre os adotantes.

O credenciamento de um organismo tem validade de 2 anos e poderá ser renovado, desde que o pedido de renovação desse credenciamento se dê nos 60 dias anteriores ao vencimento do credenciamento inaugural.

O art. 52, §3º do ECA prevê os requisitos para o credenciamento de organismo internacional de adoção: a) decorrer de um país que tenha ratificado a Convenção de Haia e ser credenciado neste país; b) integridade moral e capacidade profissional; c) não ter fins lucrativos; d) diretores e administradores qualificados, cadastrados pela Polícia Federal e aprovados pela Autoridade Central Brasileira; e) supervisão das atividades do organismo internacional de adoção feita pelas autoridades do país de sua sede e pela autoridade do país de acolhida.

Não necessariamente o país da sede do organismo credenciado será o país de acolhida. Ex.: poderá ocorrer de o país sede do organismo internacional de adoção ser a Alemanha, mas o organismo estar intermediando a adoção de um brasileiro que morará na França, com franceses.

São obrigações dos organismos internacionais de adoção: apresentação de relatório anual de suas atividades à Autoridade Central Federal, apresentação de relatórios pós-adotivos semestrais às Autoridades Centrais Estaduais e Federais, durante o período mínimo de 2 anos e até a juntada de cópia autenticada do registro civil da criança ou do adolescente, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado.

O organismo não poderá representar uma pessoa e nem seu cônjuge, caso elas já estejam representadas por outro organismo internacional de adoção. Ademais, os representantes dos organismos internacionais de adoção não podem manter contato direto com dirigentes de programas de acolhimento institucional e familiar, nem com crianças ou adolescentes passíveis de adoção, sendo o objetivo de tal proibição assegurar a imparcialidade e impedir a violação do princípio do melhor interesse.

O organismo poderá ser descredenciado quando não cumpre os seus deveres, tais como: não apresentação dos relatórios que deve apresentar e cobrança abusiva pela prestação dos serviços. Veja-se que o organismo poderá cobrar pelos serviços prestados, porém sem finalidade lucrativa e sem cobrança abusiva. A constatação de repasse de recursos de organismos internacionais de intermediação a entidades nacionais com essa função ou mesmo a pessoas físicas situadas no Brasil.

4.3.6. EFEITOS DA ADOÇÃO

A sentença que julga a adoção tem natureza constitutiva, altera a situação jurídica da pessoa, criando um vínculo e extinguindo outro. Note-se, porém, que ao mesmo tempo em que é constitutiva, também é desconstitutiva, remanescendo, quanto ao vínculo familiar anterior tão somente os impedimentos matrimoniais, os quais perdurarão. O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será 120 dias, prorrogável por uma única vez pelo mesmo tempo.

Os efeitos da sentença são *ex nunc*, ou seja, não retroagem, a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. Excepcionalmente, poderá retroagir, no caso de adoção póstuma. Neste caso, retroagirá até a data do óbito.



A adoção concede à criança ou ao adolescente o sobrenome do adotante. O prenome também poderá ser modificado se houver pedido do adotando e também no caso de o adotante pedir e o filho, após ser ouvido, concordar, nos termos do art. 28, §1º e 2º do ECA.

Feita a adoção, haverá novo registro de nascimento em cartório no município de residência dos adotantes. As certidões extraídas desse registro não podem conter qualquer observação relativa à adoção.

Em relação à adoção internacional, tem-se que a saída da criança ou do adolescente do território nacional somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença. Ainda, a Autoridade Central Estadual emitirá, ao final do processo de adoção internacional, um atestado de conformidade, requisito imprescindível para que a adoção seja reconhecida no país de acolhida.

Finalmente, consoante dispõe o art. 48 do ECA, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.

5. JURISPRUDÊNCIA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE.

1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família.

2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88.

3. **Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, exsurto, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico.**

4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social.

5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial.

6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1159242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)

Família. Abandono material. Menor. Descumprimento do dever de prestar assistência material ao filho. Ato ilícito. Danos morais. Compensação. Possibilidade. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a condenação em danos morais do pai que deixa de prestar assistência material ao filho. Inicialmente, cabe frisar que o dever de convivência familiar, compreendendo a obrigação dos pais de prestar auxílio afetivo, moral e psíquico aos filhos, além de assistência material, é direito fundamental da criança e do adolescente, consoante se extrai da legislação civil, de matriz constitucional (Constituição Federal, art. 227). Da análise dos artigos 186,



1.566, 1.568, 1.579 do CC/02 e 4º, 18-A e 18-B, 19 e 22 do ECA, extrai-se os pressupostos legais inerentes à responsabilidade civil e ao dever de cuidado para com o menor, necessários à caracterização da conduta comissiva ou omissiva ensejadora do ato ilícito indenizável. Com efeito, **o descumprimento voluntário do dever de prestar assistência material, direito fundamental da criança e do adolescente, afeta a integridade física, moral, intelectual e psicológica do filho, em prejuízo do desenvolvimento sadio de sua personalidade e atenta contra a sua dignidade, configurando ilícito civil e, portanto, os danos morais e materiais causados são passíveis de compensação pecuniária.** Ressalta-se que – diferentemente da linha adotada pela Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.159.242-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi – a falta de afeto, por si só, não constitui ato ilícito, mas este fica configurado diante do descumprimento do dever jurídico de adequado amparo material. Desse modo, estabelecida a correlação entre a omissão voluntária e injustificada do pai quanto ao amparo material e os danos morais ao filho dali decorrentes, é possível a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, com fulcro também no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). (REsp 1.087.561-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/6/2017, DJe 18/8/2017).

A diferença etária mínima de 16 (dezesseis) anos entre adotante e adotado é requisito legal para a adoção (art. 42, § 3º, do ECA). No entanto, a adoção é sempre regida pela premissa do amor e da imitação da realidade biológica, sendo o limite de idade uma forma de evitar confusão de papéis ou a imaturidade emocional indispensável para a criação e educação de um ser humano e o cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. Dessa forma, **incumbe ao magistrado estudar as particularidades de cada caso concreto a fim de apreciar se a idade entre as partes realiza a proteção do adotando, sendo o limite mínimo legal um norte a ser seguido, mas que permite interpretações à luz do princípio da socioafetividade**, nem sempre atrelado às diferenças de idade entre os interessados no processo de adoção. (REsp 1.785.754-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019 - Informativo n. 658)

Ação de guarda proposta contra mãe biológica por casal interessado. Ação de destituição do poder familiar proposta pelo Ministério Público julgada procedente. Posterior sentença de procedência da ação de guarda. Apelação da genitora. Legitimidade reconhecida. Manutenção do laço de parentesco. **A mãe biológica detém legitimidade para recorrer da sentença que julgou procedente o pedido de guarda formulado por casal que exercia a guarda provisória da criança, mesmo se já destituída do poder familiar em outra ação proposta pelo Ministério Público e já transitada em julgado.** (REsp 1.845.146-ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019 – Informativo n. 661)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Menor sob guarda judicial. Dependente econômico. Óbito do instituidor da pensão em data posterior à vigência da MP 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/1997. Manutenção do benefício previdenciário. Proibição de retrocesso. Diretrizes constitucionais de isonomia, prioridade absoluta e proteção integral à criança e ao adolescente. **O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97.** Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. (REsp 1.411.258-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, por



unanimidade, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018. – Recurso Repetitivo – Informativo 619/2018)

ADOÇÃO UNILATERAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. No caso de adoção unilateral, a **irrevogabilidade prevista no art. 39, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser flexibilizada no melhor interesse do adotando**. Restringe-se a controvérsia, exclusivamente, a definir se é possível flexibilizar o preceito do art. 39, § 1º, da Lei n. 8.069/1990, que atribui caráter irrevogável ao ato de adoção, em virtude do enfraquecimento do vínculo afetivo firmado entre adotado e adotante. Inicialmente, consigna-se que a adoção unilateral, ou adoção por cônjuge, é espécie do gênero adoção, que se distingue do caudal comum por possuir elementos que lhe são singulares, sendo o mais acentuado, a ausência de ruptura total entre o adotado e os pais biológicos, porquanto um deles permanece exercendo o poder familiar sobre o menor que será, após a adoção, compartilhado com o cônjuge adotante. Ela ocorre a partir do óbito de um dos ascendentes biológicos, após a destituição do poder familiar de um deles ou mesmo na ausência de pai registral. Tal adoção irá substituir, para todos os efeitos, a linha biológica originária do adotado e ocorre independentemente de consulta ao grupo familiar estendido, cabendo tão-só ao cônjuge supérstite decidir sobre a conveniência, ou não, da adoção do filho pelo seu novo cônjuge/companheiro. É de se salientar que hoje, procura-se prioritariamente colocar o menor como o foco central do processo de adoção, buscando-se, em prol dele, a melhor fórmula possível de superação da ausência parcial, ou total dos ascendentes biológicos. Essa opção é claramente expressa no artigo 43 do ECA (*a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.*), que pela sua peremptoriedade e capacidade de se sobrepor aos outros ditames relativos à adoção, pode ser considerada verdadeira norma-princípio. Assim, os elementos balizadores e constitutivos da adoção unilateral, bem como as prerrogativas do cônjuge supérstite de autorizar a adoção unilateral de seu filho, e mesmo a própria declaração de vontade do adotando, podem ser superados ou moldados em nome da inexistência de reais vantagens para o adotando no processo de adoção. O princípio do interesse superior do menor, ou melhor interesse, tem assim, a possibilidade de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação judicial da situação concreta onde se analisa. Em complemento a esse raciocínio, fixa-se que a razão de ser da vedação erigida, que proíbe a revogação da adoção é, indistintamente, a proteção do menor adotado, buscando colocá-lo a salvo de possíveis alternâncias comportamentais de seus adotantes, rupturas conjugais ou outras atitudes que recoloquem o menor adotado, novamente no limbo sócio emocional que vivia antes da adoção. Sob esse diapasão, observa-se que há espaço para, diante de situações singulares onde se constata que talvez a norma protetiva esteja, na verdade, vulnerando direitos do seu beneficiário, ser flexibilizada a restritiva regra fixada no art. 39 § 1º, do ECA. (REsp 1.545.959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 6/6/2017, DJe 1/8/2017. Informativo 608/2017)

DIREITO CIVIL. ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR DE IDADE SEM O CONSENTIMENTO DE SEU PAI BIOLÓGICO. Ante o abandono do adotando pelo pai biológico e o estabelecimento de relação paterno-filial (vínculo afetivo) entre adotante e adotando, a adoção de pessoa maior de idade não pode ser refutada sem apresentação de justa causa por parte do pai biológico. Após a revogação do art. 1.621 do CC pela Lei 12.010/2009, o ECA passou a reger, no que couber, a adoção de maiores de dezoito anos (art. 1.619 do CC). Nesse passo, convém esclarecer que o *caput* do art. 45 do referido Estatuto dispõe que "a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando". Por sua vez, o § 1º do mencionado dispositivo do ECA preceitua que "o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais

sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar". Ciente disso, importa destacar que o poder familiar extingue-se pela maioria (art. 1.635 do CC), pois "os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores" (art. 1.630 do CC). Portanto, considerando-se que o direito em discussão está envolto à defesa de interesse individual e disponível de pessoa plenamente capaz e que o exercício da autonomia da vontade do maior de dezoito anos não depende mais do consentimento de seus pais ou de seu representante legal, não se aplica o art. 45 do ECA à adoção de maior de idade. Além disso, o art. 48 do ECA dispõe que "o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos". Desse modo, sendo possível ao filho maior buscar suas origens biológicas, partindo-se de uma interpretação teleológica desse dispositivo, é possível reconhecer também o direito de afastá-las por definitivo, por meio de adoção quando ele atingir a maioria. (REsp 1.444.747-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/3/2015, DJe 23/3/2015. – Informativo 558/2015)

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO DE ADOÇÃO CONJUNTA TRANSMUDAR-SE EM AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL POST MORTEM. **Se, no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir do pedido e outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de adotar unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o pedido de adoção unilateral post mortem.** (REsp 1.421.409-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016. – Informativo n. 588)

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HIPÓTESE DE ADOÇÃO DE DESCENDENTE POR ASCENDENTES. **Admitiu-se, excepcionalmente, a adoção de neto por avós, tendo em vista as seguintes particularidades do caso analisado:** os avós haviam adotado a mãe biológica de seu neto aos oito anos de idade, a qual já estava grávida do adotado em razão de abuso sexual; os avós já exerciam, com exclusividade, as funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento; havia filiação socioafetiva entre neto e avós; o adotado, mesmo sabendo de sua origem biológica, reconhece os adotantes como pais e trata a sua mãe biológica como irmã mais velha; tanto adotado quanto sua mãe biológica concordaram expressamente com a adoção; não há perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; e não havia predominância de interesse econômico na pretensão de adoção. (REsp 1.448.969-SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/10/2014. – Informativo n. 551)

QUESTÕES

1- Juiz de Direito – TJCE/CESPE (2018) Considerando o disposto no ECA e a jurisprudência do STJ acerca da adoção unilateral, assinale a opção correta.

- a) Nessa espécie de adoção, há ruptura total da relação entre o adotado e seus pais biológicos, substituindo-se a linha biológica originária do adotado para todos os efeitos, inclusive os civis.
- b) Caso o poder familiar de um dos genitores do adotando seja destituído, será necessária consulta ao grupo familiar estendido, a fim de a adoção unilateral ser concluída.
- c) Mesmo depois de transitada em julgado a sentença de adoção unilateral, é possível a sua revogação em razão de arrependimento do adotado, em favor do melhor interesse dele.
- d) O objeto da adoção unilateral é o menor completamente desassistido, cuja percepção de pertencimento familiar é impactada pelo próprio processo de adoção.
- e) O adotado unilateralmente por cônjuge pode, ao atingir a maioria, requisitar a revogação da adoção por não mais ter interesse nela.



2- Defensor Público, DPE-SC/FCC (2017) Sem considerar a interpretação mais flexível eventualmente dada pela jurisprudência aos dispositivos que regem o instituto da adoção, é regra hoje prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente que

- a) a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer antes do início do procedimento.
- b) para adoção conjunta, é indispensável, no mínimo, que os adotantes sejam ou tenham sido casados civilmente ou que mantenham ou tenham mantido união estável.
- c) se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, rompem-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.
- d) a adoção internacional pressupõe a intervenção de organismos nacionais e estrangeiros, devidamente credenciados, encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional.
- e) a guarda de fato autoriza, por si só, a dispensa do estágio de convivência.

3- Juiz de Direito –TJSC/FCC (2017) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são regras que devem ser observadas para a concessão da guarda, tutela ou adoção,

- a) o consentimento do adolescente, colhido em audiência, exceto para a guarda.
- b) a opinião da criança que, sempre que possível, deve ser colhida por equipe interprofissional e considerada pela autoridade judiciária competente.
- c) a prevalência das melhores condições financeiras para os cuidados com a criança ou adolescente.
- d) a prioridade da tutela em favor de família extensa quando ainda coexistir o poder familiar.
- e) a preferência dos pais ou responsável por algum dos eventuais pretendentes à guarda, tutela ou adoção.

4- Juiz de Direito – TJMS/FCC (2020) Maria, não desejando ficar com seu filho João, que não tem pai registral, entrega-o a um casal de amigos, Marta e Vicente, os quais desejam adotá-lo. Segundo previsão expressa de lei,

- a) Maria, Marta e Vicente, estando de acordo, poderão requerer ao Cartório de Registro Civil o reconhecimento de Marta e Vicente como pais socioafetivos de João, com prejuízo da filiação registral originária.
- b) Marta e Vicente não poderão adotar João, exceto se já tiverem sido previamente habilitados a adotar e incluídos no cadastro de adoção.
- c) Maria pode perder, por decisão judicial, o poder familiar sobre o filho por tê-lo entregue de forma irregular a terceiros para fins de adoção.
- d) Marta e Vicente, ainda que não habilitados, têm prioridade para a adoção da criança porque foram indicados pela própria genitora de João como adotantes de sua preferência.
- e) sendo do interesse de João, sua adoção pode ser concedida a Marta e Vicente, os quais sujeitam-se, em tese, às penas do crime de burla de cadastro adotivo.

5- Juiz de Direito – TJRJ/Vunesp (2019) Pedro, criança de 4 anos, com pais desconhecidos, vive em uma instituição de menores abandonados. Em razão de sua aparência física (branco e de olhos claros) despertou o interesse na adoção por um casal alemão. Entretanto, outro casal brasileiro, regularmente cadastrado para adoção na forma da lei, também manifestou interesse em adotar Pedro. Acerca do caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- a) Deverá ser dada preferência ao casal estrangeiro, tendo em vista que a adoção irá representar a Pedro a possibilidade de ser cidadão da comunidade europeia, o que significa uma manifesta vantagem em seu interesse.



- b) Deverá ser deferida a adoção ao casal que melhor apresentar condições de satisfazer os interesses da criança.
- c) Deverá ser dada preferência ao casal brasileiro, se este apresentar perfil compatível com a criança.
- d) Pedro deverá previamente ser inserido no programa de apadrinhamento e, apenas no caso de insucesso deste, poderá ser deferida a adoção, com preferência ao casal brasileiro.
- e) Caso seja deferida a adoção ao casal alemão, a saída de Pedro do território nacional somente poderá ocorrer a partir da publicação da decisão proferida pelo juiz em primeira instância, mesmo sem o trânsito em julgado, vedada a concessão de tutela provisória.

GABARITO

- 1. C
- 2. B
- 3. B
- 4. C
- 5. C



CAPÍTULO 4 – DIREITOS FUNDAMENTAIS: PARTE 3

1. DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Um dos mais relevantes direitos para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e do próprio desenvolvimento do país é o direito à educação. Na leitura de JOSÉ AFONSO DA SILVA, conjugando-se o art. 205 da CF, que prevê a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, com o art. 6º, tem-se a educação como um direito fundamental, que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

Aliás, as modernas correntes pedagógicas inclusive entendem que a educação sequer se resume à educação formal, mas também abrange um aprendizado que se inicia desde o berço, compreendendo um dever dos pais, familiares e da sociedade como um todo de educar o infante.

Assim, reconhecido o direito fundamental dos infantes à educação, o art. 54 do ECA destrincha o conteúdo de tal direito, estabelecendo que deve ser dada igualdade de condições para acesso e permanência na escola; direito de ser respeitado pelos educadores; contestar critérios avaliativos mediante recursos; organização e participação em entidades estudantis; acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Aos pais de alunos, por sua vez, é direito ter ciência do processo pedagógico e de participar das propostas educacionais.

Nesse ponto, cabe destacar que a garantia de acesso e de permanência significa que todos têm direito de ingressar na escola, sem distinção de qualquer natureza, não podendo ser obstada a permanência de quem teve acesso. O acesso não pode ser impedido a qualquer criança ou adolescente. Todos possuem o direito à matrícula em escola pública ou particular. Existindo a recusa em razão de preconceito de raça, caracteriza-se, neste caso, uma infração penal.

O artigo 6º da Lei nº. 7716/89 tipifica como crime recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, cominando ao comportamento uma pena de privação de liberdade de três a cinco anos.

Acerca do tema, há defensores de que o direito e garantia de permanência na escola impede a exclusão ou a transferência compulsória por ato unilateral da escola. De outro lado, há defensores da possibilidade da transferência compulsória de alunos da rede pública de ensino, mas desde que o estabelecimento de ensino tome algumas cautelas, tais como a decisão seja tomada por órgão colegiado da escola, haja prévia oportunidade de manifestação/defesa do aluno e seus responsáveis e não sejam recomendáveis e nem suficientes outras medidas sancionatórias lícitas a serem tomadas pela escola, a depender de suas normas internas e normativas da Secretaria Estadual de Educação, tais como advertência verbal, advertência por escrito junto aos responsáveis legais pelo aluno; a suspensão da frequência às atividades da classe, por período determinado; a reparação do dano causado involuntariamente ao patrimônio público ou particular; a retratação verbal ou escrita; a mudança de turma e a mudança de turno.

Ou seja, a transferência compulsória deve ser medida extrema, adotável somente se outras medidas não surtirem efeito. Ademais, deve-se levar em consideração o período em que é realizada a transferência compulsória, caso se opte por de fato realizá-la, evitando-se que a transferência cause prejuízos do ponto de vista pedagógico e educacional ao aluno. Por exemplo, a transferência não deve ocorrer em período de realização de provas para que não haja prejuízos quanto à avaliação do aluno.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já teve a oportunidade de decidir pela licitude da transferência de alunos considerados indisciplinados, sem considerar que isso afrontasse o direito de acesso e permanência na escola. Este parece ser o posicionamento mais sensato, desde que haja respeito ao devido processo legal.

No que tange aos deveres do Estado, dispõe o ECA que o Ensino fundamental, obrigatório e gratuito deve ser assegurado a todos, inclusive para aquelas crianças e adolescentes que não tiveram acesso na idade própria. Também de dever do estado fornecer atendimento em creche e pré-escola



às crianças de 0 a 5 anos de idade (Lei 13.306/16). Quanto ao ensino médio, é prevista a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade. A extensão da obrigatoriedade foi implementada por meio da Lei nº 12.796/2013, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº9394/1996), estabelecendo a educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade.

Cabe lembrar que a Constituição Federal determina que os Municípios atuarão prioritariamente na educação infantil (creche e pré-escola) e no ensino fundamental (1º ao 9º ano), ao passo que os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio (antigo colegial). A União, por sua vez, organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Já no que atine aos níveis mais elevados do ensino, assim considerado o acesso ao nível superior, apenas dispõe o ECA que será garantido conforme a capacidade de cada um.

Em atenção às pessoas com deficiência, o atendimento educacional especializado deve ser feito, preferencialmente na rede regular de ensino, para que possam ter contato com os demais alunos, privilegiando-se assim a educação inclusiva.

Também deve ser assegurada oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.

Para fins de apoiar a frequência e manutenção na escola, é dever também o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação (merenda escolar) e assistência à saúde. Em face da obrigatoriedade do ensino médio, consoante alterações promovidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode-se interpretar que esse amparo também deve ser fornecido ao ensino médio.

O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Tal responsabilidade pode se dar no campo administrativo e também cível, mediante ação civil pública e ação de improbidade.

Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.

Recentemente, o STF decidiu pela vedação do homeschooling, a chamada educação em casa ou ensino domiciliar, em razão da ausência de lei a disciplinar a matéria. Tratou-se do Tema 822. Assim sendo, é obrigação dos pais matricular os filhos na rede regular de ensino, não sendo permitida a educação em casa, sem que a criança frequente escola. Havendo o descumprimento desta regra, poderá haver o crime de abandono intelectual (art. 246 do CP).

Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. A omissão da comunicação ao Conselho Tutelar em casos de maus-tratos caracterizará infração administrativa do dirigente do estabelecimento educacional.

Também é dever da instituição de ensino, além de clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas.

Por fim, deve-se destacar o entendimento do STJ no sentido de que não se trata de discricionariedade do Poder Executivo atender à demanda educacional e sim de verdadeira obrigação, cabendo inclusive ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, não cabendo sequer a alegação de reserva do possível pelo ente público.

No mais, quis o legislador que o ensino tivesse como parâmetro o contexto cultural que circunda o estudante menor de 18 anos, respeitando-se as diferenças regionais do Brasil. Nesse sentido, dispõe o art. 58 do ECA que no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.

Por conta do direito à cultura, os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.

Uma das formas de viabilizar o acesso à cultura aos estudantes se dá por intermédio da Lei nº 12933/2013, a chamada Lei da Meia Entrada, que assegura aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

2. DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO

Em princípio, cabe destacar que somente ao adolescente é destinado o direito ao trabalho, eis que crianças não estão autorizadas a trabalhar.

Diz o art. 7º, XXXIII da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que é direito do trabalhador a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Desta feita, a Constituição permitiu o trabalho a partir dos 16 anos de idade, ressalvado o caso do jovem aprendiz, que é admitido a partir dos 14 anos de idade. Assim sendo, o art. 60 do ECA contraria o disposto na CF, a partir de sua alteração realizada em 1998, estando o seu conteúdo tacitamente revogado.

Sobre a aprendizagem, esta pode ser definida como a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Obedecerá aos seguintes princípios, como forma de proteger o trabalho aprendiz: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; horário especial para o exercício das atividades, assegurada a bolsa de aprendizagem.

No mais, ao adolescente que trabalha são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, feitas algumas ressalvas: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Por esta razão, existem algumas proibições que visam à proteção do adolescente, tais como a vedação ao trabalho noturno realizado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte; vedação ao trabalho perigoso, insalubre ou penoso, vedação ao trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; vedação ao trabalho realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Questão peculiar diz respeito aos atores mirins, ou seja, crianças menores de 14 anos que fazem papéis em novelas da televisão ou comerciais. Nesse caso, é necessária autorização expressa do Juízo da Infância e da Juventude (art. 149, II, ECA), mediante alvará a ser expedido por este juízo, qual levará em conta a peculiaridade da situação, adequando este trabalho ao cotidiano do ator infanto-juvenil, a fim de não prejudicar o seu desenvolvimento.

O trabalho não pode ser prejudicial à formação moral da criança ou adolescente e se mostrar essencial à subsistência do ato infanto-juvenil e da sua família.

Há posição doutrinária no sentido de que a hipótese dos atores mirins não é de trabalho, e sim de participação em teatro, televisão ou similar.

3. JURISPRUDÊNCIA

CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL RELACIONADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE DA CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA NA PRESTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE LEI FORMAL, EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, PARA REGULAMENTAR O ENSINO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A educação é



um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). No caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os titulares desse direito indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade escolar. 2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos. 3. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de unschooling radical (desescolarização radical), unschooling moderado (desescolarização moderada) e homeschooling puro, em qualquer de suas variações. 4. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou “por conveniência circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de matérias acadêmicas, a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder Público; bem como as demais previsões impostas diretamente pelo texto constitucional, inclusive no tocante às finalidades e objetivos do ensino; em especial, evitar a evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo, por meio de ampla convivência familiar e comunitária (CF, art. 227). 5. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese (TEMA 822): “**Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira**”.

São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. STF. Plenário. ADPF 292/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/8/2018 (Informativo n. 909).

É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. STF. Plenário. ADC 17/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/8/2018 (Informativo n. 909).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Persiste a aplicação da Súmula 7/STJ, tendo em vista que o exame do atendimento ou não dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela demanda, em regra, a reavaliação dos elementos fático-



probatórios dos autos, o que não é cabível na via estreita do Recurso Especial. 3. **A jurisprudência desta Corte Superior, atenta à prioridade constitucional (art. 227 da CF/1988) e legal (arts. 4o. e 53 do ECA) na tutela dos direitos da criança e do adolescente, já se manifestou repetidas vezes quanto à possibilidade de determinar ao Poder Público, judicialmente, a realização de matrícula de criança em creche.** (AgRg no AREsp 794213 / RJ, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJE 25/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOLVIDA PELA CORTE DE ORIGEM COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇAS EM CRECHE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 256, e-STJ, grifei): "(...) a Constituição Federal dispôs expressamente que o acesso ao ensino é direito público subjetivo que "é o direito exigível, é o direito integrado ao patrimônio do titular, que lhe dá o poder de exigir sua prestação - se necessário, na via judicial (...) oponível ao Poder Público, direito que cabe ao Estado satisfazer" (AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextuai à Constituição. 5 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 794/795). A educação infantil é direito social fundamental e não mera norma programática. Por isso, impõe uma atuação positiva e prioritária do Estado para a sua efetivação, independentemente da idade da criança". 2. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia utilizando-se de fundamentos eminentemente constitucionais. Tem-se, assim, que refoge à competência do STJ a apreciação da matéria aludida, pois de cunho eminentemente constitucional, cabendo tão somente ao STF o exame de eventual ofensa. 3. Não se pode conhecer da irrisignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 4. **O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas. Precedentes do STJ e do STF.** 5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. 7. Se é certo que ao Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à Administração Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das funções do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional e legal dos poderes e deveres do Administrador, exigindo-se, de um lado, cumprimento integral e tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à esfera da chamada competência discricionária, respeito ao due process e às garantias formais dos atos e procedimentos que pratica. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1771912, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 11/12/2018).

O Poder Judiciário não pode substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de



ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade. STJ. 1ª Turma. REsp 1412704/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/12/2014.

QUESTÕES

1- Promotor de Justiça – MPPR/MPPR (2019) Nos termos do que expressamente estabelece a Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
- b) É dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
- c) É assegurado às crianças e aos adolescentes o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
- d) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.
- e) Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que prevalecem as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento profissional e produtivo do educando.

2- Juiz de Direito – TJSC/CEBRASPE (2019) Com relação ao direito fundamental das crianças à educação, julgue os itens a seguir à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do entendimento dos tribunais superiores.

I - Direito social fundamental, a educação infantil constitui norma de natureza constitucional programática que orienta os gestores públicos dos entes federativos.

II - Em se tratando de questões que envolvam a educação infantil, poderá o juiz, ao julgá-las, sensibilizar-se diante da limitação da reserva do possível do Estado, especialmente da previsão orçamentária e da disponibilidade financeira.

III - O Poder Judiciário não pode impor à administração pública o fornecimento de vaga em creche para menor, sob pena de contaminação da separação das funções do Estado moderno.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item II está certo.
- d) Apenas os itens I e III estão certos.
- e) Apenas os itens II e III estão certos.

3- Juiz de direito – TJRJ/Vunesp (2019) Assinale a alternativa que revela o atual entendimento do STJ sobre a interpretação do corte etário para ingresso de crianças na educação básica.



- a) Decidiu que não é dado ao Judiciário substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade.
- b) Foi declarada a legalidade dessa medida, contanto que tal limitação seja feita por Lei Municipal, uma vez que compete a esse ente federativo legislar sobre a matéria.
- c) Afirmou que os órgãos administrativos têm plena liberdade para fixarem, dentro dos critérios das regiões em que atuam, as faixas etárias que melhor expressarem as necessidades da comunidade, tendo em vista que a legislação federal que tutela o assunto não admite a intervenção judicial nesse sentido, por ser matéria administrativa.
- d) Determinou que é papel do Poder Judiciário suprir as omissões legislativas sobre o tema, e definiu que o acesso ao Ensino Infantil se dá aos 4 anos de idade e ao Ensino Fundamental aos 6 anos, completados até 31 de março do ano da matrícula.
- e) Declarou a inconstitucionalidade de legislação estadual que trate desse recorte, informando que compete ao legislador municipal e federal legislar sobre o tema, por se tratar de ensino fundamental e não médio ou superior.

GABARITO

1. E
2. A
3. A



CAPÍTULO 5 – DA PREVENÇÃO

1. NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE PREVENÇÃO

A partir da concepção de que crianças e adolescentes devem ser sujeitos de direitos surgiu a doutrina da proteção integral. Nessa senda, o legislador outorgou um cuidado especial de proteção a esses sujeitos em peculiar condição de desenvolvimento.

Prevenção é o ato de prevenir, ou seja, tratar de evitar a ameaça ou a própria violação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O art. 70 inicia o título da prevenção no ECA, afirmando que é dever de todos prevenir transgressões aos direitos dos infantes. Por todos, entenda-se o Estado, a sociedade e a família.

Nesse sentido, o poder público deve atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações:

- A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos;
- A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
- A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
- O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente;
- A inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo;
- A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência.

De forma a dar concretude à prevenção contra maus-tratos e violação de direitos de crianças e adolescentes, as entidades públicas e privadas que trabalhem diretamente com lazer, cultura, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços voltados à infância devem contar com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra infantes. São igualmente responsáveis pela comunicação de maus tratos as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes

A violação de normas de prevenção ensinará os responsáveis, sejam eles pessoa física ou jurídica, na forma prevista no ECA.



2. PREVENÇÃO ESPECIAL REFERENTE À INFORMAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTES, DIVERSÕES E ESPETÁCULOS (ART. 74 A 80)

Explica VALTER KENJI ISHIDA que “dentro da doutrina da proteção integral, fez-se uma divisão entre a prevenção geral e a prevenção especial. A diferença clara entre as duas está na estipulação de regras gerais na prevenção geral e na especificação de regras nesta última”²³.

A prevenção especial inicia-se tratando da regulamentação do acesso de infantes a diversos e espetáculos públicos. Com efeito, o Poder Público tem o dever de regulamentar o acesso de menores a esses tipos de eventos, qualificando sua natureza, indicando a faixa etária recomendada, localização e horário de exibição recomendados.

Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. São exemplos de diversões e espetáculos: teatros, cinemas, parques de diversão, parques temáticos em geral, circos, dentre outros. O mesmo vale para programas de rádio e televisão.

As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Os demais terão acesso conforme a classificação adequada à sua faixa etária.

Nota-se a necessidade de harmonizar direitos em aparente rota de colidência, quais sejam: a liberdade de expressão e informação de uma lado, e de outra a proteção integral e a necessidade de proteger as crianças e adolescentes.

Nesse campo, o STF entendeu ser inconstitucional a expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art. 254 do ECA. Este dispositivo diz que seria infração administrativa a conduta de

transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.

Dessa forma, o Estado não pode determinar que os programas somente possam ser exibidos em determinados horários. Isso seria uma imposição, o que é vedado pelo texto constitucional por configurar censura. O Poder Público pode apenas recomendar os horários adequados. A classificação dos programas é indicativa (e não obrigatória) (Inf. 837).

O STF entendeu que não é apenas o poder público que pode determinar o que seja inadequado ou adequado à criança e ao adolescente, devendo ser analisado tal situação com base também no que a família entender adequado, que é a base da sociedade. O poder público faz a sua parte quando não recomenda certa programação, mas impedir que a criança assista certa programação compete à família.

Se houver um desrespeito ou abuso por parte da emissora, violando o direito à programação sadia, ela poderá ser responsabilizada, consoante já decidiu o STJ, mas não se pode determinar o horário que deverá haver certa programação, sob pena de haver censura.

Os proprietários e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. As fitas exibirão, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Rememore-se que o ECA é de 1990, época em que era comum a locação de fitas cassete.

Atualmente, pode-se fazer uma leitura contemporânea, pensando em locação de DVDs e *bluray*, bem como de arquivos de vídeo em sites, os quais devem alertar a faixa etária recomendável.

²³Valter Kenji Ishida. *Estatuto da criança e do adolescente – Doutrina e jurisprudência*. Salvador: JusPodium, 2019. Pg. 268 e 269.



As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. As capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas serão protegidas com embalagem opaca. Recentemente, decidiu o STJ que tal regra, prevista no art. 78 do ECA, também se aplica às transportadoras de revistas e distribuidoras.

As revistas destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Por fim o art. 80 prevê que os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público.

3. PREVENÇÃO À VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

O direito do consumidor, de forma geral, preocupa-se com a segurança e saúde das pessoas, destinatárias de produtos e serviços. Nada obstante, tolera-se o uso de certos produtos, notoriamente nocivos, mas desde que haja a devida informação. É o caso de cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo.

No âmbito da infância, por sua vez, o acesso a certos produtos e serviços é mais restrito, diante da peculiar situação de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por essa razão, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

I - armas, munições e explosivos; II - bebidas alcoólicas; III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; V - revistas e publicações a que alude o art. 78 (material erótico, inadequado, impróprio); VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

Diga-se que a entrega de bebida alcoólica ou, sem justa causa, de produtos que causem dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes, numa das formas previstas no art. 243 do ECA, configura crime. Antes da Lei nº 13106/2015, a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos era considerada contravenção penal. Atualmente é conduta é considerada crime.

Pelas mesmas razões antes expostas, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

4. AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR

O Brasil é um país continental, dada a enorme extensão de seu território. Aqui temos grandes metrópoles mundiais, tais como São Paulo e Rio de Janeiro. Viajar de um local para outro sozinho e sem assistência pode trazer prejuízos a infantes, daí porque seu trânsito em território nacional e para o exterior é regulado no ECA.

A Lei nº 13.812/2019 promoveu algumas alterações, restringindo a liberdade de trânsito de crianças e adolescentes pelo país. Com efeito, dispõe o art. 83 do ECA, com redação dada pela referida lei, que Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Nada obstante, há exceções em que não se exigirá autorização judicial: a) quando a viagem for para comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; b) quando a



criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: 1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco, 2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.

Em se tratando de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Em qualquer outro caso, demandará autorização judicial mediante expedição de competente alvará ao juízo da infância.

Ainda a respeito do tema de autorização de viagens, a Resolução nº 131/2011 do CNJ estabelece outra hipóteses para dispensa de autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior, nas seguinte situação: quando desacompanhados ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais, com firma reconhecida.

5. JURISPRUDÊNCIA

É inconstitucional a expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art. 254 do ECA (STF. Plenário. ADI 2404/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/08/2016)²⁴.

Direito da Criança e do Adolescente. Infração às normas de proteção à criança e ao adolescente. Revistas que apresentem matéria pornográfica. Art. 78 do ECA. **Exigência de capa opaca, lacrada e com advertência de conteúdo. Comando legal que se estende aos transportadores/distribuidores. Aplicação da multa do art. 257 do ECA. Possibilidade. Máxima eficácia da norma protetiva.** Cinge-se a controvérsia a saber se as exigências insertas no art. 78 do ECA se estendem às transportadoras de revistas para efeito de responsabilização por inobservância da exigência de que as edições ostentem capa lacrada, opaca e com advertência de conteúdo. Embora se pretenda fazer prevalecer a interpretação literal do disposto no art. 78 do ECA, de forma a afastar a responsabilidade de transportadores/distribuidores, é certo que o Estatuto prevê princípios e regras próprias, orientando o Magistrado na sua tarefa de aplicar o direito ao caso concreto, de forma a assegurar à criança e ao adolescente múltiplos direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito à dignidade e ao respeito. O próprio Estatuto, frise-se, traz dispositivo, aduzindo que na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (art. 6º). Nesse passo, atendendo à finalidade da norma que busca a proteção psíquica e moral da criança e do adolescente, preservando o direito ao respeito e à dignidade, considerando, ainda, sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não se pode impor interpretação literal, muito menos restritiva, da norma em análise. Aliás, nenhuma regra pode ser entendida com a sua simples e mera leitura, porque o significado dos seus termos somente adquire efetividade e eficácia no contexto de cada caso concreto controverso. Quando se aplica qualquer regra simplesmente fazendo incidir o seu enunciado, está-se negligenciando a importância insubstituível dos fatos aos quais se destinam e a dos valores éticos que pretendem realizar. Dito de outra forma, o dever imposto pelo art. 78 do ECA que, em caso de descumprimento, resulta na infração do seu art. 257, não se destina apenas às editoras e ao comerciante direto, ou seja, àquele que expõe o produto ao público, abrangendo também os transportadores e distribuidores de revistas, de forma a garantir a máxima eficácia das normas protetivas. É equivocado o entendimento de

²⁴ Ementa completa no capítulo de infrações administrativas



que normas de proteção possam ser flexibilizadas para atender pretensões que lhes sejam opostas, pois isso seria o mesmo que deixar a proteção sob o controle de quem ofende as situações ou as pessoas protegidas. (Resp. 1610989/RJ. Min. Relator Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 20/02/2020 – Informativo n. 666)

É possível a condenação de emissora de televisão ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão da exibição de filme fora do horário recomendado pelo órgão competente. No julgamento da ADI n. 2.404/DF, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "em horário diverso do autorizado", contida no art. 254 do ECA, asseverando, ainda, que a classificação indicativa não pode ser vista como obrigatória ou como uma censura prévia dos conteúdos veiculados em rádio e televisão, haja vista seu caráter pedagógico e complementar ao auxiliar os pais a definir o que seus filhos podem, ou não, assistir e ouvir. **A despeito de ser a classificação da programação apenas indicativa e não proibir a sua veiculação em horários diversos daqueles recomendados, cabe ao Poder Judiciário controlar eventuais abusos e violações ao direito à programação sadia.** O dano moral coletivo se dá *in re ipsa*, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social. Assim, é possível, em tese, a condenação da emissora de televisão ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, quando, ao exibir determinada programação fora do horário recomendado, verificar-se uma conduta que afronte gravemente os valores e interesse coletivos fundamentais. (REsp 1.840.463-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019 – Informativo n. 663)

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA QUE A MÃE POSSA RETORNAR AO SEU PAÍS DE ORIGEM (BOLÍVIA) COM O SEU FILHO, REALIZADO NO BOJO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. **COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPOSTO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2. DISCUSSÃO QUANTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA, NO CASO, DIRETAMENTE, NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.** 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.

1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza civil, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.

2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a lei tem por propósito centralizar



no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.1 É direito da criança e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse direito, em tese, a coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. **Eventual exposição da criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais.**

3. Na espécie, a pretensão da genitora de retornar ao seu país de origem, com o filho que pressupõe suprimento judicial da autorização paterna e a concessão de guarda unilateral à genitora, segundo o Juízo a quo deu-se em plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida.

4. Recurso Especial provido.
(REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017)

QUESTÕES

1- Juiz de Direito – TJAC/Vunesp (2019) Clarisse, mãe de Bernardo, de cinco anos de idade, pretende viajar com o filho, da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, para a Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Comprou passagens aéreas e irão acompanhados da avó paterna. O pai de Bernardo é falecido. No momento do embarque, foi exigida a certidão de óbito, esquecida por Clarisse, que apresentou, além de sua certidão de casamento, a Cédula de Identidade original dos três passageiros, impedidos de embarcar pela companhia aérea. Exigiram a presença do pai, a apresentação da prova do óbito ou a autorização de viagem. A conduta do representante da companhia aérea está

- a) correta, porque não se trata de comarca contígua à residência da criança, ainda que na mesma unidade da Federação, e não está incluída na mesma região metropolitana.
- b) errada, porque foi provado o óbito do pai por duas testemunhas idôneas, o que supre a falta da prova documental ou a autorização de viagem pelo falecido ou judicial.
- c) errada, porque a criança estava acompanhada de ascendente maior, até o terceiro grau, comprovado o parentesco.
- d) correta, porque a criança, ainda que acompanhada de duas pessoas maiores, não tinha autorização expressa do pai com firma reconhecida e não houve comprovação do alegado óbito.

2- Promotor de Justiça – MPPR/MPPR (2017) Assinale a alternativa **correta**, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90):

- a) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.
- b) A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conceder a remissão como forma de exclusão, suspensão ou extinção do processo.



- c) A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações de alimentos, sendo prescindível aquilatar se a criança ou adolescente está em situação de risco.
- d) Compete à autoridade judiciária disciplinar, no âmbito da sua Comarca, as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
- e) Toda criança somente pode ingressar e permanecer nos locais de diversões e espetáculos públicos ou nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável.

3- Juiz de Direito – TJRS/Vunesp (2013) Assinale a alternativa correta quanto à prevenção de ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

- a) É permitido à criança e ao adolescente a realização de jogos em loteria federal ou estadual em casas lotéricas.
- b) Crianças menores de dez anos não poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação de espetáculos ou exibição de filmes desacompanhadas dos pais ou responsável.
- c) A dispensa de autorização para viagem ao exterior de criança ou adolescente, quando acompanhada de ambos os pais, não se estende ao responsável legal.
- d) O acesso de crianças ou adolescentes em estúdios cinematográficos, de teatro, rádio ou televisão dá-se somente por alvará judicial.

GABARITO

1. C
2. A
3. B



CAPÍTULO 6 — POLÍTICA DE ATENDIMENTO E ENTIDADES DE ATENDIMENTO

1. NOÇÕES PRELIMINARES

Inúmeros são os artigos do ECA que atribuem deveres ao Estado, sociedade e família para fazer valer os direitos dos infantes. Depreende-se daí que o sistema de garantias do ECA constitui em um conjunto articulado de pessoas e instituições, havendo atuação tanto no âmbito público quanto no privado para realizar a política de atendimento dos infantes.

Refere o art. 86: que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será feita através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Considera-se Política de atendimento o conjunto de medidas, de ações e de programas, voltados ao atendimento de crianças e adolescentes, sejam públicas ou privadas.

Na elaboração da política de atendimento de infantes, há uma série de diretrizes que devem ser seguidas, assim entendidas como orientações, os valores que devem orientar o poder público no momento de implementar as linhas da ação.

As linhas de ação, por sua vez, são as ações propriamente a serem tomadas, imprescindíveis à construção e desenvolvimento da política de atendimento da criança e do adolescente. Desta feita, quando for implementar as linhas de ação, é necessário lembrar das diretrizes.

As provas de concurso usualmente costumam mesclar ambas para confundir o candidato, valendo uma leitura atenta do conteúdo dos art. 87 e 88 do ECA.

Destaca-se dentre as diretrizes da política de atendimento a municipalização e a criação de conselhos nacionais, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

EDSON SÊDA diz que os conselhos de direitos são a instância em que a população, através das organizações representativas, vai participar e efetivamente vai influenciar na política de atendimento da criança e adolescente, controlar as ações nestes níveis.

Interessante julgado do STF (ADI 3463), em que este deu interpretação conforme a CF ao art. 51 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, para admitir a participação do Ministério Público no Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, limitada à condição de membro convidado e sem direito a voto. “O MP terá a oportunidade extraordinária de, voluntariamente, participando do Conselho, velar pela defesa dos direitos da criança e do adolescente”. Ainda, o STF declarou inconstitucional a parte que previa a participação do Poder Judiciário sob a alegação de que isto poderia comprometer a imparcialidade.

2. ENTIDADES DE ATENDIMENTO

As políticas de atendimento precisam ser executadas através de entidades de atendimento, podendo ser governamentais ou não governamentais. Essas entidades executam tanto de programas de proteção quanto socioafetivos.

Os programas de proteção estão direcionados às crianças e aos adolescentes em situação de risco, relacionando-se diretamente com a aplicação das medidas de proteção elencadas no art. 101 do ECA. Destaca-se a orientação e apoio familiar e social, colocação familiar e acolhimento institucional. Nesses casos, haverá auxílio médico, psicológico, terapêutico e em geral que se mostre necessário àquela família, criança ou adolescente. Frise-se que, no mais das vezes, para resolver a situação de risco do adolescente, não basta atendê-lo isoladamente, sendo necessário cuidar de sua família.

Em se tratando de adolescentes infratores, são aplicáveis as medidas socioeducativas, que variam desde advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade até internação. Somente estas duas últimas têm caráter de privação de liberdade.



Tanto as entidades de programas socioafetivos quanto de programas de proteção devem ter seus programas inscritos junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA). O Conselho Municipal manterá o registro das inscrições e suas eventuais alterações, assim como fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. A reavaliação dos programas ocorre a cada 2 anos pelo Conselho Municipal, a quem competirá renovar a autorização de funcionamento.

São critérios para renovação da autorização de funcionamento: o efetivo respeito às regras e princípios do ECA; a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestado pelo Conselho, Ministério Público e Justiça da Infância e da Juventude e índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta.

O ECA trata com alguma diferença as entidades governamentais e não governamentais, trazendo algumas exigências adicionais para estas últimas no art. 91. Veja-se:

Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.

§ 1º Será negado o registro à entidade que:

- a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
- b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei;
- c) esteja irregularmente constituída;
- d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
- e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis.

§ 2º O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1º deste artigo.

2.1. ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR

Os art. 92 e 93 tratam especificamente de entidades voltadas ao acolhimento institucional e familiar. Essas entidades só vão atuar quando não couber a manutenção da criança ou do adolescente em sua família natural.

Regra geral, somente poderão receber e acolher infantes em face de decisão judicial fundamentada, ressaltando-se casos excepcionais e urgentes, em que não há tempo hábil para aguardar decisão judicial, havendo, contudo, necessidade de comunicar o juízo da infância em até 24 horas, sob pena de responsabilidade, vide art. 93 do ECA.

Em sua atuação, as entidades de acolhimento devem ser guiadas pelos seguintes princípios, dentre outros:

- Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar: durante o período de acolhimento, o contato entre a criança ou adolescente e sua família devem ser estimulados, salvo determinação em contrário da autoridade judiciária.
- Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa;
 - Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
 - Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
 - Não desmembramento de grupos de irmãos;
 - Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
- Participação na vida da comunidade local;



- Preparação gradativa para o desligamento, já que a permanência em entidade de acolhimento tem caráter excepcional.

- Participação de pessoas da comunidade no processo educativo;

Ressalte-se que as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades do ECA.

O dirigente da entidade de acolhimento familiar ou institucional deve enviar relatórios ao juiz, sobre a situação de cada criança ou a cada adolescente e sobre suas respectivas famílias, no máximo a cada 6 meses²⁵.

Ademais, consoante já estudado no capítulo 3, o dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito (art. 92, §1º), sendo que o descumprimento das disposições do ECA pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.

A despeito de ser desnecessária, por decorrer do sistema geral de responsabilidade civil, o art. 97, §2º do ECA afirma que as pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica.

Finalmente, cabe ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento 32/2013, disciplinando a realização de visitas e audiências, preferencialmente *in loco*, nas próprias entidades de atendimento.

Dispõe o art. 1º de tal Provimento que o juiz da infância e juventude deverá realizar, em cada semestre, preferencialmente nos meses de abril e outubro, "Audiências Concentradas", a se realizarem, sempre que possível, nas dependências das entidades de acolhimento, com a presença dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, para reavaliação de cada uma das medidas protetivas de acolhimento, diante de seu caráter excepcional e provisório, com a subsequente confecção de atas individualizadas para juntada em cada um dos processos.

2.2 ENTIDADES VOLTADAS À INTERNAÇÃO

A medida socioeducativa com maior espectro pedagógico sobre o adolescente, que acaba inclusive por limitar sua liberdade, é a internação. Há entidades específicas para o cumprimento desta medida socioeducativa.

Dada a peculiaridade do programa por ela desenvolvido, essas entidades deverão observar algumas obrigações (art. 94):

- Respeitar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;
- Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão judicial de internação;
- Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos;
- Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
- Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;
- Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;
- Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;
- Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;
- Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;

²⁵ Em que pese este dispositivo falar em 6 meses, no capítulo que trata do direito à convivência familiar e comunitária há previsão no art. 19, §1º de que a situação de crianças e adolescentes acolhidos sejam reavaliados pelo juízo a cada 3 meses. Assim, há quem entenda que os relatórios devem ser enviados trimestralmente.



- Propiciar escolarização e profissionalização;
- Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
- Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;
- Proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
- Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;
- Informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual;
- Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infectocontagiosas;
- Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes;
- Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;
- Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem;
- Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.

Atenção: essas obrigações também serão aplicadas, no que couber, às entidades de programas de acolhimento institucional e familiar.

2.3. FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES

As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Em que pese o ECA não mencione expressamente, a doutrina acrescenta a este rol também a Defensoria Pública.

O impedimento ou a oposição de dificuldades ao trabalho destes que cumprem um múnus público de fiscalizar implica o cometimento do crime previsto no art. 236 do ECA.

Caso sejam encontradas irregularidades nas entidades, aplica-se o art. 97, que estabelece um rol de sanções administrativas a que estão sujeitas as entidades. A aplicação de tais sanções decorrerá de procedimento administrativo presidido pelo juiz da infância, sem prejuízo da autônoma responsabilidade civil e criminal de seus prepostos ou dirigentes.

Veja-se que o rol de sanções é diferente, caso se trate de entidade governamental ou não governamental:

I - Se entidade é governamental:

- Advertência;
- Afastamento provisório de seus dirigentes;
- Afastamento definitivo de seus dirigentes;
- Fechamento de unidade ou interdição de programa.

Admite-se medida cautelar administrativa de afastamento de dirigentes no âmbito do procedimento judicial. Aliás, em que pese tal sanção não esteja prevista para as entidades não-governamentais, conforme exposto a seguir, há corrente doutrinária entendendo que é possível tal afastamento também neste caso.

II - Se a entidade for não-governamental:

- Advertência;
- Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas;
- Interdição de unidades ou suspensão de programa;
- Cassação do registro.

Vale lembrar que a entidade governamental não se sujeita a registro, ao contrário da não governamental, que apenas fica sujeita à inscrição de seu programa no órgão competente.



Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.

Além das medidas aplicáveis às entidades, poderão ser aplicadas duas providências contra os seus dirigentes: advertência e multa (art. 193, §4º do ECA).

3. JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. ART. 97 DO **ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA APLICADA AO DIRIGENTE RESPONSÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as medidas punitivas do **ECA** não devem ser aplicadas às **entidades**, mas aos dirigentes responsáveis ou ao programa **de atendimento** irregular, uma vez que a imposição **de** sanção à pessoa jurídica implica no acarretamento **de** prejuízo aos seus beneficiários, as crianças e adolescentes, que ficariam desprovidos dos correspondentes serviços assistenciais. (STJ. AgInt no AREsp 555869, Min. Rel. Assusete Magalhães, 2ª turma, DJe 24/10/2017).

ECA. MULTA. DIRIGENTE. INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO. O art. 97 do ECA prevê a aplicação de medidas disciplinares às entidades de atendimento, porém a multa e a advertência têm de ser aplicadas a seus dirigentes (art. 193, § 4º, do ECA). Se assim não fosse, poderia haver a suspensão, o fechamento ou a dissolução da entidade, o que privaria seus beneficiários do serviço assistencial em confronto com o próprio escopo do Estatuto. (REsp 489.522-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19/8/2003.- Informativo n. 180)

QUESTÕES

1- Promotor de Justiça – MPMO/MPGO (2019) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 86, define que a política de atendimento à criança e ao adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sobre o tema, é incorreto afirmar:

- a) A política de atendimento à criança e ao adolescente prevê que seja evitada a mobilização da opinião pública para sua definição, uma vez que pode gerar exposição desnecessária da criança e do adolescente, a quem é garantida proteção integral.
- b) Dentre as diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente está a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais.
- c) Uma das linhas de ação da política de atendimento de crianças e adolescentes é a realização de campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.



d) Conforme alteração legislativa efetivada por meio da Lei n. 13.257, de 2016, foi incluída como diretriz da política de atendimento a crianças e adolescentes a especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil.

2- Promotor de Justiça – MPMG/FUNDEP (2019) Assinale a alternativa CORRETA:

a) Uma das diretrizes da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente é a federalização do atendimento.

b) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 3 (três) anos, permitida uma recondução.

c) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de todos os titulares do poder familiar, de forma conjunta, nos casos de internação de criança ou adolescente.

d) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses.

3- Defensor Público – DPE-PE/CEBRASPE (2018) As linhas de ação da política de atendimento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) incluem a

a) elaboração de banco de dados nacional com as informações necessárias à localização de crianças desaparecidas em substituição ao boletim de ocorrência feito nas delegacias de polícia.

b) proteção jurídica das entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

c) realização de campanhas de estímulo ao acolhimento, sob forma de adoção, de crianças e adolescentes temporariamente afastados do convívio familiar.

d) implementação de políticas sociais especiais que visem à satisfação das necessidades e dos anseios de crianças e adolescentes.

e) criação de projetos e benefícios de assistência social que garantam proteção social, prevenção e redução de violações de direitos.

GABARITO

1. A

2. D

3. E



CAPÍTULO 7 — MEDIDAS DE PROTEÇÃO

1. CONCEITO E PRINCÍPIO

Segundo VALTER KENJI ISHIDA, medidas de proteção “são medidas que visam evitar ou afastar o perigo ou a lesão à criança ou ao adolescente. Possuem dois vieses: um preventivo e outro reparador”. Desta feita, são aplicáveis a crianças e adolescentes submetidos às situações de risco, com o objetivo de salvaguardar qualquer criança ou adolescente, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados de violação.

A situação de risco, consoante interpretação do art. 98 do ECA, se caracteriza quando os direitos reconhecidos aos infantes forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou III - em razão de sua própria conduta. Inclusive, a ocorrência de risco enseja a fixação da competência do Juízo da Infância e da Juventude.

Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Tal aplicação, por sua vez, seguirá os seguintes princípios, dispostos exemplificadamente no art. 100, parágrafo único do ECA:

- Princípio da condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;
- Princípio da proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no ECA deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;
- Princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes pelo ECA e pela CF, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais;
- Princípio do interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;
- Princípio da privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada;
- Princípio da intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;
- Princípio da intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;
- Princípio da proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada;
- Princípio da responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;
- Princípio da prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva (Lei 13.509/17);

- Princípio da obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;

- Princípio da oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente.

O ECA traz um rol exemplificativo de medidas de proteção (art. 101):

- Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
- Orientação, apoio e acompanhamento temporários;
- Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;

- Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente;

- Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Cabe destacar que, em havendo necessidade de internação contra a vontade da criança ou adolescente em caso de drogadição ou alcoolismo, é necessário ajuizar ação própria.

- Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

- Acolhimento institucional;
- Inclusão em programa de acolhimento familiar;
- Colocação em família substituta.

2. ACOLHIMENTO

A medida de proteção mais drástica ao infante, sem dúvidas, é o acolhimento, especialmente se for o caso de acolhimento institucional.

Consiste na determinação, pela autoridade competente, do encaminhamento de uma certa criança ou adolescente a uma entidade que desenvolve o programa de acolhimento, segundo ensina PATRÍCIA TAVARES.

No capítulo que trata das medidas de proteção, o ECA dispõe de algumas regras específicas ao acolhimento.

Em primeiro lugar, dispõe que as duas modalidades de acolhimento (institucional ou familiar) são provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta. Não implicam privação de liberdade.

O acolhimento deve ser realizado em local próximo ao local de residência dos pais ou do responsável, uma vez que o contato entre o acolhido e sua família deve ser estimulado. Assim que a família estiver apta a ser reunida novamente, o programa de acolhimento deverá informar o juízo da infância. De todo modo, o acolhimento deve ser reavaliado pelo juízo trimestralmente.

Se ficarem esgotadas as possibilidades de reintegração à família, o programa de acolhimento encaminhará relatório ao Ministério Público, a fim promover as providências devidas à destituição do poder familiar e à tutela ou guarda desta criança. A 13.509/2017 reduziu de 30 para 15 dias, a contar do recebimento do o relatório, o prazo para o Ministério Público ingressar com a ação de destituição do poder familiar (fica ressalvada a hipótese de o membro do *Parquet* entender ser necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda).

Regra geral, o acolhimento deve durar até 18 meses, podendo este prazo pode ser prorrogado, em caso de comprovada necessidade, mediante decisão judicial fundamentada.



O acolhimento decorre de decisão judicial do juízo da infância, sendo que o encaminhamento da criança ou adolescente ao acolhimento se dá com a expedição da guia de acolhimento, contendo os dados elencados no art. 101, §3º do ECA.

Excepcionalmente e em razão da urgência, a entidade de acolhimento institucional poderá acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. Normalmente se dá por intervenção do Conselho Tutelar.

Recebida a comunicação, o juiz, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta.

Imediatamente após o acolhimento, a entidade responsável, por meio de sua equipe técnica, deverá elaborar um plano individual de atendimento, contendo os elementos indicados no § 6º do art. 101: resultados da avaliação interdisciplinar, compromissos assumidos pelos pais e responsáveis e previsão de atividades a serem desenvolvidas com o infante e seus pais ou responsáveis, com vistas à reintegração familiar ou colocação em família substituta.

A Justiça da Infância e do Adolescente deve criar cadastro de crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar.

No mais, as medidas de proteção serão acompanhadas da regularização do registro civil da criança ou do adolescente. Caso seja constatada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.

Para garantir a facilidade à regularização do registro civil, todos os registros e certidões que se fizerem necessários à regularização são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Além disso, serão gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente.

Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação. Trata-se de ação de investigação de paternidade proposta pelo Ministério Público. Relembre-se que, excepcionalmente, o Ministério Público poderá deixar de ingressar com esta ação, nos casos em que esta criança ou adolescente for encaminhado à adoção.

3. MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

Conforme já estudado, a situação de risco muitas vezes decorre de um problema na família. Assim, o ECA tem a preocupação não somente com a criança e com o adolescente, mas também de tratar do núcleo familiar que vivencia algum conflito.

Nesse sentido, há previsão de medidas que são aplicáveis aos pais ou responsáveis de infante, as quais estão previstas em rol enumerativo no art. 129 do ECA:

- Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família;
- Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
- Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
- Encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
- Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;
- Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
- Advertência;
- Perda da guarda;
- Destituição da tutela;



- Suspensão ou destituição do poder familiar.

Destaque-se que a jurisprudência não admite a aplicação de qualquer medida aos pais ou responsáveis como decorrência de ato infracional praticado pelo adolescente.

Uma importante medida prevista no art. 130 do ECA é o afastamento do agressor da moradia comum, por ordem judicial, caso verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável.

Inclusive, o juiz, ao aplicar a medida cautelar, fixará alimentos provisórios de que necessitem a criança ou o adolescente dependente do agressor. Há entendimento prevalente no sentido de que a fixação de alimentos nesse caso é obrigatória, de modo que pode até cogitar-se numa atuação *ex officio* do juiz em face de expressa determinação legal.

4. JURISPRUDÊNCIA

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ENTREGA IRREGULAR DO INFANTE PELA MÃE BIOLÓGICA. LIMINAR QUE DETERMINOU O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. POSTERIOR SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E IMPROCEDENTE A AÇÃO DE ADOÇÃO. **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE. ORDEM DENEGADA. LIMINAR REVOGADA.**

1. A disciplina do art. 50 do ECA, ao prever a manutenção dos cadastros de adotantes e adotandos, tanto no âmbito local e estadual quanto em nível nacional, visa conferir maior transparência, efetividade, segurança e celeridade ao processo de adoção, assim como obstar a adoção *intuitu personae*.

2. No caso, diante do superveniente julgamento de procedência da ação de destituição do poder familiar, em relação à mãe biológica, e de improcedência da ação de adoção pelo casal a quem a genitora entregou irregularmente a criança desde o nascimento, não há como permitir que o menor permaneça sob a guarda dos pretendentes, sobretudo porque um deles tem condenação criminal por tráfico de drogas, o que representa um empecilho à adoção legal.

3. Ordem denegada e, por consequência, revogada a liminar anteriormente concedida. (STJ. HC 522557. Rel. Min Raul Araújo. 4ª Turma. DJe 12/03/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO DE ALIMENTOS EM PROVEITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). **O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou de o infante se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.** De fato, o art. 127 da CF traz, em seu *caput*, a identidade do MP, seu núcleo axiológico, sua vocação primeira, que é ser "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Ademais, nos incisos I a VIII do mesmo dispositivo, a CF indica, de forma meramente exemplificativa, as funções institucionais mínimas do MP, trazendo, no inciso IX, cláusula de abertura que permite à legislação infraconstitucional o incremento de outras atribuições, desde que compatíveis com a vocação constitucional do MP. Diante disso, já se deduz um vetor interpretativo invencível: a legislação infraconstitucional que se propuser a disciplinar funções institucionais do MP poderá apenas elastecer seu campo de atuação, mas nunca subtrair atribuições já existentes no próprio texto constitucional ou mesmo sufocar ou criar embaraços à realização de suas incumbências centrais, como a defesa dos "interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127 da CF) ou do respeito "aos direitos assegurados nesta

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II, da CF). No ponto, não há dúvida de que a defesa dos interesses de crianças e adolescentes, sobretudo no que concerne à sua subsistência e integridade, insere-se nas atribuições centrais do MP, como órgão que recebeu a incumbência constitucional de defesa dos interesses individuais indisponíveis. Nesse particular, ao se examinar os principais direitos da infância e juventude (art. 227, *caput*, da CF), percebe-se haver, conforme entendimento doutrinário, duas linhas principiológicas básicas bem identificadas: de um lado, vige o princípio da absoluta prioridade desses direitos; e, de outro lado, a indisponibilidade é sua nota predominante, o que torna o MP naturalmente legitimado à sua defesa. Além disso, é da própria letra da CF que se extrai esse dever que transcende a pessoa do familiar envolvido, mostrando-se eloquente que não é só da família, mas da sociedade e do Estado, o dever de assegurar à criança e ao adolescente, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação" (art. 227, *caput*), donde se extrai o interesse público e indisponível envolvido em ações direcionadas à tutela de direitos de criança e adolescente, das quais a ação de alimentos é apenas um exemplo. No mesmo sentido, a CF consagra como direitos sociais a "alimentação" e "a proteção à maternidade e à infância" (art. 6º), o que reforça entendimento doutrinário segundo o qual, em se tratando de interesses indisponíveis de crianças ou adolescentes (ainda que individuais), e mesmo de interesses coletivos ou difusos relacionados com a infância e a juventude, sua defesa sempre convirá à coletividade como um todo. Além do mais, o STF (ADI 3.463, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2012) acolheu expressamente entendimento segundo o qual norma infraconstitucional que, por força do inciso IX do art. 129 da CF, acresça atribuições ao MP local relacionadas à defesa da criança e do adolescente, é consentânea com a vocação constitucional do *Parquet*. Na mesma linha, é a jurisprudência do STJ em assegurar ao MP, dada a qualidade dos interesses envolvidos, a defesa dos direitos da criança e do adolescente, independentemente de se tratar de pessoa individualizada (AgRg no REsp 1.016.847-SC, Segunda Turma, DJe 7/10/2013; e EREsp 488.427-SP, Primeira Seção, DJe 29/9/2008). Ademais, não há como diferenciar os interesses envolvidos para que apenas alguns possam ser tutelados pela atuação do MP, atribuindo-lhe legitimidade, por exemplo, em ações que busquem tratamento médico de criança e subtraindo dele a legitimidade para ações de alimentos, haja vista que tanto o direito à saúde quanto o direito à alimentação são garantidos diretamente pela CF com prioridade absoluta (art. 227, *caput*), de modo que o MP detém legitimidade para buscar, identicamente, a concretização, pela via judicial, de ambos. Além disso, não haveria lógica em reconhecer ao MP legitimidade para ajuizamento de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, ou mesmo a legitimidade recursal em ações nas quais intervém - como reiteradamente vem decidindo a jurisprudência do STJ (REsp 208.429-MG, Terceira Turma, DJ 1/10/2001; REsp 226.686-DF, Quarta Turma, DJ 10/4/2000) -, subtraindo-lhe essa legitimação para o ajuizamento de ação unicamente de alimentos, o que contrasta com o senso segundo o qual quem pode mais pode menos. De mais a mais, se corretamente compreendida a ideologia jurídica sobre a qual o ECA, a CF e demais diplomas internacionais foram erguidos, que é a *doutrina da proteção integral*, não se afigura acertado inferir que o art. 201, III, do ECA - segundo o qual compete ao MP promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como officiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude - só tenha aplicação nas hipóteses previstas no art. 98 do mesmo diploma, ou seja, quando houver violação de direitos por parte do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou em razão da conduta da criança ou adolescente, ou ainda quando não houver exercício do poder familiar. Isso porque essa solução implicaria ressurgimento do antigo paradigma superado pela *doutrina da proteção integral*, vigente durante o Código de Menores, que é a *doutrina do menor em situação irregular*. Nesse contexto, é

decorrência lógica da *doutrina da proteção integral* o princípio da intervenção precoce, expressamente consagrado no art. 100, parágrafo único, VI, do ECA, tendo em vista que há que se antecipar a atuação do Estado exatamente para que o infante não caia no que o Código de Menores chamava situação irregular, como nas hipóteses de maus-tratos, violação extrema de direitos por parte dos pais e demais familiares. Além do mais, adotando-se a solução contrária, chegar-se-ia em um círculo vicioso: só se franqueia ao MP a legitimidade ativa se houver ofensa ou ameaça a direitos da criança ou do adolescente, conforme previsão do art. 98 do ECA. Ocorre que é exatamente mediante a ação manejada pelo MP que se investigaria a existência de ofensa ou ameaça a direitos. Vale dizer, sem ofensa não há ação, mas sem ação não se descortina eventual ofensa. Por fim, não se pode confundir a substituição processual do MP - em razão da qualidade dos direitos envolvidos, mediante a qual se pleiteia, em nome próprio, direito alheio -, com a representação processual da Defensoria Pública. Realmente, o fato de existir Defensoria Pública relativamente eficiente na comarca não se relaciona com a situação que, no mais das vezes, justifica a legitimidade do MP, que é a omissão dos pais ou responsáveis na satisfação dos direitos mínimos da criança e do adolescente, notadamente o direito à alimentação. É bem de ver que - diferentemente da substituição processual do MP - a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública não dispensa a manifestação de vontade do assistido ou de quem lhe faça as vezes, além de se restringir, mesmo no cenário da Justiça da Infância, aos necessitados, no termos do art. 141, § 1º, do ECA. Nessas situações, o ajuizamento da ação de alimentos continua ao alvedrio dos responsáveis pela criança ou adolescente, ficando condicionada, portanto, aos inúmeros interesses rasteiros que, frequentemente, subjazem ao relacionamento desfeito dos pais. Ademais, sabe-se que, em não raras vezes, os alimentos são pleiteados com o exclusivo propósito de atingir o ex-cônjuge, na mesma frequência em que a pessoa detentora da guarda do filho se omite no ajuizamento da demanda quando ainda remanescer esperança no restabelecimento da relação. Enquanto isso, a criança aguarda a acomodação dos interesses dos pais, que nem sempre coincidem com os seus. **REsp 1.265.821-BA e REsp 1.327.471-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 14/5/2014.**

QUESTÕES

- 1- **Promotor de Justiça – MPSP/Vunesp (2017)** Dentre as medidas específicas de proteção, textualmente previstas no art. 101 da Lei Federal nº 8.069/90, não se encontra arrolada a de:
- a) encaminhamento aos pais mediante termo de responsabilidade.
 - b) requisição de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar.
 - c) acolhimento institucional.
 - d) abrigo em entidade.
 - e) colocação em família substituta.
- 2- **Promotor de Justiça – MPPR/MPPR (2019)** Nos termos do que expressamente estabelece a Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a alternativa **incorreta**. É medida aplicável aos pais ou responsável:
- a) Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.
 - b) Comparecimento em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades.
 - c) Advertência



- d) Perda da guarda.
- e) Destituição da tutela.

3- Defensor Público – DPE-PE/Cebraspe (2018) A respeito da aplicação de medidas ao pai, à mãe ou ao responsável conforme o ECA, assinale a opção correta:

- a) Medida mais gravosa, como a perda de guarda, não se aplica em caso de a criança ser reprovada na escola por excesso de faltas, mesmo que a reprovação decorra da falta de acompanhamento adequado de seu responsável
- b) É facultativa a inclusão de pai alcoólatra que, por vezes, seja agressivo ou violento com a criança em programa oficial de tratamento desde que a criança seja encaminhada a programa especial de atendimento a vítimas de violência doméstica
- c) Estando a submissão ou não a tratamento de saúde no âmbito da liberalidade familiar, não é possível a aplicação de medidas a mãe que, por mera desídia, não leva seu filho portador de HIV às consultas programadas.
- d) Na hipótese de um adolescente que tenha pais vivos, mas viva com os avós paternos, se encontrar em situação de risco por falta de cumprimento de obrigações a ele relativas, caberá a aplicação de advertência aos genitores, mas não aos avós.
- e) Se uma criança em idade escolar estiver fora da escola, o pai, a mãe ou o responsável deverá ser obrigado a matriculá-la, bem como a acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar.

GABARITO

- 1. D
- 2. B
- 3. E

CAPÍTULO 8 – O ATO INFRACIONAL

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE O ATO INFRACIONAL

No âmbito criminal, em face do critério etário, os menores de 18 anos são inimputáveis, de modo que, para a teoria tripartite do crime, não cometem crimes ou contravenção penal e não são responsabilizados criminalmente.

Nada obstante, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por menor de 18 anos. A criança que praticar ato infracional ficará sujeita somente a medidas de proteção; aquelas elencadas no art. 101 do ECA. Os adolescentes, por sua vez, além da sujeição a medidas protetivas, ficarão sujeitos a medidas socioeducativas, até completarem 21 anos.

Nesse sentido, tem-se a Súmula 605 do STJ: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

Há duas correntes sobre a natureza jurídica do direito relacionado ao ato infracional:

a) Direito penal juvenil: para essa corrente, além da existência do caráter pedagógico da medida socioeducativa aplicada a quem comete ato infracional, há em sua execução também um caráter retributivo, semelhante ao direito penal. Daí porque, segundo essa corrente, deve haver ao adolescente infrator os mesmos direitos e garantias conferidos ao réu maior de 18 anos, já que o direito penal dos adolescentes é um ramo próprio do subsistema penal. O STJ parece alinhar-se com tal posicionamento, justamente com o escopo de permitir a incidência da prescrição das medidas socioeducativas. Nesse sentido, a Súmula 338 do STJ estabelece que: “A Prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas”, muito embora o ECA seja silente quanto ao tema.

b) Doutrina do direito infracional: segundo essa corrente, oposta à outra supra apresentada, a medida socioeducativa deve preservar seu purismo, tendo finalidade essencialmente educativa e pedagógica. Nessa linha, o objetivo do ECA não seria punir nem prejudicar o adolescente, o que contraria a doutrina da proteção integral.

Quanto ao tempo do ato infracional, é adotada a mesma teoria o Código Penal, isto é, teoria da atividade, segundo a qual se considera praticado o ato infracional no momento da conduta comissiva ou omissiva. Deste modo, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato para fins de incidência do ECA e responsabilização infantojuvenil. O implemento da maioridade aos 18 anos não impede a aplicação de medida socioeducativa, que somente será extinta aos 21 anos, vide art. 121, §5º do ECA.

Quanto ao lugar do ato infracional, aplica-se por analogia o art. 6º do Código Penal, isto é, a teoria da ubiquidade.

Será competente para o julgamento de atos infracionais a justiça da infância e da juventude, sempre no âmbito dos Tribunais de Justiça Estaduais.

2. DIREITOS INDIVIDUAIS DO ADOLESCENTE SUSPEITO DE COMETER ATO INFRACIONAL

Uma vez praticado o ato infracional, detém o Estado o direito de reeducar. Nada obstante, antes de realizado esse direito por meio da aplicação de medida socioeducativa, existe em contrapartida um direito subjetivo de liberdade e de ser tratado com respeito de que são titulares crianças e adolescentes. Portanto, dos art. 106 a 111, o ECA preocupou-se em elencar direitos individuais e garantias processuais aos adolescentes que poderão ser reeducados mediante medida socioeducativa.

Nesse sentido, a privação de liberdade somente será possível em caso de flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Para compreensão da situação de flagrância, aplica-se por analogia o art. 302 do CPP:

- **Flagrante próprio:** está em flagrante quem está cometendo ato infracional ou acaba de cometê-lo;



- **Quase-flagrante (ou flagrante impróprio):** está em flagrante quem é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor do ato infracional;

- **Flagrante presumido:** está em flagrante quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor do ato infracional;

Em qualquer dessas situações, o adolescente será apreendido e encaminhado à delegacia de polícia, preferencialmente especializada.

O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

Por sua vez, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão *incontinenti* comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Desde logo e sob pena de responsabilidade, será analisada a possibilidade de liberação imediata por parte da autoridade policial e judicial. Veja-se que o ECA não fala no Ministério Público, porém tradicionalmente este também é comunicado do flagrante.

A internação provisória, antes da sentença judicial, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. O ECA houve por bem dimensionar prazo para finalização do procedimento para aplicação de medida socioeducativa. Os tribunais superiores, como regra geral, não admitem prorrogação desse prazo, colocando-se o adolescente em liberdade após passados os 45 dias de internação provisória.

Outro direito individual do adolescente é o de ser civilmente identificado, não podendo se submeter à identificação criminal compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo se houver dúvida fundada para efeito de confrontação.

O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

A internação não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Inexistindo na comarca entidade de internação, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, em seção isolada dos adultos, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade.

3. GARANTIAS PROCESSUAIS

Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. O devido processo legal no caso se realiza mediante a ação socioeducativa, cujo titular para representar em desfavor do adolescente é o Ministério Público.

O art. 111 do ECA estabelece um rol exemplificativo de garantias asseguradas ao adolescente:

- Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação do adolescente ou meio equivalente;
- Garantia de igualdade na relação processual, podendo o adolescente se confrontar com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;
- Garantia de defesa técnica por advogado;
- Garantia de assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
- Garantia do direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;
- Garantia do direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.

4. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Conceito: Medida que encerra um programa de caráter proeminentemente pedagógico, imposta obrigatoriamente ao adolescente, autor de ato infracional, com a finalidade de reorganizar seus valores pessoais, sem prejuízo de ser uma resposta à violação da ordem com caráter preventivo



e também punitivo. Decorre de uma sentença judicial ou, nos casos que a lei permite, de remissão ministerial homologada em juízo ou da própria remissão judicial.

São objetivos primordiais das medidas socioeducativas:

- Responsabilidade do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação;
- Integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e
- Desaprovação da conduta infracional.

Diferentemente das medidas de proteção, cujo rol do art. 101 é meramente exemplificativo, as medidas socioeducativas têm caráter taxativo. É possível, todavia, que as medidas de proteção sejam aplicadas cumulativamente com as medidas socioeducativas.

Eis o rol das medidas socioeducativas, no art. 112 do ECA:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (medidas de proteção).

Em hipótese alguma, será admitida a prestação de trabalho forçado.

Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.

No mais, o juiz, ao decidir qual medida socioeducativa imporá, deve levar em conta alguns vetores como:

- Capacidade de cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente;
- Circunstâncias fáticas do ato infracional;
- Gravidade do ato infracional.

Tais vetores estão declinados no art. 112, § 2º do ECA. Nada obstante, a doutrina e a jurisprudência elenca outros vetores, como a primariedade ou não do adolescente em conflito com a lei e vinculação com a família natural ou extensa

Não pode ser invocada como motivo ou critério para aplicação ou manutenção do adolescente em medida socioeducativa de privação da liberdade a oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto (como é o caso da prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida), vide art. 49, §2º da Lei nº 12.594/2012.

Lado outro, é direito do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência, consoante dispõe o art. 49, inciso II da mesma lei supracitada.

Nada obstante, segundo o STJ, referida regra deve ser aplicada de acordo com o caso concreto, observando-se as situações específicas do adolescente, do ato infracional praticado, bem como do relatório técnico e/ou plano individual de atendimento. Isso significa que o simples fato de não haver vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade em unidade próxima da residência do adolescente infrator não impõe a sua inclusão em programa de meio aberto.

Para além da possibilidade de cumulação de medidas socioeducativas com medidas de proteção, é possível a substituição de medidas aplicadas a qualquer tempo, para que estas se tornem mais adequadas ao adolescente, cumprindo sua função pedagógica.

Acerca da possibilidade de substituição das medidas socioeducativas, já decidiu o STF que a substituição para medida mais grave poderá ocorrer apenas no caso de regressão por descumprimento da medida aplicada. As medidas protetivas, por sua vez, podem ser amplamente substituídas.



Para imposição de medida mais gravosa em caráter substitutivo, é necessária a prévia oitiva do adolescente, em homenagem ao devido processo legal e à ampla defesa. Tem-se nesse sentido a Súmula 265 do STJ: “é necessária a oitiva do menor antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa”.

A imposição de medida de internação em face de descumprimento de medida mais branda é chamada de “internação sanção”. Seu prazo, porém, está limitado a 3 (três) meses, vide art. 122, §1º do ECA.

A fim de que sejam impostas as medidas socioeducativas, prevê o art. 114 do ECA que são pressupostas a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração. Há, no entanto, duas exceções, em que pode ser aplicada medida socioeducativa sem plena comprovação da autoria e materialidade.

A primeira delas é no caso de advertência. Nesse caso, dispõe o ECA que basta a existência de “indícios suficientes de autoria”, consoante consta do parágrafo único daquele artigo.

Segundo explica VALTER KENJI ISHIDA:

a diferença entre provas suficientes de autoria (art. 114, caput) e indícios suficientes da autoria (art. 114, parágrafo único) trata-se de uma gradação, de escala que vai da certeza absoluta até impossibilidade (...). Na verdade, a expressão prova suficiente quer dizer uma prova que basta, que é razoável, o que necessariamente não implica na exigência da certeza. Já o indício suficiente de autoria significa uma prova qualitativamente menor, mas que implique prova de que tal adolescente foi o autor do ato infracional, embora possam pairar dúvidas. (...). A medida de advertência admite a aplicação desde que haja indícios de autoria, ou seja, elementos que façam supor que o adolescente tenha cometido o ato infracional. Assim, para a aplicação da medida socioeducativa, existe a necessidade de uma prova plena. Apenas para a medida socioeducativa de advertência, exige-se apenas a prova não plena.

O segundo caso em que não se exige a prova de autoria é para aplicação do instituto da remissão. Trata-se de uma espécie de perdão dado ao adolescente pela prática de ato infracional. Não gera qualquer efeito de antecedentes infracionais, não implica reconhecimento da responsabilidade, nem comprovação da responsabilidade. Caso aceite a oferta do Ministério Público (remissão ministerial), o processo é encerrado. Da mesma forma nos casos de remissão judicial. Nos casos de remissão, é possível cumular a remissão com a imposição de uma medida socioeducativa, desde que não seja internação ou semiliberdade.

Antes de adentrar na análise de cada uma das medidas socioeducativas existentes, cabe ressaltar que o STJ admite a aplicação do princípio da insignificância no bojo do sistema do ECA, desde que presentes seus requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

Nessa linha já decidiu o STJ que caso o ato infracional praticado seja praticado com violência ou grave ameaça ou quando há reiteração da conduta infracional, é inaplicável o princípio da insignificância.

4.1. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM ESPÉCIE

4.1.1 ADVERTÊNCIA

Reza o art. 115 que advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.

Relembre-se a peculiaridade de tal advertência: possibilidade de aplicação com meros indícios de autoria do adolescente.



4.1.2. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO

Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.

Tal obrigação é um caso de responsabilidade civil de incapaz. Tal responsabilidade só se tornará viável no caso de o incapaz possuir patrimônio próprio, pois ele é o responsável pela reparação do dano, e não seus pais ou responsáveis.

São modos de aplicação da medida: a indenização em pecúnia, obrigação de restituição da coisa quando possível ou a imposição de providência compensatória em relação ao dano, por exemplo, a de serviço diretamente a vítima para compensá-la.

Havendo manifesta impossibilidade, a medida de reparação do dano poderá ser substituída por outra adequada.

4.1.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Operacionaliza-se normalmente por meio de convênios da vara da infância com entidades privadas ou encaminhamento ao município. Tal como na execução criminal, depende de guia de encaminhamento.

A jornada máxima será de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada de trabalho. O prazo máximo de duração, por sua vez, é de 6 meses.

4.1.4. LIBERDADE ASSISTIDA

É a medida mais rígida dentre as medidas cumpridas pelo adolescente em liberdade.

Liberdade assistida é a liberdade com ajuda. Trata-se de uma forma de submeter o adolescente à assistência, com o fim de impedir reincidência e obter sua reeducação. Desta feita, o adolescente é acompanhado por equipe interdisciplinar, possuindo inclusive um orientador da entidade de atendimento, responsável por:

- Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;
- Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;
- Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;
- Apresentar relatório do caso.

O prazo mínimo de duração da liberdade assistida: 6 meses, não havendo previsão de prazo máximo. Nada obstante, para o STJ, aplica-se analogicamente o prazo máximo da internação, que é de 3 anos.

A liberdade assistida será fixada pelo juiz, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. O orientador deve ser pessoa maior, capaz e idônea.

4.1.5. SEMILIBERDADE

É uma medida socioeducativa que priva em parte a liberdade do adolescente, podendo ser fixada na sentença, ou como forma de transição da medida de internação para o meio aberto, como



se fosse uma espécie de progressão de regime. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se analogicamente, por determinação legal, o máximo de 3 anos previstos para internação.

Na semiliberdade, o adolescente trabalha e estuda durante o dia, e, à noite, retorna para dormir na entidade. Importante frisar que a realização do trabalho, do estudo e de atividades externas não dependem de autorização judicial. Já decidiu o STF que a vedação às atividades externas e de visitação à família dependem de fundamentação expressa e razoável do juízo.

A escolarização e a profissionalização são obrigatórias, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.

4.1.6 INTERNAÇÃO

Internação é a medida socioeducativa mais gravosa, já que implica privação da liberdade, com a incidência do mais largo espectro pedagógico, uma vez que o adolescente será amplamente assistido por equipe técnica composta por assistente social, psicólogo, pedagogo, médico, professores, etc.

Por se tratar de medida privativa de liberdade, sujeita-se aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Pelo princípio da brevidade: a internação somente irá durar pelo prazo estritamente necessário para atingir sua finalidade social, pedagógica e educativa. De acordo com o princípio da excepcionalidade, somente se impõe medida de internação se outra medida não se revelar adequada, conforme art. 122, §2º do ECA.

Já o respeito à condição peculiar, visa manter as condições gerais de desenvolvimento do adolescente, garantindo-se, por exemplo, seu ensino e profissionalização enquanto internados, já que o objetivo é que a imposição de medida socioeducativa venha a ressocializar o adolescente.

Na internação, a realização de atividades externas é possível, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Ou seja, somente haverá vedação às atividades externas caso haja ordem judicial proibindo expressamente.

A internação não está sujeita a prazo certo de duração, mas há prazo máximo de cumprimento, que é de 3 anos. Ademais, no máximo a cada 6 meses, deverá ser reavaliada a manutenção da internação do adolescente.

A internação é cabível somente nas hipóteses dispostas no art. 122 do ECA:

- Ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa: doutrina e jurisprudência entendem passível a internação mesmo que as condutas sejam apenas tentadas. Importante também nesse ponto destacar a Súmula 492 do STJ: “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”. Dessa feita, por mais que o tráfico de drogas seja equiparado a hediondo, como não envolve diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, não se admite a internação por esse ato infracional ao adolescente sem qualquer antecedente infracional (primário).

- Reiteração no cometimento de outras infrações graves: o ECA não estipulou um número mínimo de atos infracionais. De acordo com o STJ, cabe ao magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente a fim de aplicar ou não a internação. Restou superado o entendimento de que a internação com base nesse dispositivo somente seria permitida com a prática de no mínimo 3 infrações. Ademais, o STF já decidiu que o adolescente que pratique ato infracional análogo ao crime de porte de drogas para consumo próprio não poderá sofrer internação. Isso porque o crime de porte de droga para uso pessoal não comina pena privativa de liberdade e, deste modo, o adolescente não pode ser tratado de forma mais gravosa que o adulto.

- Descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Com relação à regressão, por conta de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, é necessária a oitiva do adolescente, vide a já citada Súmula 265 do STJ.



Prazo máximo de 3 meses para esta internação sanção. Ademais, a regressão deve ser fundamentada em parecer técnico.

Atingido o limite de 3 anos de internação, o adolescente deverá ser colocado em liberdade, colocado em regime de semiliberdade ou colocado em regime de liberdade assistida. Em nenhuma hipótese poderá continuar internado. Vale destacar: atingidos os 21 anos, a liberação do adolescente será compulsória.

Rememore-se que a internação provisória terá um prazo total de 45 dias, sendo este computado no prazo da internação total a que fica sujeito o adolescente.

Cabe destacar ainda que é vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.

O art. 123 ECA do ECA traz algumas características sobre o cumprimento da internação, a qual deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao acolhimento institucional.

Além disso, as entidades que executam a internação devem obedecer rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Em que pese nesse artigo não haja menção expressa, evidentemente que deverá haver separação por sexo de adolescentes.

Em hipótese alguma, será admitida a incomunicabilidade do adolescente (124, §1º, ECA). No entanto, excepcionalmente, poderá o juiz suspender o direito do adolescente de receber visitas, inclusive dos pais, caso estas visitas estejam sendo nocivas.

Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.

O art. 124, por sua vez, prevê extenso rol exemplificativo de direitos dos adolescentes privados de liberdade:

- Direito de entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
- Direito de peticionar diretamente a qualquer autoridade;
- Direito de avistar-se reservadamente com seu defensor;
- Direito de ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
- Direito de ser tratado com respeito e dignidade;
- Direito de permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável;
- Direito de receber visitas, ao menos, semanalmente;
- Direito de corresponder-se com seus familiares e amigos;
- Direito de ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
- Direito de habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
- Direito de receber escolarização e profissionalização;
- Direito de realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;
- Direito de ter acesso aos meios de comunicação social;
- Direito de receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
- Direito de manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;
- Direito de receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.

É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.



5. REMISSÃO

O instituto da remissão surgiu a partir das chamadas Regras de Beijing, que são regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude. Também conhecidas como Regras de Pequim. Sua natureza jurídica é de Resolução da Assembleia Geral da ONU.

Com efeito, na referida normativa, a finalidade era de conceder um perdão ao adolescente que comete ato infracional, mas não um perdão puro e simples; e sim um perdão com aplicação de medida menos rigorosa e sem estigmatização causada por todo o procedimento infracional.

Fala-se em remissão própria quando ocorre o perdão simples e remissão imprópria quando ela é cumulada com aplicação de alguma medida socioeducativa.

Ademais, existe a remissão ministerial e remissão judicial.

Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, que se dá com a apresentação pelo Ministério Público da representação, o Promotor de Justiça poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.

Esse é o caso da remissão ministerial: o processo não terá sequer início. O perdão concedido pelo Ministério Público evita a propositura da ação socioeducativa, além de não ensejar perda de primariedade nem confissão. Tem previsão no art. 126 do ECA

Para além da remissão nesta fase pré-processual, tem-se que, iniciado o procedimento, é possível a concessão da remissão pela autoridade judiciária, o que importará na suspensão ou extinção do processo. Trata-se da remissão judicial e depende, necessariamente, da existência do processo judicial. Diz o art. 188 que a remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.

A remissão não implica reconhecimento ou comprovação da responsabilidade e tampouco serve como fixador de antecedentes.

Há entendimento doutrinário no sentido de que o Promotor de Justiça pode oferecer remissão cumulada com medidas de proteção, porém não poderia cumular remissão com medida socioeducativa, uma vez que somente o juiz poderia conceder a remissão cumulada medida socioeducativa, desde que esta não seja de semiliberdade e de internação.

Aliás, diz a Súmula 108 do STJ que “a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz”. Assim sendo, se o promotor entender que é adequada a remissão cumulada com medida socioeducativa, deverá submeter a remissão ao crivo do juízo, para homologação.

Todavia, se o representante do Ministério Público oferece remissão pré-processual cumulada com medida socioeducativa e o juiz discorda da cumulação, o magistrado não pode excluir do acordo a aplicação da medida socioeducativa e homologar apenas a remissão. Isso porque é prerrogativa do *Parquet*, como titular da representação por ato infracional, a iniciativa de propor a remissão pré-processual como forma de exclusão do processo.

No ato da homologação, se o juiz discordar da remissão concedida, deverá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que ele decida, tal como ocorre no art. 28 do CPP. Assim sendo, o Procurador poderá oferecer representação, designar outro membro do Ministério Público para apresentar representação ou ratificar o arquivamento ou a remissão, hipótese na qual juiz estará obrigado a homologar.

Nesse sentido já decidiu recentemente o STJ: mesmo que o juiz discorde parcialmente da remissão, ele não pode modificar os termos da proposta oferecida pelo Ministério Público para fins de excluir aquilo com o que não concordou, vide Informativo n. 587.

A remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente, de seu representante legal ou do Ministério Público.

Da decisão que concede ou que denega a remissão, cabe recurso de apelação.



Caso seja oferecida remissão imprópria e o adolescente descumpra a medida aplicada, em razão da falta de sentença de mérito, tendo em vista o caráter transacional do instituto, necessário se faz com que se prossiga (ou proponha) a ação socioeducativa para que ao final seja definitivamente imposta a medida socioeducativa.

Aliás, já julgados que reconhecem a suspensão da prescrição na data da homologação da remissão judicial.

6. JURISPRUDÊNCIA

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MAIORIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO POSTERIOR A FATO EQUIPARADO A DELITO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ATÉ 21 ANOS. De início, note-se que a partir do momento em que foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, observou-se um período intermediário, compreendido entre os 18 e os 21 anos, no qual se poderia ter um indivíduo considerado relativamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, porém, sob o aspecto criminal, seria capaz. Daí exsurge a premissa de o legislador ter previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 8.069/1990, que, nos casos expressos em lei, aplicar-se-iam as normas previstas no ECA, também, às pessoas entre 18 e 21 anos. Ainda que inexistente norma expressa no sentido da extinção da medida socioeducativa pelo implemento da maioridade civil, é inegável que a inserção desta excepcionalidade de aplicação do ECA para além dos 18 anos – e da qual nos valem para impor a execução das medidas de semiliberdade e internação até os 21 anos, se o caso – deu-se ante a iminente necessidade de, à época, se ampliar a proteção integral prevista na Lei n. 8.069/1990, para até o atingimento da maioridade civil, mesmo que, nessa faixa etária, o agente não pudesse mais ser considerado criança e nem sequer adolescente. Sobre o tema, este Superior Tribunal considera que, nos termos da interpretação do art. 121, § 5º, da Lei n. 8.069/1990, para sujeitar o adolescente às medidas socioeducativas, [...] deve ser considerada a inimizabilidade penal à data do fato. Diante disso, esta Corte assentou o entendimento segundo o qual a superveniência de maioridade relativa (período entre 18 e 21 anos) não tem o condão de extinguir a medida socioeducativa, a qual ocorrerá apenas com a liberação compulsória do menor, aos 21 anos de idade [...] (HC n. 352.662/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). Nesses termos é que foi editada, pela Terceira Seção deste Superior Tribunal, a **Súmula 605/STJ**: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. (REsp 1.705.149-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 13/08/2018 (Tema 992 – Informativo n. 630)

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO IMEDIATO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INDEPENDENTE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. Mesmo diante da interposição de recurso de apelação, é possível o imediato cumprimento de sentença que impõe medida socioeducativa de internação, ainda que não tenha sido imposta anterior internação provisória ao adolescente. Cuidando-se de medida socioeducativa, a intervenção do Poder Judiciário tem como missão precípua não a punição pura e simples do adolescente em conflito com a lei, mas, principalmente, a ressocialização e a proteção do jovem infrator. Deveras, as medidas previstas nos arts. 112 a 125 da Lei n. 8.069/1990 não são penas e possuem o objetivo primordial de proteção dos direitos do adolescente, de modo a afastá-lo da conduta infracional e de uma situação de risco. Por esse motivo, deve o juiz orientar-se pelos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, definidos no art. 227 da CF e nos arts. 3º e 4º do ECA. Desse modo, postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra



o processo por ato infracional importa em "perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional". Observe-se que não se cogita equiparar o adolescente que pratica ato infracional ao adulto imputável autor de crime, pois, de acordo com o art. 228 da CF, os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos às normas da legislação especial. Por esse motivo e considerando que a medida socioeducativa não representa punição, mas mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora, não calharia a alegação de ofensa ao princípio da não culpabilidade, previsto no art. 5º, LVII, da CF, sua imediata execução. Nessa linha intelectual, ainda que o adolescente infrator tenha respondido ao processo de apuração de prática de ato infracional em liberdade, a prolação de sentença impondo medida socioeducativa de internação autoriza o cumprimento imediato da medida imposta, tendo em vista os princípios que regem a legislação menorista, um dos quais, é o *princípio da intervenção precoce na vida do adolescente*, positivado no parágrafo único, VI, do art. 100 do ECA. Frise-se que condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional. Ademais, a despeito de haver a Lei n. 12.010/2009 revogado o inciso VI do art. 198 do referido Estatuto, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos - e não obstante a nova redação conferida ao *caput* do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012 - é importante ressaltar que continua a vigor o disposto no art. 215 do ECA, o qual prevê que "O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". Ainda que referente a capítulo diverso, não há impedimento a que, supletivamente, se invoque tal dispositivo para entender que os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, repita-se, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista. Pondere-se, ainda, ser de fundamental importância divisar que, ante as características singulares do processo por ato infracional - sobretudo a que determina não poder o processo, em caso de internação provisória, perdurar por mais de 45 dias (art. 183 do ECA) - não é de se estranhar que os magistrados evitem impor medidas cautelares privativas de liberdade, preferindo, eventualmente, reservar para o momento final do processo - quando, aliás, disporá de elementos cognitivos mais seguros e confiáveis para uma decisão de tamanha importância - a escolha quanto à medida socioeducativa que se mostre mais adequada e útil aos propósitos ressocializadores de tal providência. Sob outra angulação, não seria desarrazoado supor que, a prevalecer o entendimento de que somente poderá o juiz impor ao adolescente o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação fixada na sentença se já estiver provisoriamente internado, haverá uma predisposição maior, pela autoridade processante, de valer-se dessa medida cautelar antes da conclusão do processo. Em suma, há de se conferir à hipótese em análise uma interpretação sistêmica, compatível com a doutrina de proteção integral do adolescente, com os objetivos a que se destinam as medidas socioeducativas e com a própria utilidade da jurisdição juvenil, que não pode reger-se por normas isoladamente consideradas. (HC 346.380-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/4/2016, DJe 13/5/2016 – Informativo n. 583.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EM ATOS INFRACIONAIS. A prática de ato infracional durante a adolescência pode servir de



fundamento para a decretação de prisão preventiva, sendo indispensável para tanto que o juiz observe como critérios orientadores: a) a particular gravidade concreta do ato infracional, não bastando mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) a distância temporal entre o ato infracional e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito policial) no qual se deve decidir sobre a decretação da prisão preventiva; e c) a comprovação desse ato infracional anterior, de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência. (RHC 63.855-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016, DJe 13/6/2016 (Informativo n.583).

Em sentido aposto ao julgado anterior: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS NÃO JUSTIFICA PRISÃO PREVENTIVA. No processo penal, o fato de o suposto autor do crime já ter se envolvido em ato infracional não constitui fundamento idôneo à decretação de prisão preventiva. Isso porque a vida na época da menoridade não pode ser levada em consideração pelo Direito Penal para nenhum fim. Atos infracionais não configuram crimes e, por isso, não é possível considerá-los como maus antecedentes nem como reincidência, até porque fatos ocorridos ainda na adolescência estão acobertados por sigilo e estão sujeitos a medidas judiciais exclusivamente voltadas à proteção do jovem. Por conseguinte, a prática de atos infracionais não serve de lastro para a análise de uma pretensa personalidade voltada à prática de crimes hábil a justificar ameaça a garantia da ordem pública. Portanto, o cometimento de atos infracionais somente terão efeito na apuração de outros atos infracionais, amparando, v.g., a internação (art. 122, II, do ECA), e não a prisão preventiva em processo criminal. HC 338.936-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016. (Informativo 576)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI N. 8.069/90 (ECA) E DA RESOLUÇÃO N. 40/33 DA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. DESCUMPRIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. A decisão judicial que impõe à Administração Pública o restabelecimento do plantão de 24 horas em Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude não constitui abuso de poder, tampouco extrapola o controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. (REsp 1.612.931-MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por maioria, julgado em 20/6/2017, DJe 7/8/2017 – Informativo n. 609)

A depender das particularidades e circunstâncias do caso concreto, pode ser aplicada, com fundamento no art. 122, II, do ECA, medida de internação ao adolescente infrator que antes tenha cometido apenas uma outra infração grave. Dispõe o art. 122, II, do ECA que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível "por reiteração no cometimento de outras infrações graves". Sobre o tema, destaquem-se os seguintes ensinamentos trazidos por doutrina: "Há orientação jurisprudencial, em nosso entendimento equivocada, dando conta da necessidade da reiteração de, pelo menos, três atos infracionais graves. Chega-se a tal conclusão pelo fato de o legislador não ter usado o termo reincidência, ao qual se permitiria a prática de duas infrações. Com a devida vênia, este Estatuto fez o possível para evitar termos puramente penais. Se não usou a palavra reincidência, foi justamente para fugir ao contexto criminal, aliás, como usou ato infracional e não delito ou crime." Não há que se falar em quantificação do caráter socioeducador do ECA, seja em razão do próprio princípio da proteção integral, seja em benefício do próprio desenvolvimento do adolescente, uma vez que tais medidas não ostentam a particularidade de pena ou sanção, de modo que inexistente juízo de censura, mas, sim, preceito instrutivo, tendo em vista que exsurge, conforme doutrina, "após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja finalidade principal é educar (ou reeducar), não deixando de proteger a formação moral e intelectual do jovem". À luz do princípio da

legalidade, devemos nos afastar da quantificação de infrações, devendo, portanto, a imposição da medida socioeducativa pautar-se em estrita atenção às nuances que envolvem o quadro fático da situação em concreto. Comunga-se, assim, da perspectiva proveniente da doutrina e da majoritária jurisprudência do STF e da Quinta Turma do STJ, de modo que a reiteração pode resultar do próprio segundo ato e, por conseguinte, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá vir a culminar na aplicação da medida de internação. Precedentes citados do STJ: HC 359.609-MS, Quinta Turma, DJe 10/8/2016; HC 354.216-SP, Quinta Turma, DJe 26/8/2016; HC 355.760-SP, Quinta Turma, DJe 22/8/2016; HC 342.892-RJ, Quinta Turma, DJe 30/5/2016; HC 350.293-SP, Quinta Turma, DJe 26/4/2016; AgRg no HC 298.226-AL, Quinta Turma, DJe 18/3/2015; RHC 48.629-SP, Quinta Turma, DJe 21/8/2014; HC 287.354-SP, Sexta Turma, DJe 18/11/2014; HC 271.153-SP, Sexta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 330.573-SP, Sexta Turma, DJe 23/11/2015. Precedente citado do STF: HC 94.447-SP, Primeira Turma, DJe 6/5/2011. (HC 347.434-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016. – Informativo n. 591)

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR MAGISTRADO DOS TERMOS DE PROPOSTA DE REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. Se o representante do Ministério Público ofereceu a adolescente remissão pré-processual (art. 126, *caput*, do ECA) cumulada com medida socioeducativa não privativa de liberdade, o juiz, discordando dessa cumulação, não pode excluir do acordo a aplicação da medida socioeducativa e homologar apenas a remissão. Dispõe o art. 126, *caput*, da Lei n. 8.069/1990 (ECA) que, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do MP poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendente às circunstâncias e às consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Essa remissão pré-processual é, portanto, atribuição legítima do MP, como titular da representação por ato infracional e diverge daquela prevista no art. 126, parágrafo único, do ECA, dispositivo legal que prevê a concessão da remissão pelo juiz, depois de iniciado o procedimento, como forma de suspensão ou de extinção do processo. Ora, o juiz, que não é parte do acordo, não pode oferecer ou alterar a remissão pré-processual, tendo em vista que é prerrogativa do MP, como titular da representação por ato infracional, a iniciativa de propor a remissão pré-processual como forma de exclusão do processo, a qual, por expressa previsão do art. 127 do ECA, já declarado constitucional pelo STF (RE 248.018, Segunda Turma, DJe 19/6/2008), pode ser cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, as quais não pressupõem a apuração de responsabilidade e não prevalecem para fins de antecedentes, possuindo apenas caráter pedagógico. A medida aplicada por força da remissão pré-processual pode ser revista, a qualquer tempo, mediante pedido do adolescente, do seu representante legal ou do MP, mas, discordando o juiz dos termos da remissão submetida meramente à homologação, não pode modificar suas condições para decotar condição proposta sem seguir o rito do art. 181, § 2º, do ECA, o qual determina que, "Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar". As medidas socioeducativas em meio aberto, portanto, são passíveis de ser impostas ao adolescente em remissão pré-processual e não pode a autoridade judiciária, no ato da homologação, deixar de seguir o rito do art. 181, § 2º, do ECA e excluí-las do acordo por não concordar integralmente com a proposta do MP. Havendo discordância, total ou parcial, da remissão, deve ser observado o rito do art. 181, § 2º do ECA, sob pena de suprimir do órgão ministerial, titular da representação por ato infracional, a atribuição de conceder o perdão administrativo como forma de exclusão do processo, faculdade a ele conferida legitimamente pelo art. 126 do

ECA. (REsp 1.392.888-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, julgado em 30/6/2016, DJe 1/8/2016 – Informativo n. 587)

Jurisprudência em teses do STJ – Edição nº 54:

“A aplicação da medida de semiliberdade, a despeito do disposto no art. 120, § 2º, do ECA, não se vincula à taxatividade estabelecida no art. 122 do mesmo estatuto (Jurisprudência em teses do STJ – Edição nº 54)”

“A existência de relatório técnico favorável à progressão ou extinção de medida socioeducativa não vincula o juiz. “

“É possível a incidência do princípio da insignificância nos procedimentos que apuram a prática de ato infracional.”

“A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA, sendo vedado ao julgador dar qualquer interpretação extensiva do dispositivo.”

“A internação provisória prevista no art. 108 do ECA não pode exceder o prazo máximo e improrrogável de 45 dias, não havendo que se falar na incidência da Súmula n. 52 do STJ.”

“A internação-sanção, imposta em razão de descumprimento injustificado de medida socioeducativa, não pode exceder o prazo de 3 (três) meses.”

“A atenuante da confissão espontânea não tem aplicabilidade em sede de procedimento relativo à apuração de ato infracional.”

“A maioria penal não implica a liberação compulsória do menor infrator, fato que somente se dá aos 21 anos nos termos do art. 121, §5º, do ECA.”

“O cumprimento de medida socioeducativa de internação em estabelecimento prisional viola o art. 123 do ECA, ainda que em local separado dos maiores de idade condenados.”

“A gravidade do ato infracional equiparado ao crime de ameaça (art. 147 do CP) não se subsume à grave ameaça exigida para a aplicação da medida de internação (art. 122, I, do ECA).”

“Os atos infracionais compreendidos na remissão não servem para caracterizar a reiteração nos moldes do art. 122, II, do ECA.”

QUESTÕES

- 1- Juiz Substituto – TJMS/FCC (2019)** Jorge tem 20 anos e completou 3 anos ininterruptos de cumprimento de medida de internação. Assim, de acordo com o que dispõe expressamente a lei, Jorge
- a) deverá ser imediatamente liberado, independentemente de prévia autorização judicial.
 - b) poderá ser colocado em regime de semiliberdade, liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade.
 - c) poderá ser encaminhado, excepcionalmente, a Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico caso persista a periculosidade e tenha sido decretada sua interdição.
 - d) deverá ser encaminhado a uma residência inclusiva caso não disponha de local para morar.
 - e) pode permanecer em medida de internação caso nova internação tenha sido aplicada por ato infracional praticado durante a execução.



- 2- Juiz Substituto – TJRJ/Vunesp (2019)** Com relação à responsabilidade civil de crianças e adolescentes por danos causados a terceiros, assinale a alternativa correta:
- a) Ao adolescente que cometer ato infracional com reflexos patrimoniais, poderá ser determinada obrigação de reparar o dano, possibilitada a cumulação com outra medida socioeducativa.
 - b) Violada a esfera patrimonial e extrapatrimonial de terceiro, por ato voluntário de crianças ou adolescentes, a autoridade competente poderá determinar às crianças e aos adolescentes a medida socioeducativa de reparar o dano.
 - c) Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, se impossível a restituição da coisa e o ressarcimento do dano, a medida socioeducativa será substituída pela realização de tarefas remuneradas de interesse geral, pelo adolescente, desde que maior de catorze anos e respeitadas as suas aptidões, e o valor apurado será usado no ressarcimento da vítima.
 - d) Como ocorre com a advertência, a obrigação de reparar o dano exige prova de materialidade e indícios de autoria da infração, diante da possibilidade de ressarcimento de valores ao atingimento da maioridade civil, não só pela criança como pelo adolescente.
 - e) Com a reparação do dano, extingue-se a obrigação, cabendo ao Poder Judiciário a fiscalização indireta da medida socioeducativa e restando a execução direta sob responsabilidade da entidade de atendimento.
- 3- Juiz substituto – TJPA/CEBRASPE (2019)** A medida socioeducativa de internação será legítima na hipótese de
- a) o juiz constatar gravidade em abstrato da prática de ato infracional.
 - b) o menor ter praticado ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
 - c) o menor ser reincidente na prática de ato infracional.
 - d) o menor ter cometido reiteradamente infrações graves.
 - e) o menor já ter sido submetido ao regime de semiliberdade.
- 4- Promotor de Justiça – MPMG/MPGO (2019)** Para efeitos legais, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança ou adolescente. Sobre o assunto, assinale a afirmativa incorreta:
- a) O adulto privado de liberdade em virtude de medida socioeducativa de internação será obrigatoriamente colocado em liberdade aos vinte e um anos de idade, podendo a autoridade judiciária proceder de ofício, sem a oitiva do Ministério Público;
 - b) Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional;
 - c) A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não podendo exceder, em nenhuma hipótese, o prazo de 3 (três) anos²⁶;
 - d) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as medidas de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI, do ECA.
- 5- Juiz substituto – TJAL/FCC (2019)** Rogério, pela prática de ato infracional equiparado a dano (primeiro ato), recebeu remissão como forma de exclusão do processo com medida

²⁶ Atenção, em caso de unificação de penas, havendo novo ato infracional após o início da execução da internação, é possível, em tese, internação que supere 3 anos. Isoladamente é que cada internação poderá ter prazo máximo de 3 anos. Imagine-se o caso de adolescente que está internado e no curso da internação comete um ato análogo a homicídio de outro adolescente, às vésperas de completar 3 anos de internação. Nesse caso, será possível nova internação, a qual, se somada com a anterior, ultrapassará 3 anos no total.



socioeducativa de advertência. Um mês antes de completar 18 anos, Rogério é flagrado na prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (segundo ato). Segundo o que dispõe a lei, sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal e as teses de orientação jurisprudencial mais recentes divulgadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é correto afirmar que

- a) foi descabida a aplicação de advertência quando do primeiro ato, uma vez que somente a remissão suspensiva e a remissão extintiva admitem a cumulação com medida socioeducativa em meio aberto.
- b) o primeiro ato infracional (dano), compreendido na remissão, não serve para caracterizar a reiteração que autorize a internação pelo segundo ato, mas prevalece para fins de antecedentes, podendo influenciar na definição da medida mais adequada e de seu tempo de duração.
- c) a medida de semiliberdade pode ser aplicada diante do segundo ato, já que a imposição de tal medida não se vincula à taxatividade estabelecida no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) em relação à internação.
- d) é vedada, segundo a Súmula 492 do STJ, a aplicação de medida socioeducativa de internação pelo segundo ato por não comportar violência ou grave ameaça à pessoa.
- e) com o alcance da maioridade civil ou penal de Rogério, a medida a ele aplicada pelo segundo ato deve ser extinta, exceto se se tratar de medida de internação.

6- Promotor de Justiça – MPRS/MPRS (2017) Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as seguintes afirmações, relativamente às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

- () A medida de internação pela prática de ato infracional, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo de quarenta e cinco dias, prorrogáveis por igual período, por decisão fundamentada, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
- () O cumprimento de medida socioeducativa é declarado extinto quando o adolescente completa dezoito anos.
- () Ao adolescente, internado para cumprimento de medida socioeducativa, é vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento.
- () A execução das medidas socioeducativas rege-se pelo princípio da legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto, e proporcionalidade, em relação à ofensa cometida.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) V – F – V – V.
- (b) F – V – F – V.
- (c) F – F – F – V.
- (d) V – V – V – F.
- (e) F – V – F – F.

GABARITO

- 1. E
- 2. A
- 3. D
- 4. A
- 5. C
- 6. C



CAPÍTULO 9 – CONSELHO TUTELAR

Um importante órgão na promoção e fiscalização dos direitos de crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar. Trata-se de órgão do Poder Executivo Municipal.

Dispõe o art. 132 do ECA que em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 01 Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local através de pleito eleitoral para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha.

É um órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Cada conselheiro tutelar eleito é considerado agente público do poder executivo municipal que exerce um múnus público e, para ser eleito e tornar-se membro de Conselho Tutelar, é preciso atender a alguns requisitos legais:

- Idade mínima de 21 anos
- Idoneidade moral (reputação ilibada)
- Residir no município

Estes são os requisitos mínimos estabelecidos no ECA, havendo divergência quanto à possibilidade de lei municipal estabelecer mais requisitos. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, já se decidiu pela impossibilidade.

Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:

- Cobertura previdenciária;
- Direito de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
- Licença-maternidade;
- Licença-paternidade;
- Gratificação natalina (décimo terceiro).

Compete à lei orçamentária municipal prever os recursos para manutenção do Conselho Tutelar e para remuneração dos conselheiros.

As eleições para membro do Conselho Tutelar acontecem de forma unificada no Brasil no primeiro domingo de outubro do ano subsequente às eleições presidenciais, ocorrendo a posse no dia 10 de janeiro do ano seguinte.

Em razão de se tratar de um verdadeiro processo eleitoral, inclusive com o uso de urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, há inúmeras condutas vedadas durante o período eleitoral. É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

O exercício da função de conselheiro tutelar (art. 135) constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral, tal como os jurados. Em razão de alterações promovidas no ECA em 2012, não mais possuem direito à prisão especial.

São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar: marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

Estende-se o impedimento do conselheiro em relação ao juiz e ao representante do Ministério Público com atuação na vara da infância, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

São atribuições do Conselho Tutelar, dispostas no art. 136 do ECA:

- Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses de situação de risco;
- Atender e aconselhar os pais ou responsável;
- Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, bem como



representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

- Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
- Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
- Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária;
- Expedir notificações;
- Requisitar certidões de nascimento e certidões de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
- Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
- Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, §3º, II, CF (programação de TV e rádio nociva à saúde e ao meio ambiente);
- Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural;
- Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes.

Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.

Em face da autonomia do Conselho, suas decisões somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.

QUESTÕES

- 1- **Juiz substituto – TJRO/Vunesp (2019)** Considerando-se presente a situação de risco ou violação de direitos prevista no art. 98 do ECA, é correto dizer que se incluem entre as atribuições legais expressas do Conselho Tutelar, nos termos dos artigos 101 e 136 do Estatuto, dentre outras:
- a) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; aplicação de medida de advertência aos pais e à criança que praticar ato infracional; orientação, apoio e acompanhamento temporários; requisição de serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, podendo representar junto à autoridade judiciária, nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações; inclusão em programa de acolhimento familiar.
 - b) elaboração, juntamente com a entidade de acolhimento, do PIA, Plano Individual de Atendimento, visando à reintegração familiar da criança ou adolescente acolhido; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime ambulatorial; orientação, apoio e acompanhamento temporários; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; colocação em família substituta, salvo na forma de adoção.
 - c) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; orientação, apoio e acompanhamento temporários; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a



alcoólatras e toxicômanos; elaboração, juntamente com a entidade de acolhimento, do PIA, Plano Individual de Atendimento, visando à reintegração familiar da criança ou adolescente acolhido.

- d) acolhimento institucional; aplicação de medida de advertência aos pais e à criança que praticar ato infracional; colocação em família substituta, salvo na forma de adoção; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; requisição de serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, podendo representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.
- e) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; orientação, apoio e acompanhamento temporários; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente.

2- Juiz Substituto – TJPR/CEBRASPE (2019) De acordo com o ECA, o conselho tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou violação aos direitos de crianças e adolescentes, é competente, em regra, para determinar a

- a) inclusão da criança e(ou) do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente.
- b) destituição da tutela da criança e(ou) do adolescente.
- c) inclusão da criança e(ou) do adolescente em programa de acolhimento familiar.
- d) perda da guarda da criança e(ou) do adolescente.

3- Promotor de Justiça – MPPI/CEBRASPE (2019) O professor de uma escola suspeitou, durante a aula, de que um de seus alunos, de doze anos de idade, estava sendo vítima de maus-tratos. Nesse caso, o ECA determina que o caso seja obrigatoriamente reportado:

- a) ao Ministério Público
- b) ao conselho tutelar.
- c) ao juízo da infância e da juventude.
- d) à autoridade policial mais próxima.
- e) ao centro especializado de assistência social mais próximo.

4- Promotor de Justiça – MPPR/MPPR (2019) Assinale a alternativa **correta**:

- a) A investigação do fato e o atendimento de criança a quem se imputa a prática de ato infracional é de responsabilidade exclusiva do Conselho Tutelar.
- b) Como a tônica do procedimento para apuração de ato infracional é a celeridade, mostra-se viável a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.
- c) Toda ação socioeducativa é pública incondicionada, e o Ministério Público é o seu titular exclusivo, não havendo que se falar em ação socioeducativa privada, ainda que em caráter subsidiário.
- d) Em sede de aplicação de medida socioeducativa, havendo confissão, deve-se atenuar a imposição da medida.



- e) O cálculo da prescrição de medida socioeducativa aplicada com ou sem prazo de duração certo, por analogia, deve ter em vista o limite de 3 (três) anos previsto para a duração máxima da medida de internação.

GABARITO

1. E
2. A
3. B
4. C



CAPÍTULO 10 — A JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E SEUS PROCEDIMENTOS

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

O art. 141 garante o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Garante-se, assim, o acesso ao sistema de justiça como um todo.

A assistência judiciária gratuita, que inclui não somente o patrocínio de causas, mas orientação jurídica em geral, será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.

Para fomentar o acesso ao Poder Judiciário e facilitar o trâmite das ações relativas à infância e à juventude, todas as ações da vara da infância são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

O STJ confere interpretação restritiva a esse dispositivo: a gratuidade se estende apenas aos atos processuais em que figurem crianças e adolescentes, em benefício destes. Não alcança processos, por exemplo, para expedição de alvará para shows.

Em juízo, como também nos atos da vida civil em geral, os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 18 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Ressalte-se que o art. 142 do ECA, que traz referida previsão legal, ainda menciona 21 anos, idade em que se alcançava a maioridade civil pelo Código Civil de 1916, que vigia quando da promulgação do ECA.

O juiz dará curador especial (Defensoria Pública) à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual.

Em face de sua especificidade e autonomia, e em consonância com o disposto no item 1.4 das Regras de Beijing, dispõe o ECA no art. 145 que os Estados e o DF poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotar essas varas de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

Veja-se bem: a lei federal faculta à lei estadual criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude. Isso se dá porque a competência para tratar de organização judiciária é do Estado, e não da União.

2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

O art. 148 do ECA trata da competência material (*ratione materiae*) da Vara da Infância e da Juventude. No *caput*, são previstas situações em que a competência será sempre da vara da infância, independentemente da situação da criança e do adolescente. Veja-se:

- Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
- Conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;
- Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
- Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente;
- Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
- Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;
- Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.



O parágrafo único, por sua vez, trata de hipóteses em que, via de regra, a competência seria de outra vara (vara cível ou vara de família, a depender da organização judiciária local), porém, por estar a criança ou adolescente em situação de risco, a competência é atraída para a Vara da Infância e da Juventude. Assim, quando se tratar de criança ou adolescente em situação de risco, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

- Conhecer de pedidos de guarda e tutela;
- Conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;
- Suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
- Conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;
- Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;
- Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;
- Conhecer de ações de alimentos;
- Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

A competência territorial cível, envolvendo criança e adolescente será fixada, consoante o art. 147 do ECA:

- Pelo domicílio dos pais ou responsável;
- À falta dos pais ou responsável, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.

A competência territorial, via de regra, é relativa. No entanto, o STJ tem entendido que, no âmbito dos direitos da criança e do adolescente, a competência territorial passa a ser dotada de natureza absoluta. Isso porque há prevalência do princípio do melhor interesse da criança ou adolescente.

As duas hipóteses supracitadas (incisos I e II do art. 147 do ECA) retratam, segundo a jurisprudência, a regra do juízo imediato, isto é, aquele mais próximo do local onde se encontra o infante. Por esta razão, o princípio da *perpetuatio jurisdictionis* não se aplica nos procedimentos relativos ao ECA, consoante reiteradamente decide o STJ.

Já nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Trata-se, pois de aplicação da teoria da atividade.

Cabe destacar que mesmo que o ato infracional seja praticado contra patrimônio da União, entidade autárquica federal ou empresa pública federal, a competência não será da Justiça Federal, e sim da competência da Vara da Infância e da Juventude. De acordo com o que já decidiu o STJ, a Constituição Federal prevê somente que crimes desta natureza sejam da competência da Justiça Federal, não mencionando nada sobre atos infracionais.

A execução das medidas socioeducativas, por sua vez, poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

Em caso de infração administrativa cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Ex.: caso de injúria irrogada na televisão, atingindo todo o país. Competência para julgamento do ato infracional será o juízo da comarca da sede da emissora, ou sede da rede.

O ECA também trata da chamada competência para regular a presença de crianças e adolescentes em eventos. Dispõe o art. 149 que compete ao juiz disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em estádio, ginásio e campo desportivo; bailes ou promoções dançantes; boate ou congêneres; casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; estúdios



cinematográficos, de teatro, rádio e televisão, bem como a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios e certames de beleza.

No inciso II, é preciso a autorização do juiz, ainda que esteja acompanhada dos pais para fins de participação em espetáculos públicos ou certames de beleza.

Tanto a portaria como o alvará regulam situações concretas, não se admitindo formulações genéricas e abstratas por parte do juízo, tais como “toques de recolher” indiscriminados a infantes. Portanto, as medidas adotadas devem ser fundamentadas caso a caso, vedadas determinações de caráter geral.

A portaria regula situação concreta de forma geral, ao passo que o alvará regula a situação da criança ou do adolescente em específico. Contra essas decisões do juiz, caberá recurso de apelação.

São critérios que orientarão o juiz no momento de expedição do alvará, ou de disciplinar o caso por portaria os princípios gerais do ECA, as peculiaridades locais, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência habitual ao local, adequação do ambiente à participação ou frequência de menor, bem como a natureza do espetáculo.

Finalmente, cabe destacar que, segundo já decidiu o STJ, a Lei de organização judiciária estadual pode, no momento de criação da Vara da Infância e da Juventude, estabelecer outras competências além das fixadas no ECA, determinando inclusive a competência da vara da infância para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

3. PROCEDIMENTOS

3.1. NOÇÕES PRELIMINARES

Depois de estabelecer regras acerca da Justiça da Infância e da Juventude, traz o ECA um capítulo específico para tratar dos diversos procedimentos atinentes a tal justiça.

Inicialmente, dispõe o ECA que, aos seus procedimentos, aplicam-se o CPC e o CPP de modo subsidiário, nos casos de omissão de regra própria. Ademais, é assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

Os prazos estabelecidos no ECA e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Apenas a Defensoria Pública remanesce com prazo em dobro nos procedimentos afetos à infância.

Após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, por sua vez, questionou-se se os prazos não deveriam seguir a regra daquele diploma, contando-se em dias úteis. Cabe destacar no ponto relevante julgado disponibilizado no informativo nº 647 do STJ, segundo o qual a previsão expressa no ECA da contagem dos prazos nos ritos nela regulados em dias corridos impede a aplicação subsidiária do art. 219 do CPC/2015, que prevê o cálculo em dias úteis.

A prioridade absoluta na busca da tutela dos direitos dos infantes permite uma maior flexibilidade procedimental em seus procedimentos. Daí porque o art. 153 estabelece que se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto no ECA ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público.

Em outras palavras, quando não houver procedimento contencioso, ou seja, quando se tratar de procedimentos de jurisdição voluntária, é possível que se adotem mecanismos e medidas judiciais que, em verdade, não encontram previsão expressa em lei, desde que ouvido Ministério Público.

O disposto neste artigo, todavia, não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos.



3.2. PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E DESTITUIÇÃO DE TUTELA

O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse e terá no polo passivo um dos genitores ou ambos. São exemplos de legitimados eventuais particulares que tenham interesse na adoção ou tutela do menor. De acordo com a jurisprudência, não é necessária a intimação ou citação do guardião para participar da demanda, podendo estes, no entanto, figurarem como assistentes (se não forem os próprios autores).

Na petição inicial deverá haver a indicação da autoridade judiciária a que for dirigida; o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público; a exposição sumária do fato e o pedido e as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos.

Vale ressaltar que, a depender da situação e da gravidade do motivo, a suspensão do poder familiar poderá se dar *initio litis* (concedida liminarmente pelo magistrado). Neste caso, ficará a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.

Durante o processo, caso tenha sido deferida a suspensão do poder familiar, a criança e o adolescente serão encaminhados à entidade de acolhimento institucional ou mesmo ao acolhimento familiar, se não houver outra pessoa idônea.

Recebida a inicial, cabe ao juiz determinar, independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 da Lei²⁷, e observado o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Ademais, se os pais forem oriundos de comunidades indígenas, é obrigatória também a intervenção de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar acima mencionada.

Prosseguindo-se na formação da relação jurídica processual, o requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

Como regra, a citação será pessoal, devendo-se esgotar todos os meios para tanto. Inclusive o requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente.

Após esgotadas as tentativas, na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização.

Admite-se também a citação por hora certa. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do art. 252 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Há previsão expressa de que caso o requerido não tenha condições, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.

Se não for contestado o pedido (revelia sem presunção de veracidade) e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. Admite-se em tal caso julgamento antecipado da lide, mas que, ressalte-se, somente será admitida se realizado o estudo social ou perícia pela equipe técnica,

²⁷ “§ 10 Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda.” (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)



que é imprescindível. De toda sorte, como será visto a diante, poderá ser necessária também a oitiva do infante.

Como a revelia no caso em que se discute direito indisponível não induz a veracidade das alegações firmadas na inicial, ainda que não haja contestação, havendo necessidade, o juiz deverá proceder à dilação probatória. Assim, a autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil, ou no art. 24 do ECA.

Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida.

Ademais, afirma o ECA que é obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados. Inclusive, se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva.

Caso os pais sejam oriundos de comunidades indígenas, é obrigatória a intervenção, junto à equipe profissional, de representantes da FUNAI, observado o disposto no § 6º do art. 28 do ECA.

Se, no entanto, for apresentada a resposta pelos requeridos, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. Assim, em havendo contestação, é indispensável a dilação probatória.

Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 minutos.

Prevê o ECA que a decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Ressalte-se que quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente.

O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 dias, primando-se pela celeridade, e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta.

A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente.

Cabe destacar que se admite a cumulação de pedidos de destituição de poder familiar e adoção na mesma ação.

Em se tratando de destituição de tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil (art. 761 e 763 do CPC) e, no que couber, o disposto para a destituição de poder familiar. Ressalte-se apenas que, da conjugação de ambas leis, a doutrina majoritária entende que o prazo de contestação será de 10 dias.

3.3. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA

Abrange as hipóteses de guarda, tutela e adoção.

Basicamente, há dois procedimentos distintos: procedimento simplificado de colocação em família substituta e procedimento litigioso de colocação em família substituta

O procedimento simplificado de colocação em família substituta é aplicável quando não há contestação por parte dos pais. É o caso de pais falecidos, destituídos ou suspensos do poder



familiar, ou ainda quando aderem expressamente à determinação de colocação em família substituta. Traduz procedimento de jurisdição voluntária.

Neste caso, regra geral, basta que as partes apresentem diretamente em cartório o pedido com a qualificação completa do requerente e seu eventual cônjuge/companheiro, com anuência expressa deste; indicação de eventual do requerente com o infante, especificando ainda se tem ou não parente vivo; qualificação da criança ou adolescente e seus pais (se conhecidos); indicação do cartório da inscrição do nascimento com sua respectiva certidão, se possível; declaração sobre existência de bens/rendimentos/direitos do infante.

A petição vem assinada pelas próprias partes (requerentes), estando dispensada a assessoria de advogado ou de defensor público (art. 166 ECA). Na hipótese de concordância dos pais, o juiz:

I - na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência;

II - declarará a extinção do poder familiar.

Veja-se que como o pedido pode ser formulado sem advogado, diretamente no cartório da vara da infância, o consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida.

O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada acima e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Ademais, o consentimento somente terá validade se dado após o nascimento da criança, daí porque não se permite a adoção de nascituro.

São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações.

A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

Nos casos em que os pais se opõem à colocação da criança ou do adolescente em família substituta, será indispensável a presença de advogado e tramitará um procedimento litigioso de colocação em família substituta.

A petição inicial será recebida, determinando o juízo a realização de estudo social pela equipe interprofissional. Após, o juiz decidirá sobre a guarda provisória. Sendo caso de adoção, decidirá o juiz sobre o estágio de convivência.

Realizada a instrução processual, serão colhidos os depoimentos da família substituta, dos pais biológicos da criança ou do adolescente, sempre que possível. É indispensável o consentimento do adolescente, o qual será dado em audiência, a fim de o juiz chegar à sua conclusão.

Discute-se se é possível que a demanda traga pedidos cumulados de perda do poder familiar com adoção ou se é implícito o pedido de destituição do poder familiar quando há o pedido de adoção.

Tradicionalmente, a jurisprudência tem entendido que é necessária a cumulação. No entanto, há precedente do STJ, admitindo apenas o pedido de adoção, considerando implícito o de destituição do poder familiar.

3.4. HABILITAÇÃO DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO

Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste, segundo o teor do art. 197-A do ECA:

- Qualificação completa;



- Dados familiares;
- Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável;
- Cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
- Comprovante de renda e domicílio;
- Atestados de sanidade física e mental;
- Certidão de antecedentes criminais;
- Certidão negativa de distribuição cível.

Referida documentação tem o objetivo de verificar a vida pregressa dos requerentes e ainda aferir se haverá real vantagem ao adotando. Acerca da vida pregressa, não é qualquer crime que será impeditivo para promover a adoção, deve-se analisar casuisticamente.

Apresentada a documentação acima, será encaminhada ao Ministério Público, o qual se manifestará no prazo de 5 dias.

Na sequência, a equipe interprofissional elaborará o estudo psicossocial, que conterà subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável.

Além disso, é obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos.

Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no § 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva.

Certificada nos autos a conclusão da participação dos postulantes no programa de orientação, o juiz, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento.

Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, o juiz determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo.

Deferida a habilitação à adoção, o postulante será inscrito nos cadastros de adoção, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis.

Consoante já estudado no capítulo que tratou da adoção, a ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pelo juiz nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando.

Após habilitação dos pretendentes e inclusão no cadastro de adoção da comarca, esta habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante avaliação por equipe interprofissional. Inclusive, quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional.

Para evitar que haja inúmeras escolhas pelos pretendentes, o que pode até indicar um perfil inadequado para adoção, após 3 (três) recusas injustificadas, pelo habilitado, à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida, podendo ser determinada a exclusão.

A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, inclusive indenização por dano moral ao infante prejudicado.

Em 2017, incluiu-se no ECA o prazo máximo para conclusão da habilitação à adoção de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

3.5. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO

O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não-governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.

De acordo com VALTER KENJI ISHIDA:

embora prevista legalmente pelo art. 191, entendemos que tal previsão não acompanha a tendência de se evitar a inicialização pelo magistrado, visando-se manter o princípio da inércia da jurisdição. A atuação *ex officio* pelo juiz deve ser evitada, devendo ser iniciada por representação ministerial²⁸.

A apuração de irregularidade em entidade de atendimento é atividade administrativa, relativa ao poder de polícia do magistrado da infância e juventude. São consideradas entidades governamentais para fins de apuração de irregularidades as instituições de acolhimento e internação, bem como as entidades não governamentais que se destinam às mesmas finalidades. Não se aplica, por exemplo, a entidade de ensino, que se submete à fiscalização pela Secretaria de Educação competente.

Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada, caso em que deverá ser oficiada à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, designando prazo para a substituição. O mesmo se dará em caso de afastamento definitivo.

Após iniciado o procedimento, o dirigente da entidade será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes.

Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

Cabe destacar que antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito.

Saliente-se, que a despeito das sanções próprias para as entidades enquanto pessoa jurídica, a multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento.

3.6. INFILTRAÇÃO DE POLICIAIS PARA INVESTIGAR CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E DE ADOLESCENTE

A Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017, incluiu no ECA os artigos 190-A a 190-F para disciplinar o procedimento de infiltração de agentes de polícia para investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

²⁸ Valter Kenji Ishida. *Estatuto da criança e do adolescente – Doutrina e jurisprudência*. Salvador: JusPodium, 2019. Pg. 634.



O foco é a infiltração de agentes por meio da internet, visando combater os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D do ECA e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Código Penal.

Devem ser obedecidas as seguintes regras:

I – prévia autorização judicial circunstanciada e fundamentada, que estabeleça os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público;

II – prévio requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia que demonstre a necessidade da medida, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas;

III – a medida terá prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial.

III – deve-se demonstrar a imprescindibilidade da medida. A infiltração não será autorizada se a prova puder ser obtida por outros meios (menos gravosos).

Durante o curso da infiltração, o juiz e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação. Ao final, as informações serão encaminhadas diretamente ao juiz que autorizou a medida, que velará pelo seu sigilo. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações.

Por fim, cumpre mencionar que a lei ressaltou que não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes acima mencionados. Todavia, obviamente, se não observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados.

3.7. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

3.7.1. APREENSÃO E ENCAMINHAMENTO

A apreensão de um adolescente poderá ocorrer em duas situações somente: a) em razão de ordem judicial determinando a apreensão, ocasião em que o adolescente será apresentado ao juiz ou b) em razão de flagrante de ato infracional, situação em que adolescente é encaminhado ao delegado. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias, e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria.

Quando do flagrante, a autoridade policial deve tomar algumas providências. Se o ato infracional foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, será lavrado um Auto de Apreensão em Flagrante (AAF), caso em que as testemunhas e o adolescente serão ouvidos, bem como haverá a apreensão do produto e dos instrumentos da infração. O delegado também poderá requisitar exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria.

Se o ato infracional foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o delegado poderá optar por realizar um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC).

Após tais providências, comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato.

A liberação pela autoridade policial não ocorrerá quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Nesse caso, o delegado encaminhará o adolescente ao Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de

ocorrência. Sendo impossível a apresentação imediata, o Delegado encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, caso em que esta que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Se não houver entidade de atendimento na localidade, a apresentação ao Ministério Público será feita pela autoridade policial.

Não havendo repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de 24 horas.

3.7.2 FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Apresentado o adolescente ao promotor de justiça, este deverá ouvir informalmente o adolescente e, se possível, ouvir os pais, a vítima e as testemunhas do fato, a fim de que possa formar a sua convicção.

Duas são as finalidades dessa oitiva informal, prevista no art. 179 do ECA: privilegiar a autodefesa do adolescente e formar a convicção do membro do Ministério Público, especialmente quanto à caracterização ou não do ato infracional e sua autoria, bem como possibilidade ou não de oferecimento de remissão ministerial.

De acordo com a jurisprudência, a oitiva informal não se mostra indispensável para fins de oferecimento da representação. Não se trata sequer de condição de procedibilidade para oferecimento de representação.

O STJ decidiu que o adolescente deve ser ouvido na presença dos pais, principalmente se é colhida confissão em tal audiência. De todo modo, trata-se de nulidade relativa, devendo haver prova do prejuízo.

Ademais, já decidiu o STJ que o defensor do adolescente possui o direito de acompanhar a oitiva informal, mas não o de fazer perguntas, uma vez que inexistente contraditório.

Em caso de não apresentação, o Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.

Realizada a apresentação do adolescente em oitiva informal, o Ministério Público poderá adotar três medidas possíveis:

- Promover o arquivamento dos autos;
- Conceder a remissão;
- Representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa.

O Ministério Público promove o arquivamento dos autos quando chega à conclusão de que o adolescente não praticou o ato infracional, de que o fato não aconteceu, ou aconteceu, mas não se trata de ato infracional.

Na remissão, o Ministério Público constata que foi praticado o ato e que o ato foi praticado pelo adolescente, mas opta por não oferecer representação. Será própria a remissão, se o Ministério Público não oferecer nenhuma medida socioeducativa, concedendo simplesmente o perdão, ao passo que será imprópria caso sejam oferecidas medidas socioeducativas, caso em que haverá necessidade de homologação judicial.

Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.

Tanto no arquivamento quanto na remissão, o juiz poderá não se convencer das razões do Ministério Público, situação na qual o juiz remeterá os autos ao PGJ, podendo este:

- Oferecer representação
- Designar outro membro do Ministério Público para apresentar
- Ratificar o arquivamento ou a remissão, situação na qual estará o juiz obrigado a homologar.

Caso o representante do Ministério Público não promova o arquivamento ou conceda a remissão, deverá oferecer representação, mediante petição, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada.



Na representação, deve constar o breve resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.

A representação, para fins de aplicação de medida socioeducativa, independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade.

O ECA não regulamentou a natureza da ação socioeducativa, tal qual existe no âmbito criminal (ações penais pública e ações penais privadas). Prevalece o entendimento de que a ação socioeducativa é pública incondicionada. Assim sendo, a representação da vítima não é exigida.

Há entendimento minoritário que defende a necessidade de representação da vítima nos casos de ação penal pública condicionada ou privada, uma vez que, do contrário, estar-se-ia tratando de forma mais severa e rigorosa os adolescentes infratores do que réus adultos. É o posicionamento desta autora.

O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, é de 45 dias. Esgotado o prazo, caso o procedimento não esteja concluído, o adolescente deverá ser colocado em liberdade imediata.

Oferecida a representação, o juiz profere despacho liminar positivo, verificando se a inicial está nos seus devidos termos (narra o fato, capitula o ato infracional, arrola testemunhas). Estando tudo em termos, o juízo designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação.

O adolescente e seus pais ou responsável serão citados do teor da representação, e notificados para a audiência de apresentação, devendo estar acompanhados de advogado.

Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva deles, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.

Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão.

Caso não sejam localizados os pais ou responsável, o juiz dará curador especial ao adolescente, papel a ser desempenhado pelo Defensor Público. Se o próprio adolescente não for localizado, o juiz expedirá mandado de busca e apreensão e determinará o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.

Quando o adolescente estiver internado, a sua apresentação será requisitada à entidade de atendimento, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.

Na audiência de apresentação, o adolescente será ouvido pelo juiz (espécie de interrogatório), ocasião em que poderá ficar em silêncio ou exercer sua autodefesa. Após as perguntas do juiz, o promotor de justiça fará as perguntas e, em seguida, a defesa.

Além da oitiva do adolescente, será oportunizada a fala aos pais ou ao responsável pelo adolescente, cujo objetivo é compreender o contexto familiar que está inserido.

É possível que se determine a realização de estudos psicossociais do adolescente e de sua família.

Após a verificação ampla e profunda da situação do adolescente, o juiz poderá conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo.

Não sendo o caso de remissão, após a audiência de apresentação, abre-se o prazo de 3 dias para defesa prévia e rol de testemunha, a ser feita por advogado constituído ou defensor nomeado. Depois da apresentação de defesa prévia, será marcada a audiência em continuação.

A audiência em continuação é a segunda audiência realizada no processo de apuração de ato infracional, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, será apresentado o relatório da equipe interprofissional e serão cumpridas diligências imprescindíveis.

Cabe destacar, no ponto, a súmula 342 do STJ. Se ocorreu a audiência de apresentação, e o adolescente confessou a prática do ato infracional, não se pode deixar de designar a audiência em continuação, sob pena de nulidade, devendo o juiz ouvir as testemunhas, analisar o relatório da equipe interprofissional, dentre outros. No procedimento de aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente (Súmula 342 – STJ).

Há corrente doutrinária que defende que ao final da audiência em continuação, deve ser renovada a oportunidade de o adolescente ser ouvido, para privilegiar a ampla defesa e ter a oportunidade de se manifestar ao término da instrução, tal qual já decidiu o STF que deve ser feito nos processos criminais.

Ao final da instrução na audiência em continuação, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão.

O art. 189 prevê hipóteses em que o Ministério Público terá seu pedido julgado improcedente: quando estiver provada a inexistência do fato; quando faltar prova da existência do fato; quando o fato não constituir ato infracional; quando não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Em havendo estas hipóteses, a autoridade judiciária não poderá aplicar qualquer medida socioeducativa e estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade.

Frise-se que o STJ já decidiu que no âmbito do ato infracional, aplicam-se as escusas absolutórias, bem como o princípio da insignificância.

A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita ao adolescente e ao seu defensor e, quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, e a seu defensor.

Caso seja aplicada outra medida, a intimação será feita unicamente na pessoa do defensor.

Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.

Se o adolescente disser que não quer recorrer, mas o seu defensor disser que quer recorrer, aplica-se a inteligência da Súmula 705 do STF, razão pela qual o recurso será conhecido. Prevalece o desejo daquele que quer recorrer.

4. JURISPRUDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR LEI ESTADUAL. **Lei estadual pode conferir poderes ao Conselho da Magistratura para, excepcionalmente, atribuir aos Juizados da Infância e da Juventude competência para processar e julgar crimes contra a dignidade sexual em que figurem como vítimas crianças ou adolescentes.** Embora haja precedentes do STJ em sentido contrário, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é de se seguir o entendimento assentado nas duas Turmas do STF no sentido de ser possível atribuir à Justiça da Infância e da Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Precedentes citados do STF: HC 113.102-RS, Primeira Turma, DJe 18/2/2013; e HC 113.018-RS, Segunda Turma, DJe 14/11/2013. HC 238.110-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2014 (Vide Informativo nº 529).

PROCESSO CIVIL. REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. ADOÇÃO E GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO JUÍZO IMEDIATO.

1. A determinação da competência, em casos de disputa judicial sobre a guarda - ou mesmo a adoção - de infante deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique em flexibilização de outras normas.

2. **O princípio do juízo imediato estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.**

3. **Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta.** Isso porque a

necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência.

4. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC.

5. A regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide.

6. A aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, somente é possível se - consideradas as especificidades de cada lide e sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança - ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual.

7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como competente o Juízo suscitado.

(CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011)

QUESTÕES

1- Promotor de Justiça – MPMO/MPGO (2019) A Lei n. 13.441/2017 trouxe alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentando conteúdo relativo à infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Sobre essas recentes modificações, assinale a alternativa incorreta:

a) A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D do ECA e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto -Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público.

b) A autorização para infiltração dar-se-á somente mediante requerimento da autoridade policial, ouvido o Ministério Público, e contera a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.

c) A infiltração não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial.

d) Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D do ECA e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto -Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), sendo que o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados.

2- Juiz de Direito – TJRO/Vunesp (2019) Com relação aos procedimentos para destituição do poder familiar e eventual colocação da criança ou adolescente em família substituta, conforme previstos no ECA, assinale a alternativa correta:

a) É obrigatória a oitiva em juízo dos pais na ação de destituição do poder familiar, sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados, conforme art. 161, § 4º, do ECA.

b) Nos termos do art. 166 do ECA, o juiz declarará extinto o poder familiar dos pais se eles houverem aderido ao pedido de colocação da criança ou adolescente em família substituta, desde que tal consentimento seja ratificado em audiência, na presença do Ministério Público, dispensando-se a solenidade apenas se o consentimento houver sido prestado por escrito e com firma reconhecida.

c) A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará, por si só, a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação transitada em julgado por crime hediondo, a pena igual ou superior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 23, § 2º, do ECA.

d) Conforme art. 158 do ECA, a citação dos requeridos em ação de destituição do poder familiar deverá ser pessoal, esgotando-se os meios para a localização antes da citação por edital, sendo obrigatória a expedição de ofícios para tanto.

e) Conforme art. 163 do ECA, o prazo máximo para a conclusão do procedimento de destituição do poder familiar dos pais será de 120 dias, mas a criança cujos pais forem destituídos do referido poder não poderá, se estiver acolhida em instituição, ser colocada em família substituta, para fins de adoção, antes do trânsito em julgado da destituição, vedação não aplicável aos adolescentes.

4- Juiz de direito – TJRO/Vunesp (2019) Em relação às medidas de remissão previstas nos artigos 126 a 128 do ECA, assinale a alternativa correta.

a) Uma vez iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, a concessão da remissão pelo juiz importará na suspensão ou extinção do processo, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a semiliberdade e a internação, não havendo vedação expressa para a concessão de remissão a adolescente ao qual já tenha sido aplicada medida socioeducativa pela prática de ato infracional anterior

b) O Ministério Público poderá aplicar a remissão ao adolescente não reincidente, como forma de suspensão do processo já iniciado, atendendo às circunstâncias do fato e à personalidade do adolescente, cumulando-se ou não a medida com outras em meio aberto, cabendo ao juiz a homologação ou aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal, se discordar.

c) Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias do fato e à personalidade do adolescente, podendo cumular a medida com qualquer das previstas em lei, exceto internação, mas dependerá da aceitação do adolescente e de seu representante legal.

d) A medida socioeducativa em meio aberto aplicada cumulativamente e por força da remissão suspensiva do processo só poderá ser revista até o início do efetivo cumprimento pelo adolescente, salvo na hipótese de pedido expresso dele ou de seu representante legal.

e) No caso de ato infracional equiparado a crime não punível com pena de reclusão, e comparecendo os pais ou responsáveis à delegacia de polícia, a autoridade policial poderá



aplicar diretamente a remissão pura e simples ao adolescente não reincidente, liberando-o, como forma de exclusão do processo.

5- Juiz de Direito – TJAC/FCC (2019) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990) estabelece, expressamente, como regra geral referente aos procedimentos nele regulados, que

- a) os prazos estabelecidos no ECA aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e Defensoria Pública.
- b) se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto no ECA, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias.
- c) as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas, emolumentos e honorários de sucumbência.
- d) o Ministério Público, nos processos em que for parte, será intimado para, no prazo máximo de dez dias, intervir como curador da infância e da juventude, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.
- e) as normas procedimentais previstas no ECA permitem adequação ou flexibilização, sempre que assim exigir a tutela do melhor interesse da criança e do adolescente, demonstrada em decisão judicial fundamentada.

6- Juiz Substituto – TJSC/CEBRASPE (2019) A respeito de aspectos processuais da justiça da infância e da juventude, assinale a opção correta à luz das disposições do ECA e do entendimento do STJ.

- a) O juiz, caso entenda indispensável estudo psicossocial para a formação de sua convicção, poderá determinar a intervenção de equipe interprofissional no procedimento de habilitação de pretendentes à adoção.
- b) Decretar liminarmente o afastamento provisório de dirigente de entidade de atendimento de infantes sem a oitiva prévia é vedado ao juiz.
- c) Durante o curso da ação de destituição de poder familiar, é possível a modificação da competência em razão da alteração do domicílio dos menores, o que relativiza a regra da *perpetuatio jurisdictionis*, que impõe a estabilização da competência.
- d) No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, havendo a confissão do adolescente, o juiz poderá homologar a desistência de produção de demais provas requeridas pelo MP ou pela defesa técnica.
- e) No caso de procedimentos previstos no ECA, o MP detém a prerrogativa processual de contagem em dobro dos prazos recursais.

GABARITO

1. B

2. A



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br

3. A

4. A

5. B

6. C

CAPÍTULO 11 – RECURSOS NO ECA

Recurso, segundo o JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, é “o remédio voluntário e idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”.

Dispõe o art. 198 do ECA que nos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil. Referido artigo faz menção à revogada Lei nº 5869/73, de sorte que com o advento do novo CPC (Lei nº 13105/2015), este é o diploma processual a ser aplicado.

Tais quais as ações em geral, que são isentas de custas e emolumentos, os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Cabe rememorar decisão do STJ, segundo a qual a isenção do ECA é incabível quando não figurarem no polo passivo ou ativo crianças ou adolescentes, citando-se como exemplo o caso de empresa requer alvará para a promoção de espetáculo público e a permissão de ingresso de criança desacompanhada dos pais.

Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias. Os embargos de declaração, por sua vez, devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias. Os prazos estabelecidos no ECA e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. A Defensoria Pública, por sua vez, goza de prazo em dobro em razão de sua lei orgânica.

Não há que se falar, portanto, em contagem de prazos em dias úteis, tal qual já decidiu o STJ recentemente no Informativo n. 647/2019.

Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor.

Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público.

O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer.

Em suma, são características dos recursos no sistema da infância e juventude:

- Adoção do sistema do CPC;
- Dispensa de preparo recursal;
- Prioridade no julgamento;
- Dispensa de revisor;
- Prazo em dias corridos.

A apelação no ECA terá cabimento nas regulares hipóteses do art. 1010 do CPC, além das hipóteses do art. 149 do ECA, ou seja, alvarás e portarias expedidos pelo juízo da infância. A sentença que julga ação socioeducativa também estará sujeita à apelação.

Ademais, há previsão expressa da realização de juízo de retratação na apelação antes de ser feita a remessa dos autos para o juízo *ad quem* (instância superior). Trata-se do chamado efeito iterativo em tais recursos no juízo da infância. O juiz proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias. O Agravo de Instrumento também terá efeito iterativo, permitindo o juízo de retratação.

Mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação.

A apresentação das razões de apelação (bem como de qualquer outro recurso) deve ser realizada dentro do prazo do decêndio de sua interposição. A falta de apresentação de razões leva ao não conhecimento do recurso diante do vício formal existente.



A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se:

- Tratar-se de adoção internacional ou
- Houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando.

A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.

Em relação às demais hipóteses de apelação, a regra geral é que tenham apenas efeito devolutivo. O STJ, no entanto, entendeu que é aplicável supletivamente o artigo 215 do ECA, que prevê que o juiz pode conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte, a despeito do artigo estar no Cap. VII (Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos) do Título VI (Do Acesso à Justiça). Ressalte-se que o STJ tem julgados permitindo que a medida socioeducativa determinada em sentença seja executada desde logo, de modo que a apelação terá somente efeito devolutivo.

Finalmente, com o advento do art. 942 do CPC para complementar o julgamento da apelação julgada por maioria nos procedimentos, decidiu o STJ que tal técnica poderá ser aplicada nos procedimentos relativos ao ECA, ressalvado o caso de haver julgamento não unânime favorável ao adolescente infrator, pois isso ensejaria tratamento mais gravoso ao adolescente do que ao adulto réu.

1. JURISPRUDÊNCIA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO IMEDIATO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INDEPENDENTE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. **Mesmo diante da interposição de recurso de apelação, é possível o imediato cumprimento de sentença que impõe medida socioeducativa de internação, ainda que não tenha sido imposta anterior internação provisória ao adolescente.** Cuidando-se de medida socioeducativa, a intervenção do Poder Judiciário tem como missão precípua não a punição pura e simples do adolescente em conflito com a lei, mas, principalmente, a ressocialização e a proteção do jovem infrator. Deveras, as medidas previstas nos arts. 112 a 125 da Lei n. 8.069/1990 não são penas e possuem o objetivo primordial de proteção dos direitos do adolescente, de modo a afastá-lo da conduta infracional e de uma situação de risco. Por esse motivo, deve o juiz orientar-se pelos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, definidos no art. 227 da CF e nos arts. 3º e 4º do ECA. Desse modo, postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em "perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional". Observe-se que não se cogita equiparar o adolescente que pratica ato infracional ao adulto imputável autor de crime, pois, de acordo com o art. 228 da CF, os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos às normas da legislação especial. Por esse motivo e considerando que a medida socioeducativa não representa punição, mas mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora, não calharia a alegação de ofensa ao princípio da não culpabilidade, previsto no art. 5º, LVII, da CF, sua imediata execução. Nessa linha intelectual, ainda que o adolescente infrator tenha respondido ao processo de apuração de prática de ato infracional em liberdade, a prolação de sentença impondo medida socioeducativa de internação autoriza o cumprimento imediato da medida imposta, tendo em vista os princípios que regem a legislação menorista, um dos quais, é o *princípio da intervenção precoce na vida do adolescente*, positivado no parágrafo único, VI, do art. 100 do ECA. Frise-se que condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo



ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional. Ademais, a despeito de haver a Lei n. 12.010/2009 revogado o inciso VI do art. 198 do referido Estatuto, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos - e não obstante a nova redação conferida ao *caput* do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012 - é importante ressaltar que continua a vigor o disposto no art. 215 do ECA, o qual prevê que "O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". Ainda que referente a capítulo diverso, não há impedimento a que, supletivamente, se invoque tal dispositivo para entender que os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, repita-se, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista. Pondere-se, ainda, ser de fundamental importância divisar que, ante as características singulares do processo por ato infracional - sobretudo a que determina não poder o processo, em caso de internação provisória, perdurar por mais de 45 dias (art. 183 do ECA) - não é de se estranhar que os magistrados evitem impor medidas cautelares privativas de liberdade, preferindo, eventualmente, reservar para o momento final do processo - quando, aliás, disporá de elementos cognitivos mais seguros e confiáveis para uma decisão de tamanha importância - a escolha quanto à medida socioeducativa que se mostre mais adequada e útil aos propósitos ressocializadores de tal providência. Sob outra angulação, não seria desarrazoado supor que, a prevalecer o entendimento de que somente poderá o juiz impor ao adolescente o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação fixada na sentença se já estiver provisoriamente internado, haverá uma predisposição maior, pela autoridade processante, de valer-se dessa medida cautelar antes da conclusão do processo. Em suma, há de se conferir à hipótese em análise uma interpretação sistêmica, compatível com a doutrina de proteção integral do adolescente, com os objetivos a que se destinam as medidas socioeducativas e com a própria utilidade da jurisdição juvenil, que não pode reger-se por normas isoladamente consideradas. **HC 346.380-SP**, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/4/2016, DJe 13/5/2016 (Informativo n. 583/2016).

CONTAGEM DE PRAZO. ART. 152, § 2º, DA LEI N. 8.069/1990 (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.509/2017). DIAS CORRIDOS. **INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS PREVISTA NO ART. 219 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.** Nos termos do *caput* do art. 198 do ECA, nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, com as adaptações da lei especial trazidas nos incisos do citado dispositivo legal. Assim, consoante o texto expresso no inciso II, em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo será decenal e a sua contagem ocorrerá de forma corrida, conforme expressa previsão do art. 152, § 2º, do ECA. Uma vez que existe norma sobre a contagem do prazo em dias corridos na lei especial, não há lacuna a atrair a aplicação subsidiária ou supletiva da regra do Código de Processo Civil, que prevê o cálculo em dias úteis. Eventual conflito na interpretação das leis deve ser solucionado por meio de critérios hierárquico, cronológico ou da especialidade. O Código de Processo Civil não é norma jurídica superior à Lei n. 8.069/1990. O art. 198 do ECA (redação dada pela Lei n. 12.594/2012), por sua vez, não prevalece sobre o art. 152, § 2º (incluído pela Lei n. 13.509/2017), dispositivo posterior que regulou inteiramente a contagem dos prazos. Prepondera, assim, a especialidade, de modo que a regra específica do Estatuto da Criança e do Adolescente impede a incidência do art. 219 do CPC/2015. (**HC 475.610-DE**, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)



APELAÇÃO JULGADA POR MAIORIA. **NOVA TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. ART. 198 DO ECA.** Admite-se a incidência do art. 942 do novo Código de Processo Civil para complementar o julgamento da apelação julgada por maioria nos procedimentos relativos ao estatuto do menor. Segundo o art. 198 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema do Código de Processo Civil, que prevê, atualmente, em caso de decisão por maioria, nova técnica de complementação de julgamento, com a tomada de outros votos em sessão subsequente ou na mesma sessão. O procedimento, em tese, nada tem de prejudicial ao menor. Ao contrário, dependendo da situação, como em caso de voto vencido favorável à tese defensiva, pode lhe ser benéfico. Não se trata, portanto, de *reformatio in pejus* indireta, uma vez que estamos diante da implementação de regra técnica de julgamento, que pode ou não resultar em decisão desfavorável à defesa. Assim, considerando os termos do art. 198 do ECA, não há, em princípio, ilegalidade no procedimento que impeça sua aplicação (AgRg no REsp 1.673.215-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018 – Informativo n. 627/2018)

EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. DECISÃO FAVORÁVEL AO MENOR INFRATOR. NÃO UNÂNIME. COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO. ARTIGO 942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. Procedimento mais gravoso que o adotado no processo criminal. Afronta às normas protetivas que regem o ECA. **É inaplicável a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente.** (REsp 1.694.248-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018 – Informativo nº 626/2018)

QUESTÕES

- 1- **Juiz de Direito – TJAC/Vunesp (2019)** Com relação ao sistema recursal adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
 - a) os recursos obedecem aos princípios fundamentais do duplo grau de jurisdição, da proibição da *reformatio in pejus*, da taxatividade e da singularidade.
 - b) os recursos serão recebidos no duplo efeito, exceção feita aos interpostos contra sentença que deferir adoção por estrangeiro.
 - c) o recorrente será dispensado do preparo, se beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, e, caso contrário, o não recolhimento das custas recursais no prazo legal implicará deserção.
 - d) as decisões sujeitas a recursos são as decisões interlocutórias e as sentenças.
- 2- **Defensor Público– DPEMA/FCC (2018)** Nas ações judiciais de competência da Justiça da Infância e Juventude, conforme previsão expressa na lei:
 - a) os recursos serão interpostos, em qualquer hipótese, no prazo de 15 dias corridos.
 - b) não se aplicam quaisquer dos efeitos da revelia, mesmos aos réus citados pessoalmente.
 - c) não se aplica a regra do prazo em dobro para a Defensoria Pública.
 - d) com exceção das ações civis fundadas em interesses individuais disponíveis, a intervenção do Ministério Público é sempre obrigatória, sob pena de nulidade.



e) há isenção de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

3- Defensor Público – DPERS/FCC (2018) A respeito do sistema recursal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar:

- a) Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, na sua integralidade.
- b) Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor, salvo quando se tratar de apelação interposta em face de sentença de procedência em ação de destituição do poder familiar.
- c) Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias.
- d) Contra decisão que indefere alvará para autorizar a entrada de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em estádio de futebol, caberá agravo de instrumento.
- e) A Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública não gozam da prerrogativa do prazo recursal em dobro, por expressa disposição legal.

GABARITO

- 1. A
- 2. E
- 3. C



CAPÍTULO 12 — MINISTÉRIO PÚBLICO, ADVOCACIA E TUTELA DE DIREITOS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público exerce essencial papel no âmbito do sistema infanto-juvenil, seja por meio de sua atuação extrajudicial, seja por sua atuação judicial, tanto como parte ou fiscal da ordem jurídica, para interceder em prol dos direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos das crianças e adolescentes.

O art. 201 do ECA, bastante cobrado em concursos, em especial do Ministério Público, traz um rol exemplificativo das atribuições do órgão:

- Conceder a remissão como forma de exclusão do processo;
- Promover e acompanhar, como fiscal da ordem jurídica, os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes.
- Promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como officiar em todos os demais procedimentos da competência da Vara da Infância e Juventude;
- Promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes em situação de risco;
- Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal (programação nociva de rádio e TV);
- Instaurar procedimentos administrativos para expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;
- Instaurar procedimentos administrativos para requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;
- Instaurar procedimentos administrativos para requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas;
- Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;
- Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
- Impetrar Mandado de Segurança, Mandado de Injunção e Habeas Corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente;
- Representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;
- Inspeccionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;
- Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições.

As atribuições expressas não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do *Parquet*. Inclusive, de se ressaltar que a legitimação do Ministério Público para ações cíveis não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem Constituição Federal e ECA.



O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente e para zelar pelos direitos e garantias legais das crianças e dos adolescentes, poderá:

- Reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;
- Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados;
- Efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.

O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo.

Nos processos judiciais em que não for parte, haverá intervenção obrigatória do Ministério Público na condição de fiscal do ordenamento jurídico. Assim, terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências. A intimação, por sua vez, será pessoal, sendo que, de acordo com posição consolidada do STJ, o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (Informativo n. 611/2017 – Recurso Repetitivo: Tema 959).

A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. A doutrina é divergente acerca do que se considera falta de intervenção. Parte entende que está satisfeita a participação do Ministério Público quando se lhe oferece oportunidade de participação (de fiscalização), bastando parar tanto sua intimação pessoal, ainda que não se manifeste. Lado outro, há quem entenda que se faz necessária a participação ativa do membro ministerial.

Segundo a jurisprudência do STJ, a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.

2. ADVOCACIA

A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata o ECA, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem.

Objetivou o legislador proporcionar todos os meios de acesso à justiça à criança e ao adolescente e ao responsável legal. Observe-se, contudo, que o legislador falou em lide, uma vez que, consoante já visto, há hipóteses de jurisdição voluntária em que se dispensa a presença de advogado.

Tal qual no âmbito criminal perante adultos, nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Caso o adolescente não tenha defensor, será nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência.

A ausência do defensor, porém, não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou apenas para o efeito do ato.

Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.

Discute-se no âmbito infracional a pertinência de habilitação de advogado para atuar como assistente de acusação. Há decisão antiga do STJ inadmitindo a figura, considerando o caráter especial do ECA e ausência de previsão legal para tanto neste microsistema.



3. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS E COLETIVOS

Na linha do que ensina VALTER KENJI ISHIDA:

a partir da segunda metade do século XX, aferiu-se a insuficiência dos chamados direitos de primeira geração (individuais) e de segunda geração (direitos de solidariedade). Questões sociais originárias das sociedades de massa passaram a exigir a disciplina de um direito denominado meta individual (...). No caso brasileiro, os primeiros projetos aparecem na década de 1980. Surgiu assim a Lei nº 7347/85 e depois a própria CF passou a disciplinar melhor a matéria. No caso do ECA, a defesa não seria apenas do direito individual da criança e do adolescente, mas também do seu interesse transindividual.²⁹

Desta feita, alguns autores reconhecem que o ECA, junto com a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, foram um tripé legislativo do microsistema de tutela de direitos e interesses transindividuais.

O ECA, valendo-se de técnica semelhante ao art. 1º da Lei da Ação Civil Pública, elenca os interesses transindividuais que são tutelados de acordo com suas disposições.

Assim reza o art. 208: regem-se pelas disposições do ECA as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

- De ensino obrigatório;
- De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
- De atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 anos de idade;
- De ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
- De programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
- De serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
- De acesso às ações e serviços de saúde;
- De escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.
- De ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes.
- De programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção.

Tais situações não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pelo ECA. Ou seja, o rol do referido art. 208 é exemplificativo e não taxativo.

Em se tratando de direito difuso e coletivo, uma característica essencial é sua imprescritibilidade, não havendo prazo para o ajuizamento da ação civil pública.

Há ainda previsão expressa a respeito de investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes. Esta deverá ser realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Tal previsão foi inserida no art. 208 por meio da Lei 11259/05, todavia, há de se destacar sua atecnia legislativa, já que a hipótese, a rigor, não se trata de tutela transindividual.

²⁹Valter Kenji Ishida. *Estatuto da criança e do adolescente – Doutrina e jurisprudência*. Salvador: JusPodium, 2019. Pg 701.



3.1 LEGITIMIDADE

A tutela dos direitos previstos no ECA poderá ser feita de forma individual, caso em que a demanda será feita pelo próprio adolescente, por intermédio de seus responsáveis legais. Lado outro, a tutela poderá também ser feita de forma coletiva. Normalmente, isto se dá por meio de Ação Civil Pública, promovida por qualquer dos seus legitimados. O art. 210 dispõe que para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente:

- Ministério Público;
- União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios;
- Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a autorização da assembleia, se houver prévia autorização estatutária.

O art. 5º da Lei de Ação Civil Pública e o art. 82 do CDC preveem outros legitimados para ajuizamento de ações coletivas, havendo entendimento doutrinário no sentido de que, por se tratar de um microsistema coletivo, tais normas aplicam-se complementarmente, de tal sorte que estes outros legitimados também poderiam ajuizar ações, caso haja pertinência temática. Não há unanimidade quanto ao posicionamento.

Cabe destacar que no bojo da ADIN 3943, julgada em 2015, o STF reconheceu legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública, ressaltando a ampliação do acesso à justiça.

Em provas de concurso, atentar se a questão está cobrando a literalidade da lei ou não. Pela literalidade, no ECA, há apenas os legitimados indicados nos itens acima, não se incluindo a Defensoria Pública.

Será admitido litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Ministérios Públicos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida o ECA.

Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. A utilização pelo legislador do verbo “poderá” indica a adoção do princípio da disponibilidade motivada da ação coletiva, ou seja, havendo um justo motivo para o não prosseguimento, poderá o Ministério Público deixar de assumir o polo passivo. É facultativa a assunção do polo ativo em tal caso, consoante a independência funcional de cada membro. Igualmente, não seria possível obrigar qualquer outro legitimado a figurar no polo ativo.

Caso o magistrado discorde da posição do membro ministerial, caberá a ele, por analogia ao art. 9º da Lei da Ação Civil Pública, encaminhar o processo ao Conselho Superior do Ministério Público.

Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta (TAC) às exigências legais. O TAC é um negócio jurídico extrajudicial com força de título executivo, firmado pelos órgãos públicos legitimados e pelo investigado. Permite a composição mais célere da situação, corroborando para a solução extrajudicial do conflito. É instrumento muito utilizado principalmente pelo Ministério Público, evidenciando seu perfil resolutivo, contrapondo-se ao antigo perfil demandante, segundo o qual, buscava-se a solução preferencialmente pela via judicial. No âmbito do Ministério Público, o TAC deverá prever cominações em caso de descumprimento (cláusula penal cominando sanções) e será homologado perante o Conselho Superior do Ministério Público.

Para defesa dos direitos e interesses protegidos pelo ECA são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Trata-se do Princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva. Em decorrência desse princípio, são cabíveis todos os tipos de tutelas no direito processual coletivo: preventivas, repressivas, condenatórias, declaratórias, constitutivas, mandamentais, executivas *latu sensu*, cautelares, etc. Em relação às ações de tutelas individuais e coletiva, serão aplicadas as normas do Código de Processo Civil.



Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto no ECA, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança.

Interessante destacar jurisprudência do TJRS segundo a qual o mandado de segurança e as ações coletivas que tratam da impugnação de eleição para membro do Conselho Tutelar não são de competência da justiça da infância, mas sim do juízo cível.

3.2. COMPETÊNCIA

Pelo teor do art. 209, as ações previstas para a tutela de direitos individuais e coletivos serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Trata-se de competência territorial com caráter absoluto.

3.3. ESPECIFICIDADES NA TUTELA COLETIVA

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Portanto, na tutela das obrigações, há preferência ao resultado específico, em detrimento do caráter indenizatório, que somente deve ser perquirido em último caso.

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da regra que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública (art. 2º da Lei 8437/92) antes da concessão da tutela antecipada contra a Fazenda. Em casos urgentes de infância, portanto, é possível a concessão de liminar, dispensada a oitiva prévia do ente público.

Para fins de coerção ao cumprimento da tutela, o juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.

As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Na órbita cível, o Ministério Público poderá propor ação de reparação de danos ou mesmo de improbidade administrativa e, na órbita administrativa, o agente ficará sujeito a procedimento que visa à aplicação de penalidades, inclusive de demissão.

Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. É o que se chama de princípio da obrigatoriedade da execução coletiva, que, em verdade, é uma regra.

Não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas nas ações relativas à tutela dos interesses individuais, difusos e coletivos.



O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do CPC, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos.

Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá (poder dever) provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção.

De posse de informações encaminhadas por terceiros ou mesmo de ofício, o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil (além de outras espécies de expediente, tais como notícia de fato, procedimento preparatório, procedimento administrativo de tutela de interesses individuais, cujo regramento se dá no âmbito interno de cada Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, vide Resolução nº 147, de 4 de julho de 2017 do CNMP).

Poderá ainda requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez dias úteis.

Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil, fazendo-o fundamentadamente.

Os autos do inquérito civil arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito.

Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Veja-se que é o mesmo órgão que tem a incumbência de homologar TAC e de analisar a remessa judicial referente aos casos em que o membro do Ministério Público deixou de dar prosseguimento em ação coletiva abandonada ou em que houve desistência da parte.

No mais, cidadãos em geral que sejam tenham algum interesse para fins de propor ação judicial poderão requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgarem necessárias, que serão fornecidas no prazo de quinze dias, como meio de instruir a petição inicial.

Por fim, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), refletindo a existência de um microsistema de tutela coletiva.

4. JURISPRUDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO DE ALIMENTOS EM PROVEITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). **O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente**, independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou de o infante se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. (REsp 1.265.821-BA e REsp 1.327.471-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 14/5/2014 – Informativo nº 541/2014)



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MP PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CESTA DE ALIMENTOS SEM GLÚTEN A PORTADORES DE DOENÇA CELÍACA. O Ministério Público **é parte legítima para propor ação civil pública tendo por objeto o fornecimento de cesta de alimentos sem glúten a portadores de doença celíaca**. Essa conclusão decorre do entendimento que reconhece a legitimidade do Ministério Público para a defesa da vida e da saúde, **direitos individuais indisponíveis**. AgRg no AREsp 91.114-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/2/2013 (Informativo n. 517/2013).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microsistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e **Estatuto da Criança e do Adolescente**) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

ECA. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. A questão cinge-se em saber se é possível o recurso da apelação do assistente da acusação no ECA. Consta dos autos que o menor foi representado pelo ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do CP. A sentença julgou procedente a representação, aplicando-lhe medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado e desclassificando a conduta para o ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 129, § 3º, do CP. A defesa e o assistente de acusação interpuseram apelação, tendo o tribunal local negado provimento ao recurso do menor e dado provimento ao recurso do assistente de acusação para aplicar uma medida mais rigorosa: a internação. A defesa interpôs recurso especial, sustentando contrariedade aos arts. 118, 120, 121, § 5º, 122, § 2º, e 198 do ECA e 27 do CP. O recurso foi inadmitido na origem, subindo a esta Corte por meio de provimento dado a agravo de instrumento. A Turma entendeu que, na Lei n. 8.069/1990, a figura do assistente de acusação é estranha aos procedimentos recursais da Justiça da Infância e Adolescência. **Assim, os recursos interpostos em processos de competência especializada devem seguir a sistemática do CPC, não havendo previsão legal para aplicação das normas previstas no CPP**. Dessa forma, **a disciplina estabelecida nos arts. 268 a 273 do CPP não tem aplicabilidade nos procedimentos regidos pelo ECA, que possui caráter especial, faltando, portanto, legitimidade ao apelo interposto por assistente de acusação, por manifesta ausência de previsão legal**. Diante dessas e de outras considerações a Turma não conheceu do recurso e concedeu o *habeas corpus* de ofício, para anular o acórdão referente à apelação do assistente de acusação restabelecendo o *decisum* de primeiro grau. Precedentes citados: REsp 1.044.203-RS, DJe 16/3/2009, e REsp 605.025-MG, DJ 21/11/2005. (REsp 1.089.564-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/3/2012 - Informativo n. 493)

É constitucional a Lei nº 11448/2007, que alterou a Lei nº 7347/85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. (STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 – Informativo nº 784/2015).



QUESTÕES

- 1- Promotor de Justiça – MPMT/FCC (2019)** Na área da Infância e Juventude, se o Promotor de Justiça, esgotadas todas as diligências, não ajuizar demanda coletiva, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação, fundamentadamente, e
- a) encaminhará os autos, no prazo de três dias, à Corregedoria-Geral do Ministério Público, sob pena de falta grave.
 - b) encaminhará os autos ao arquivo da Promotoria de Justiça onde exerce suas atribuições.
 - c) submeterá essa deliberação à apreciação judicial, a quem competirá dar a última palavra sobre a decisão adotada.
 - d) encaminhará os autos, no prazo de três dias, à Procuradoria-Geral de Justiça, sob pena de falta grave.
 - e) encaminhará os autos, no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, sob pena de falta grave.
- 2- Defensor Público – DPEMG/FUNDEP (2019)** Com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, analise as afirmativas a seguir.
- I. Nos processos sujeitos ao ECA, prevalece de forma absoluta o princípio da perpetuação da jurisdição, já que, nos termos do art. 43 do CPC/2015, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não havendo qualquer relevância nas modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo quando houver supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta.
 - II. A Defensoria Pública não possui atribuição para fiscalizar as unidades de internação, ficando tal incumbência, de forma exclusiva, ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselhos Tutelares, por se tratar de regra *numerus clausus*.
 - III. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente, por envolver infração presumidamente permanente e de natureza grave.
 - IV. Não há óbice à adoção feita por casal homoafetivo desde que a medida represente reais vantagens ao adotando e haja o consentimento deste, conforme art. 28, §2º, do ECA.
- Assinale a alternativa em que não se tem a correta interpretação legal e jurisprudencial.
- a) I e III, apenas.



- b) II e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV
- d) I, II e III, apenas.
- 3- Juiz de Direito – TJBA/CEBRASPE (2019)** À luz do ECA e da jurisprudência do STJ, assinale a opção correta, quanto à defesa dos interesses individuais, coletivos e difusos, às atribuições do MP, ao instituto da remissão e a garantias e aspectos processuais.
- a) Ao exibir quadro que possa criar situações humilhantes a crianças e adolescentes, uma emissora de televisão poderá sofrer penalidades administrativas, mas não será responsabilizada por dano moral coletivo, visto ser inviável a individualização das vítimas da conduta.
 - b) A legitimidade ativa do MP para ajuizar ação de alimentos em prol de criança ou adolescente tem caráter subsidiário, ou seja, surge somente quando ausente a atuação da DP no local.
 - c) A competência para processar e julgar ação civil pública ajuizada contra um estado federado na busca da defesa de crianças e adolescentes é, em regra, absoluta das varas da fazenda pública, por previsão constitucional.
 - d) Na oitiva de apresentação, o representante do MP pode conceder, sem a presença da defesa técnica, a remissão ao ato infracional. Contudo, na audiência ou no procedimento de homologação por sentença da remissão, para evitar nulidade absoluta, é obrigatória a presença de defensor.
 - e) Antes de iniciado o processo para apuração de ato infracional, o MP poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, podendo incluir qualquer medida socioeducativa, sendo a única exceção a internação.
- 4- Promotor de Justiça – MPPB/FCC (2018)** Segundo a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), eventual demanda coletiva deve ser proposta no juízo:
- a) do domicílio da criança ou adolescente, que terá competência absoluta, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
 - b) do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
 - c) da sede do legitimado ativo, ressalvada a competência da Justiça Federal e a competência dos tribunais superiores.
 - d) do domicílio do réu, ressalvada a competência da Justiça Federal e a competência dos tribunais superiores.
 - e) onde o autor escolher demandar.

GABARITO

@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



1. E

2. C

3. D

4. A

CAPÍTULO 13 – CRIMES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. INTRODUÇÃO

O art. 227, §4º da Constituição Federal contém em seu teor um mandado constitucional de criminalização (ou de tutela penal), dispondo que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. Nesses termos, o ECA deu concretude à referida normal constitucional, prevendo crimes relativos à exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outras condutas.

Veja-se, no entanto, que outros diplomas, especialmente o Código Penal, também preveem crimes envolvendo menores de idade, mas no ECA há uma preocupação maior com tais sujeitos enquanto vítimas. Assim, a tutela penal infanto-juvenil de forma alguma se restringe aos tipos penais do ECA.

De toda sorte, do art. 288 ao 244-B do ECA são previstos crimes praticados contra criança e adolescente, por ação ou omissão. Como o ECA não traz dispositivos específicos relacionados à teoria geral do crime e aplicação da pena, aplicam-se as normas da parte geral do Código Penal. Quanto ao processo, aplicam-se as normas do Código de Processo Penal.

Todos os crimes previstos no ECA são de ação penal pública incondicionada, ou seja, a titularidade da ação penal é do Ministério Público.

2. CRIMES EM ESPÉCIE

2.1. ART. 228

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.

Características principais: a modalidade do caput e do parágrafo único são infrações penais de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). São crimes omissivos próprios (os verbos implicam inação - não cabe tentativa), formais (independem de resultado naturalístico, consistente em prejuízo efetivo à criança ou seus pais), próprios (punem pessoa qualificada indicada no tipo penal, como o encarregado do serviço ou dirigente do estabelecimento), de perigo abstrato. Parágrafo único prevê modalidade culposa.

O tipo penal faz referência às obrigações contidas no art. 10 do ECA, por exemplo, manter por 18 anos registro das atividades desenvolvidas, por meio de prontuários individuais.

2.2. ART. 229

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.



Características principais: a modalidade do caput e do parágrafo único são infrações penais de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). São crimes omissivos próprios (os verbos implicam inação – não cabe tentativa), formais (independem de resultado naturalístico, consistente em prejuízo efetivo à criança ou seus pais), próprios (punem pessoa qualificada indicada no tipo penal, como o encarregado do serviço ou dirigente do estabelecimento), de perigo abstrato. Parágrafo único prevê modalidade culposa.

O tipo penal faz referência às obrigações contidas no art. 10 do ECA, por exemplo, realizar exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido.

2.3. ART. 230

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.

Características principais: infrações penais de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa, não precisa ser autoridade), material (dependem de resultado naturalístico, consistente na efetiva privação da liberdade em prejuízo efetivo à criança ou seus pais), doloso, permanente (a consumação se protraí no tempo enquanto mantida a privação da liberdade).

2.4. ART. 231

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Características principais: infração penal de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime próprio (autoridade policial somente), formal (independe de resultado naturalístico, consistente em prejuízo à criança ou seus pais), omissivo (os verbos implicam inação – não cabe tentativa), de perigo abstrato.

2.5. ART. 232

“Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: Pena - detenção de seis meses a dois anos.”

Características principais: infração penal de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime próprio (somente quem possua alguma autoridade ou exerça guarda ou vigilância sob o infante), material (depende de resultado naturalístico, consistente na efetiva prática de ato que exponha a vexame ou constrangimento), comissivo. Tentativa cabível.



2.6. ART. 234

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Características principais: infração penal de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime próprio (autoridade competente somente), material (depende de resultado naturalístico, consistente em não liberação após período relevante de conhecimento sobre a ilegalidade da apreensão), omissivo (os verbos implicam inação – não cabe tentativa), permanente (conduta se protraí no tempo até liberação).

2.7. ART. 235

“Art. 235 Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade: Pena - detenção de seis meses a dois anos.”

Características principais: infração penal de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime próprio (autoridade competente somente), material (depende de resultado naturalístico, consistente em não cumprir prazo em prejuízo do adolescente privado de liberdade), omissivo (os verbos implicam inação – não cabe tentativa), permanente (conduta se protraí no tempo até cumprimento do prazo em benefício do adolescente). Trata-se ainda de norma penal em branco, pois exige que o agente descumpra os prazos fixados no ECA. Ex: 45 dias de internação provisória.

2.8. ART. 236

“Art. 236 Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: Pena - detenção de seis meses a dois anos.”

Características principais: infração penal de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime comum, formal (independe de resultado naturalístico, basta que atrapalhe ou dificulte a atuação de juiz, representante do MP ou membro do Conselho Tutelar.), omissivo (os verbos implicam inação – não cabe tentativa), de perigo abstrato.

2.9. ART. 237

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.

Características principais: Crime comum, formal (independe de ocorrência de resultado naturalístico, consistente em efetivo prejuízo para o menor com a inserção em lar substituto. Se isso ocorre, há exaurimento do crime, segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI³⁰), forma livre. Há o especial fim

³⁰ Guilherme de Souza Nucci. *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2*. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 12ª Ed. pg 106.



de agir, consistente colocação em lar substituto. Trata-se de norma penal em branco, pois o conceito de lar substituto é extraído do próprio ECA.

2.10. ART. 238

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

Características: infração de médio potencial ofensivo (cabe apenas suspensão condicional do processo). Crime próprio no *caput*, pois só quem tem o filho ou pupilo poderá promover ou efetivar a entrega. No parágrafo, o crime comum, pois qualquer um poderá oferecer ou efetivar a paga ou recompensa. Crime comissivo, formal (nas modalidades prometer) e material (na modalidade efetivar, em que se exige a efetiva entrega da criança ou adolescente), doloso e instantâneo. De acordo com Nucci, os tipos penais buscam evitar o tráfico de crianças e adolescentes, mediante paga ou recompensa, punindo tanto quem promete e entrega seu infante quanto quem busca o infante mediante paga ou recompensa³¹.

2.11. ART. 239

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.

Tipo penal que visa coibir o tráfico internacional de crianças.

Características: crime comum, formal (se o infante for ao exterior, é apenas exaurimento do crime), de forma livre. Considera-se norma penal em branco diante da referência à violação de formalidades legais sobre envio de criança ou adolescente ao exterior, cuja previsão está no próprio ECA.

Segundo Nucci³², conforme o caso, respeitado o disposto no art. 109, inciso V da Constituição Federal, será caso de competência da Justiça Federal. Ainda, de acordo com o mesmo autor, referido tipo penal, por ser mais abrangente e especial, revogou tacitamente o tipo do art. 245, §2º do Código Penal.

2.12. ART. 240

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

³¹ Guilherme de Souza Nucci. *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2*. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 12ª Ed. pg 107.

³² Guilherme de Souza Nucci. *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2*. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 12ª Ed. pg 109.



Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracenam.

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime:

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la;

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.

Os art. 240 até art. 241-E foram introduzidos no ECA pela Lei nº 11829/2008, com a finalidade precípua de acompanhar os avanços tecnológicos, especialmente considerando que tais avanços propiciam exposição visual de crianças e adolescentes em fotos, filmes e outras formas de registros de imagem e som, em contexto erótico e sexualizado, em afronta aos direitos de imagem, privacidade e dignidade.

O legislador buscou, portanto, proibir envolvimento de menores em produção de entretenimento sexual, o que, segundo NUCCI, é uma forma especial e gravosa de corrupção de moral menores, e punir qualquer forma de exposição.

O tipo do art. 240 visa punir aqueles que de alguma forma produzem conteúdo envolvendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes ou ainda que atuem (contracenem) com elas na produção de tal material. É irrelevante eventual consento da vítima.

Características do tipo do art. 240: crime comum, formal (independe de resultado naturalístico, consistente em real prejuízo à formação moral de crianças e adolescentes), doloso e instantâneo).

Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar de crime único, com reprimenda mais elevada da pena base. Fala-se em tipo misto alternativo.

Admite-se o reconhecimento de erro de tipo, se houver engano do sujeito ativo quanto à idade da vítima, eliminando-se o dolo, já que o agente não terá consciência sobre a elementar criança ou adolescente. Tal tese, no entanto, por ser demasiadamente comum nas defesas, deve ser analisada com muito cuidado pelo julgador.

2.13. ART. 241

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

O presente tipo penal cuida do comerciante de material de pornografia infantil. As penas são as mesmas do tipo anterior, em que se puniam os envolvidos na produção do material.

Características do crime: crime comum, formal, comissivo, instantâneo.

Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar de crime único, com reprimenda mais elevada da pena base. Fala-se em tipo misto alternativo.

Caso sejam colocados esses registros (fotos ou vídeos) na internet, entende o STJ que o crime se consuma no momento da publicação das imagens, ou seja, aquele momento em que ocorre o

lançamento na internet do conteúdo pornográfico. Decidiu também que a competência será do local onde o material é disponibilizado, independentemente do local em que terceiros acessem. Assim, se provedor foi disponibilizado em São Paulo, ainda que alguém acesse em Manaus, a competência será da comarca de São Paulo.

Se o trânsito de fotos se der exclusivamente em território nacional, a competência será da justiça estadual, ao passo que, se houver interligação com outros países, de modo que o crime possa ter se iniciado ou finalizado no exterior, daí haverá competência da Justiça Federal, consoante o que já decidiu o STF.

2.14. ART. 241-A

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo;

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.

§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput.

Aqui neste tipo, é punido o dispersor de material pornográfico, podendo inclusive ser o sujeito que meramente as adquire para si e então compartilha com terceiros.

Classificação: crime comum, formal, comissivo. Nas modalidades “disponibilizar e divulgar” pode ser considerado crime permanente, a depender do meio utilizado pelo agente. Nos demais casos, é considerado crime instantâneo.

Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar de crime único, com reprimenda mais elevada da pena base. Fala-se em tipo misto alternativo.

O disposto no §2º, isto é, a notificação do responsável, é considerada por Nucci condição objetiva de punibilidade. O caso, por sua vez, é considerado crime a prazo, ou seja, exige-se o transcurso de um determinado prazo para sua consumação. A lei permite ao sujeito que dentro daquele período decida se consumará ou não o referido delito.

Da mesma forma que no crime do artigo anterior, há de se analisar o caso concreto e a potencial influência ao exterior para detectar a competência estadual ou federal.

2.15. ART. 241-B

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 1º A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo.



§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:

I – agente público no exercício de suas funções;

II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo;

III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.

§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido.

O criminoso, neste caso, é o consumidor da pornografia infantil; aquele que obtém o material e o guarda consigo.

Características: a figura do caput é infração de médio potencial ofensivo, cabendo suspensão condicional do processo. O parágrafo §1º trata de figura privilegiada, em que incide causa de diminuição de pena se há pequena quantidade de material. Em ambos casos, o crime é comum, formal, comissivo, instantâneo na modalidade “adquirir” e permanente nas modalidades “armazenar e possuir”.

Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar de crime único, com reprimenda mais elevada da pena base. Fala-se em tipo misto alternativo.

O parágrafo 2º traz hipóteses de excludente de ilicitude, considerando-se o exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal exposto no teor da norma, relativas a sujeitos que trabalham na proteção de infantes e repressão desse tipo de crime. De toda sorte, deverão manter sigilo sobre o material a que tiverem acesso, sob pena de também responderem por crime (especialmente o disposto no art. 241-A do ECA).

2.16. ART. 241-C

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:
Pena – reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.

A presente figura pune a bizarra situação em que o agente, desprovido de material verdadeiro, promove o simulacro necessário, realiza adulterações, alterando cenas e vídeos, por meio de programas específicos, tendo por finalidade criar imagens dissimuladas/falsas envolvendo pornografia infantil.

Características: infração de médio potencial ofensivo, cabível suspensão condicional do processo. Crime comum, formal, de forma livre, comissivo, instantâneo na maioria das modalidades, salvo em “*disponibiliza e armazena e divulga*”, a depender do caso concreto conforme o meio empregado pelo agente.



2.17. ART. 241-D

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

Veja-se que este crime abarca a conduta de quem, embora não produza o material pornográfico, é responsável pelo recrutamento da criança. Caso alguém pratique o ato libidinoso com a criança, haverá o estupro de vulnerável.

Características: infração de médio potencial ofensivo, cabível suspensão condicional do processo. Crime comum, formal, de forma livre, comissivo e instantâneo.

Por erro legislativo, não se pune a conduta de quem incorre em qualquer das condutas em prejuízo de adolescente.

2.18. NORMA PENAL EXPLICATIVA

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

Quis o legislador, pretendendo evitar contrariedades de interpretação, definir exatamente o que seria cena de sexo explícito ou pornográfica, elemento nuclear de todos os tipos anteriores. Ocorre, no entanto, que o conceito deixou de abarcar situações importantes, como por exemplo, nudez de meninas envolvendo apenas a exposição dos seios. Como os seios não são órgãos genitais, tal material não estaria abarcado pelos crimes.

Segundo crítica de Nucci³³: “infelizmente, a tentativa de tornar mais clara a redação dos tipo incriminadores trouxe redução do contexto da pornografia. Teria sido melhor permitir a interpretação dos operadores do direito em relação às cenas de sexo e, sobretudo, à cena pornográfica”.

O STJ, visando corrigir tal falha do legislador, deu interpretação ampla ao dispositivo do art. 241-E, assim decidindo:

a definição de material pornográfico acrescentada por esse dispositivo legal não restringe a abrangência do termo pornografia infanto-juvenil e, por conseguinte, deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA). Desse modo, o conceito de pornografia infanto-juvenil pode abarcar hipóteses em que não haja a exibição explícita do órgão sexual da criança e do adolescente e, nesse sentido, há entendimento doutrinário. (REsp 1543267 – Informativo 577/2016).

³³ Guilherme de Souza Nucci. *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas* – Vol. 2. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 12ª Ed. pg 136.



Inúmeras foram as críticas a tal decisão, sob o fundamento de violação à taxatividade do tipo penal. Nada obstante, é a interpretação que mais se coaduna com a proteção integral dos infantes.

2.19. ART. 242

“Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.”

Características do crime: crime comum, formal, forma livre, comissivo e instantâneo.

O referido tipo coexiste com o tipo do art. 13 do estatuto do desarmamento, já que aquele é crime omissivo e culposo. Pune-se a omissão de cautela que enseja a apropriação de arma. O tipo do art. 242 é doloso e comissivo.

2.20. ART. 243

Art. 243 Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Características: crime comum, doloso, comissivo, formal (não se exige o consumo da bebida ou substância). Infração penal subsidiária, ou seja, somente incide este tipo penal na falta de outro mais grave. Desta forma, a venda de cocaína, maconha ou outra droga para criança ou adolescente, uma vez que são substâncias que podem causar dependência física ou psíquica, ensejará punição no âmbito da Lei de Drogas.

Observe-se que, antes da alteração promovida em 2015 pela Lei nº 1.6106, a distribuição de bebida alcoólica a menor de idade configurava contravenção penal (art. 63, I da LCP). Atente-se para a proibição de retroatividade maléfica. Condutas cometidas antes da entrada em vigor da referida lei, que se deu em 17 de março de 2015, serão punidas a título de contravenção penal e não de crime do art. 243 do ECA.

2.21. ART. 244

Art. 244 Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Características do crime: infração de menor potencial ofensivo (rito sumaríssimo do JECRIM, transação penal e suspensão condicional do processo). Crime comum, formal, de forma livre, comissivo.

O tipo traz em seu bojo exceção de criminalização da conduta para elementos considerados inofensivos, tais como as famosas “biribinhas”.

2.22. ART. 244-A

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:



Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. (Redação dada pela Lei nº 13.440, de 2017) ATENÇÃO

§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo.

§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

Todo o conteúdo deste crime foi reproduzido pelo art. 218-B do Código Penal, pela grande reforma operada em 2009 por meio da Lei nº 1.2015, relativa aos crimes contra a dignidade sexual. Assim, o tipo do art. 244-A foi revogado pela alteração do Código Penal, segundo a doutrina em geral.

Em que pese a revogação tácita do tipo, em 2017 uma nova lei veio alterá-lo, passando a incluir que “além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé”. Assim, o legislador alterou o preceito secundário de um tipo penal já revogado.

De acordo com MARCIO ANDRÉ LOPES CAVALCANTE, com a vigência desta nova lei de 2017 o art. 244-A do ECA não volta a ter vigência:

Como a Lei nº 13.440/2017 alterou apenas o preceito secundário do art. 244-A, o preceito primário continua revogado. A conduta nele descrita é punida pelo art. 218-B do Código Penal. No entanto, penso que esse trecho acrescentado pela Lei nº 13.440/2017, por estar vigente e válido, pode ser utilizado pelo magistrado na sentença. Explicando melhor, o juiz, ao condenar o réu pelo art. 218-B do CP, poderá aplicar o preceito secundário do art. 244-A do ECA, ou seja, “reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé”.

2.23. Art. 244-B

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º Incorre nas penas previstas no **caput** deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

§ 2º As penas previstas no **caput** deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/90.

Este é o verdadeiro crime conhecido por corrupção de menores. Por meio deste crime, o legislador pretende proteger a formação moral de infantes, punindo aqueles que praticam crimes junto a menores de idade, pervertendo sua boa formação.

Características: crime de médio potencial ofensivo, que permite suspensão condicional do processo. Crime comum, formal, comissivo.



Súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Dessa feita, ainda que o menor de 18 anos já possua antecedentes infracionais e que convide um adulto para praticar um ato infracional consigo, o adulto responderá pelo crime do art. 244-B do ECA, em concurso formal com o outro crime.

3. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

As infrações administrativas, a toda evidência, não são crimes, não havendo pena privativa de liberdade, devendo ser aplicada apenas a pena de multa, mediante procedimento a ser julgado perante o juízo da infância. Trata-se de caso excepcional em que o Poder Judiciário exerce atipicamente atividade administrativa.

Os valores das penas de multa por infrações administrativas serão revertidos a fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente.

A prescrição de infrações administrativas se dá em 5 anos, seguindo-se as regras do direito administrativo.

As infrações administrativas são pouco cobradas nas provas de concurso, valendo, todavia, sua leitura para conhecimento.

3.1. ART. 245

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

O sujeito ativo é próprio: médico, professor ou responsável por estabelecimento. A conduta, por sua vez, é omissiva. Essa comunicação deverá ser feita ao Conselho Tutelar.

3.2. ART. 246

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos de:

Peticionar diretamente a qualquer autoridade;
Avistar-se reservadamente com seu defensor;
Receber visitas, ao menos, semanalmente;
Corresponder-se com seus familiares e amigos;
Receber escolarização e profissionalização;

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

O sujeito ativo nesse caso é funcionário de entidade em que está internado o adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa.

3.3. ART. 247

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial,



administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional.

Pena - multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º Incorre na mesma pena quem exhibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.

§2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ~~ou a suspensão da programação da emissora até por 2 dias, bem como da publicação do periódico até por dois números.~~ (Expressão declara inconstitucional pela ADIN 869-2).

Qualquer pessoa poderá praticar essa infração administrativa. A expressão riscada foi declarada inconstitucional pelo STF.

3.4. ART. 249

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar.

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

3.5. ART. 250

Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congêneres.

Pena – multa.

§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias.

§ 2º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá licença cassada.

3.6. ART. 251

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância das regras de autorização de viagem.

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

3.7. ART. 252

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.



Pena - multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

3.8. ART. 253

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem.

Pena - multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.

3.9. ART. 254

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo ~~em horário diverso de autorizado~~ ou sem aviso de sua classificação.

Pena - multa de 20 a 100 salários de referência; duplicada em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias.

O STF, no bojo da ADI 2404, julgou inconstitucional a limitação de horários, sob o argumento de que o estado não pode determinar que os programas possam ser exibidos somente em determinados horários, o que seria uma imposição, vedado pela Constituição Federal. O Poder Público pode apenas recomendar horários adequadas, sendo a classificação dos programas meramente indicativa.

3.10. ART. 255

Art. 255. Exibir filmes, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo.

Pena - multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias.

3.11. ART. 256

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.

Pena - multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias.

3.12. ART. 257

Art. 257. Descumprir obrigação de:

Comercializar revistas de material impróprio com embalagem lacrada e advertência de seu conteúdo;

Não conter em revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.



Pena - multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação.

3.13. ART. 258

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo.

Pena - multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias.

3.14. ART. 258-A

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos:

Cadastro do registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e Cadastro de pessoas interessadas na adoção

Cadastro que contenha informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade.

Pena - multa de R\$ 1.000,00 a R\$ 3.000,00.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar.

3.15. ART. 258-B

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento ao juiz de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção.

Pena - multa de R\$ 1.000,00 a R\$ 3.000,00.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.

3.16. ART. 258-C

Art. 258-C. Descumprir a proibição de vender bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.

Pena - multa de R\$ 3.000,00 a R\$ 10.000,00.

Medida administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada.



4. JURISPRUDÊNCIA

Ação direta de inconstitucionalidade. Expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente). Classificação indicativa. Expressão que tipifica como infração administrativa a transmissão, via rádio ou televisão, de programação em horário diverso do autorizado, com pena de multa e suspensão da programação da emissora por até dois dias, no caso de reincidência. Ofensa aos arts. 5º, inciso IX; 21, inciso XVI; e 220, caput e parágrafos, da Constituição Federal.

Inconstitucionalidade. 1. A própria Constituição da República delineou as regras de sopesamento entre os valores da liberdade de expressão dos meios de comunicação e da proteção da criança e do adolescente. Apesar da garantia constitucional da liberdade de expressão, livre de censura ou licença, a própria Carta de 1988 conferiu à União, com exclusividade, no art. 21, inciso XVI, o desempenho da atividade material de “exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão”. A Constituição Federal estabeleceu mecanismo apto a oferecer aos telespectadores das diversões públicas e de programas de rádio e televisão as indicações, as informações e as recomendações necessárias acerca do conteúdo veiculado. É o sistema de classificação indicativa esse ponto de equilíbrio tênue, e ao mesmo tempo tenso, adotado pela Carta da República para compatibilizar esses dois axiomas, velando pela integridade das crianças e dos adolescentes sem deixar de lado a preocupação com a garantia da liberdade de expressão. 2. A classificação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para as crianças e os adolescentes. O exercício da liberdade de programação pelas emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ao Ministério da Justiça ocorre, exclusivamente, para que a União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União para determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar uma imposição, e não uma recomendação. Não há horário autorizado, mas horário recomendado. Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de classificação, data venia, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República. 3. Permanece o dever das emissoras de rádio e de televisão de exibir ao público o aviso de classificação etária, antes e no decorrer da veiculação do conteúdo, regra essa prevista no parágrafo único do art. 76 do ECA, sendo seu descumprimento tipificado como infração administrativa pelo art. 254, ora questionado (não sendo essa parte objeto de impugnação). Essa, sim, é uma importante área de atuação do Estado. É importante que se faça, portanto, um apelo aos órgãos competentes para que reforcem a necessidade de exibição destacada da informação sobre a faixa etária especificada, no início e durante a exibição da programação, e em intervalos de tempo não muito distantes (a cada quinze minutos, por exemplo), inclusive, quanto às chamadas da programação, de forma que as crianças e os adolescentes não sejam estimulados a assistir programas inadequados para sua faixa etária. Deve o Estado, ainda, conferir maior publicidade aos avisos de classificação, bem como desenvolver programas educativos acerca do sistema de classificação indicativa, divulgando, para toda a sociedade, a importância de se fazer uma escolha refletida acerca da programação ofertada ao público infanto-juvenil. 4. Sempre será possível a responsabilização judicial das emissoras de radiodifusão por abusos ou eventuais danos à integridade das crianças e dos adolescentes, levando-se em conta, inclusive, a recomendação do Ministério da Justiça quanto aos horários em que a referida programação se



mostre inadequada. Afinal, a Constituição Federal também atribuiu à lei federal a competência para “estabelecer meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221 (art. 220, § 3º, II, CF/88). 5. Ação direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90. (STF. ADI 2404. Rel. Min. Dias Toffoli. Plenário. DJe 31/08/2016 – Informativo n. 837)

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente [artigos 241, 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990] quando praticados por meio da rede mundial de computadores. STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 - Repercussão geral (Informativo n. 805).

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PENAL. TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE FOTOGRAFIAR CENA PORNOGRÁFICA E ARMAZENAR FOTOGRAFIAS DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. **Fotografar cena e armazenar fotografia de criança ou adolescente em poses nitidamente sensuais, com enfoque em seus órgãos genitais, ainda que cobertos por peças de roupas, e incontroversa finalidade sexual e libidinosa, adequam-se, respectivamente, aos tipos do art. 240 e 241-B do ECA.** Configuram os crimes dos arts. 240 e 241-B do ECA quando subsiste **incontroversa a finalidade sexual e libidinosa de fotografias produzidas e armazenadas pelo agente**, com enfoque nos órgãos genitais de adolescente - ainda que cobertos por peças de roupas -, e de poses nitidamente sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. O art. 241-E do ECA ("Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão 'cena de sexo explícito ou pornográfica' compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais") **trouxe norma penal explicativa - porém não completa - que contribui para a interpretação dos tipos penais abertos criados pela Lei n. 11.829/2008.** Nessa linha de interpretação, **a definição de material pornográfico acrescentada por esse dispositivo legal não restringe a abrangência do termo pornografia infanto-juvenil e, por conseguinte, deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento** (art. 6º do ECA). Desse modo, o conceito de pornografia infanto-juvenil pode abarcar hipóteses em que não haja a exibição explícita do órgão sexual da criança e do adolescente e, nesse sentido, há entendimento doutrinário. Portanto, configuram os crimes dos arts. 240 e 241-B do ECA quando subsiste incontroversa a finalidade sexual e libidinosa de fotografias produzidas e armazenadas pelo agente, com enfoque nos órgãos genitais de adolescente - ainda que cobertos por peças de roupas -, e de poses nitidamente sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. REsp 1.543.267-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/12/2015, DJe 16/2/2016 (Informativo nº 577).

ART. 240 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. CRIME FORMAL. CRIME COMUM. CRIME DE SUBJETIVIDADE PASSIVA PRÓPRIA. **TIPO MISTO ALTERNATIVO.** O crime do art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA se insere no contexto de proibição da produção e registro visual, por qualquer meio, de cenas de sexo explícito, no sentido da interpretação autêntica do art. 241-F do ECA, envolvendo crianças e adolescentes, o que caracteriza violência sexual, nos termos do art. 4º da Lei n. 13.431/2017. No caso, o paciente, mediante aparelho celular, registrou imagens e filmou cenas de sexo explícito entre os corréus e duas adolescentes, o que, segundo o Tribunal *a quo*, com uma única conduta teria cometido dois crimes, incidindo em concurso formal de crimes.



Primeiramente, o fato de ter fotografado e filmado as cenas de sexo indica a execução de dois verbos, com dupla conduta, todavia, representando subordinação típica única, tendo em vista sua realização no mesmo contexto fático. Por conseguinte, da execução de mais de um verbo típico representa único crime, dada a natureza de crime de ação múltipla ou conduta variada do tipo em comento. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de unicidade de conduta, com pluralidade de resultados, não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do réu realizou dois resultados típicos, haja vista a existência de duas adolescentes filmadas e fotografadas em sexo explícito. Verifica-se, entretanto, que inexistem dois resultados típicos, porquanto **o crime em questão é formal ou de consumação antecipada, consumando-se, pois, unicamente pela prática da conduta de filmar ou fotografar cenas de sexo explícito, da qual participe criança ou adolescente. O efetivo abalo psíquico e moral por elas sofrido ou a disponibilidade das filmagens ou fotos é mero exaurimento do crime, irrelevantes para sua consumação, motivo pelo qual a quantidade de vítimas menores filmadas ou fotografadas é elemento meramente circunstancial, apto a ser valorado na pena-base, sem, contudo, indicar qualquer subsunção típica adicional.** Por conseguinte, como as condutas de filmar e fotografar foram executadas durante o mesmo contexto fático, relativo ao ato sexual conjunto de dois corréus com duas adolescentes, há duas condutas de subsunção típica única, motivo pelo qual se conclui pela existência de crime único. (PExt no HC 438.080-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 – Informativo nº 655)

ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. GRANDE INTERESSE POR MATERIAL PORNOGRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL OU PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. Cinge-se a controvérsia a decidir se o grande interesse em pornografia infantil é motivo idôneo para valorar negativamente a pena-base do réu, a título de conduta social ou personalidade do agente que cometeu o crime do art. 241-A da Lei n. 8.069/1990. Caracteriza o crime do art. 241-A do ECA oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (pena de 3 a 6 de reclusão e multa). Nesse contexto, o dado inerente ao tipo penal não justifica a exasperação da pena-base, a título de conduta social ou personalidade. **O grande interesse por material que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é ínsito ao crime descrito no art. 241-A da Lei n. 8.069/1999. O referido dado já foi sopesado pelo legislador para criminalizar a conduta e estabelecer severa sanção penal, com o objetivo, justamente, de proteger a dignidade das crianças e dos adolescentes, pondo-os a salvo de formas desviadas de satisfação sexual.** REsp 1.579.578-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020 – Informativo n. 666)

ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. CONSUNÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO. Caracteriza o crime do art. 241-A do ECA oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (pena de 3 a 6 de reclusão e multa). Já o art. 241-B do mesmo estatuto estabelece que "adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente" atrai a sanção de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Via de regra, **não**



há automática consunção quando ocorrem armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil. Deveras, o cometimento de um dos crimes não perpassa, necessariamente, pela prática do outro, mas é possível a absorção, a depender das peculiaridades de cada caso, quando as duas condutas guardem, entre si, uma relação de meio e fim estreitamente vinculadas. O princípio da consunção exige um nexo de dependência entre a sucessão de fatos. Se evidenciado pelo caderno probatório que um dos crimes é absolutamente autônomo, sem relação de subordinação com o outro, o réu deverá responder por ambos, em concurso material. (REsp 1.579.578-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020 – Informativo n. 666)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL *VERSUS* JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM PORNOGRÁFICA DE ADOLESCENTE VIA *WHATSAPP* E EM *CHAT* NO *FACEBOOK*. ART. 241-A DA LEI 8.069/1990 (ECA). INTERNACIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Cinge-se a discussão a definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual a condução de inquérito policial que investiga o cometimento, em tese, de crime de compartilhamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (art. 241-A da Lei 8.069/90), que foram trocadas por particulares, via *Whatsapp* e por meio de *chat* na rede social *Facebook*. Em 29/10/2015, a matéria foi posta a exame do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.624-MG, em sede de repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento do delito do art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (divulgação e publicação de conteúdo pedófilo-pornográfico) pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Observe-se que a constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do material pornográfico tivesse sido feita em “ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet”, independentemente da ocorrência efetiva de acesso no estrangeiro. Por sua vez, tanto no aplicativo *WhatsApp* quanto nos diálogos (*chat*) estabelecidos na rede social *Facebook*, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que não está acessível a qualquer pessoa. Assim sendo, não preenchido o requisito estabelecido pela Corte Suprema, de que a postagem de conteúdo pedófilo-pornográfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso, deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão do âmbito de divulgação e publicação do referido conteúdo, o que revela a competência da Justiça Estadual. (CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe 2/5/2017. – Informativo n. 603)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 241 DO ECA. Não tendo sido identificado o responsável e o local em que ocorrido o ato de publicação de imagens pedófilo-pornográficas em site de relacionamento de abrangência internacional, competirá ao juízo federal que primeiro tomar conhecimento do fato apurar o suposto crime de publicação de pornografia envolvendo criança ou adolescente (art. 241 do ECA). Por se tratar de site de relacionamento de abrangência internacional - que possibilita o acesso dos dados constantes de suas páginas, em qualquer local do mundo, por qualquer pessoa dele integrante - deve ser reconhecida, no que diz respeito ao crime em análise, a transnacionalidade necessária à determinação da competência da Justiça Federal. Posto isso, cabe registrar que o delito previsto no art. 241 do ECA se consuma com o ato de publicação das imagens. Entretanto, configurada dúvida quanto ao local do



cometimento da infração e em relação ao responsável pela divulgação das imagens contendo pornografia infantil, deve se firmar a competência pela prevenção a favor do juízo federal em que as investigações tiveram início (art. 72, § 2º, do CPP). (CC 130.134-TO, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 9/10/2013. – Informativo n. 532)

QUESTÕES

1- Juiz de Direito – TJMS/FCC (2020) Servidor voluntário credenciado constata a presença de adolescentes desacompanhados dos pais em um espetáculo promovido em ginásio esportivo da cidade, sem observância das regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante de tal constatação, é correto afirmar que

- a) é descabida, segundo a jurisprudência dominante no STJ, a aplicação de multa para a pessoa jurídica promotora do evento, cabendo punição apenas em face dos organizadores do espetáculo.
- b) seria possível, além da multa, segundo o texto da lei, determinar-se o fechamento do estabelecimento por até 30 dias, mas o STF declarou inconstitucional a sanção de fechamento.
- c) é lícita a aplicação de multa se o Juiz da Infância e Juventude competente não expediu alvará autorizando a realização do espetáculo.
- d) cabe ao servidor elaborar auto de infração, mas somente a autoridade judiciária é competente para eventual aplicação de multa pela suposta infração administrativa.
- e) ainda que a lei preveja apenas a autuação do organizador do espetáculo, a jurisprudência tem admitido a imposição de sanção também ao responsável pelo estabelecimento.

2- Promotor de Justiça – MPCE/CESPE (2020) Um médico atendeu em seu consultório uma criança que apresentava fraturas e hematomas por todo o corpo e alegava maus-tratos. A criança estava acompanhada de seu responsável e, por isso, o médico decidiu não comunicar à autoridade competente os maus-tratos contra a criança. Nesse caso, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta do médico:

- a) não constitui crime nem infração administrativa.
- b) constitui crime culposo com pena de detenção.
- c) constitui crime culposo com pena de multa.
- d) constitui infração administrativa com pena de multa.
- e) constitui infração administrativa com pena de cassação do registro profissional.

3- Promotor de Justiça – MPSP/Vunesp (2019) Em relação ao crime de corrupção de pessoa menor de 18 anos, assinale a alternativa correta.

- a) Se o agente maior de idade apenas induz o menor de 18 anos à prática de ato infracional, não há crime de corrupção de menor.
- b) O agente maior de idade que pratica tráfico de drogas junto de menor de 18 anos, responde por esse delito, em concurso formal com a corrupção.
- c) O agente maior de idade que pratica infração penal junto de dois menores de 18 anos não responde por duas corrupções.
- d) Segundo o STJ, o crime de corrupção de menores de 18 anos é material.



e) O agente maior de idade que pratica infração penal junto de menor de 18 anos, o qual não registrava qualquer antecedente, responde por dois delitos, em concurso formal.

4- Defensor Público – DPE-PR/FCC (2017) Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do Direito da Criança e do Adolescente, é INCORRETO afirmar que

a) se, no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir do pedido e outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de adotar unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o pedido de adoção unilateral *post mortem*.

b) na hipótese de remissão imprópria pré-processual com a concordância do adolescente, seu responsável e da sua defesa técnica, ao Juiz somente caberá homologar a remissão ou remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Caso o Procurador-Geral insista na remissão, a homologação será obrigatória, ainda que o Juiz discorde da remissão imprópria por entender que era o caso de conceder remissão pura e simples, não cabendo ao Magistrado, no caso, conceder a remissão afastando a condicionante do cumprimento de medida socioeducativa.

c) não cabe *habeas corpus* para impugnar decisão judicial liminar que determinou a busca e apreensão de criança para acolhimento em família devidamente cadastrada junto a programa municipal de adoção.

d) é constitucional a expressão “em horário diverso do autorizado”, constante no art. 254 do ECA, uma vez que o Estado pode determinar que certos programas somente sejam exibidos na televisão em horários que, presumidamente, haverá menos audiência de crianças e adolescentes. Tal entendimento tem respaldo no princípio do melhor interesse da criança.

e) caso uma sentença aplique medida de internação a adolescente, tal medida pode ser iniciada imediatamente, mesmo que esteja pendente o julgamento de apelação interposta contra a sentença e ainda que o adolescente tenha permanecido em liberdade durante toda a instrução processual.

GABARITO

1. D
2. D
3. B
4. D



CAPÍTULO 14 — DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Nas disposições finais e transitórias, o ECA buscou incentivar doações aos fundos de direitos da criança e do adolescente por meio de isenções a serem concedidas no âmbito do imposto de renda, regrando a forma como isso se procederá e atribuindo ao Ministério Público poderes para fiscalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas respectivas doações.

O art. 260 diz que os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites:

- 1% do imposto de renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e
- **6% do imposto de a renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei nº 9.532/97.**

A dedução para pessoas jurídicas acima mencionada será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto.

Além disso, a dedução não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real.

Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do:

- Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e;
- Plano Nacional pela Primeira Infância.

Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade.

O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo.

O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais aqui referidos.

A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual.

A doação acima poderá ser deduzida até 3% a partir do exercício de 2012, aplicados sobre o imposto apurado na declaração.

Essa dedução está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260.

Cabe ressaltar que a dedução não se aplica à pessoa física que:

- Utilizar o desconto simplificado;
- Apresentar declaração em formulário; ou
- Entregar a declaração fora do prazo;

Além disso, a dedução só se aplica às doações em espécie, e não excluirá ou reduzirá outros benefícios ou deduções em vigor.



O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O não pagamento da doação no prazo estabelecido implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual com os acréscimos legais previstos na legislação.

A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção de que trata o caput do art. 260, respeitado o limite previsto no inciso II do mesmo artigo.

O art. 260-B diz que a doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser deduzida do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente, bem como do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente.

A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto.

Segundo o art. 260-C, as doações de que trata o art. 260 do ECA podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Tais doações devem ser depositadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o art. 260.

Conforme o art. 260-D, os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, especificando:

- Número de ordem;
- Nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente;
- Nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador;
- Data da doação e valor efetivamente recebido; e
- Ano-calendário a que se refere a doação.

O comprovante pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês.

No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores.

Na hipótese da doação em bens, o doador deverá:

- Comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil;
- Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e
- Considerar como valor dos bens doados para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado;
- Considerar como valor dos bens doados para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens.

O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária.

Diz o art. 260-F que os documentos a que se referem os arts. 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil.

Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem:



- Manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do Fundo;
- Manter controle das doações recebidas; e
- Informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador nome, CNPJ ou CPF, e o valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens.

Em caso de descumprimento das obrigações previstas no art. 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público.

Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade:

- O calendário de suas reuniões;
- As ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente;
- Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais;
- A relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto;
- O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e
- A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais.

O Ministério Público determinará, em cada Comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no art. 260 do ECA.

O descumprimento do disposto nos arts. 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão.

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K.

Findos os aspectos relativos à isenção tributária, importante é a previsão do art. 261, segundo o qual, na falta dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, parágrafo único, e 91 do ECA serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade.

A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos no ECA, tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos seus respectivos níveis.

O art. 262 diz que, enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.

A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal promoverão edição popular do texto integral do ECA, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social.



A divulgação será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a 6 anos.



CAPÍTULO 15 — SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

1. CONCEITO DE SINASE

A Lei nº 12.594/12 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, cujo objetivo é regulamentar a execução e cumprimento das medidas socioeducativas destinadas à adolescente que pratique ato infracional. Referida lei teve como intuito primordial proporcionar um mais adequado e abrangente regramento ao cumprimento das medidas socioeducativas, atentando-se na busca de eficaz reinserção do adolescente na comunidade e também efetiva contribuição à sua formação.

De acordo com o art. 1º, §1º da lei, entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.

Traçando-se um paralelo com o sistema penal, a lei do Sinase corresponde à Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

2. OBJETIVOS DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

As medidas socioeducativas têm como objetivos:

- Responsabilizar o adolescente pela prática de ato infracional e suas consequências lesivas, sempre que possível incentivando a sua reparação;
- Promover a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento;
- Promover a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.

A necessidade de promover a integração social do adolescente é um dos objetivos traçados nas Regras de Beijing, o que reflete um objetivo pedagógico na medida socioeducativa. Ao se promover a desaprovação da conduta, fica claro o viés também sancionatório da medida.

Isso reforça a existência de um direito penal juvenil e o caráter híbrido da medida socioeducativa.

Daí porque o STJ admite, majoritariamente, que os antecedentes infracionais, os quais indicam desaprovação ante ato ilegal praticado, sejam utilizados como fundamento para a prisão preventiva de adulto, consoante retratado no Informativo 585/2016.

Nada obstante, fazendo prevalecer o vetor da integração social, também já decidiu o STJ que a participação de pessoas maiores em concursos públicos que, quando adolescente praticaram atos infracionais, é plenamente possível, eis que, se o que se busca é integrar o indivíduo à sociedade, não é possível penalizar a pessoa que quando adolescente praticou ato infracional.

3. CONCEITOS BÁSICOS DA LEI Nº 12.594/12 (ART. 1º, §§3º A 5º)

- Programa de atendimento: a organização e o funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas.
- Unidade: a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento.
- Entidade de atendimento: é a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento.



4. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Todos os entes federativos desempenham papel no bojo do Sinase. Nesse sentido, determina o art.2º que o Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos da Lei do Sinase.

4.1. UNIÃO

Compete à União:

- Formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo;
- Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os Estados/Distrito Federal e os Municípios, sendo que referido plano será submetido à deliberação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda);
- Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas;
- Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida;
- Contribuir para a qualificação e ação em rede dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo;
- Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade;
- Instituir e manter processo de avaliação dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo, seus planos, entidades e programas;
- Financiar, com os demais entes federados, a execução de programas e serviços do SINASE; e
- Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais, para financiamento de programas de atendimento socioeducativo.

À União, por sua vez, são vedados o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento.

Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do Sinase, nos termos previstos na Lei 8.242/91, que cria o referido Conselho.

Já à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República competem as funções executiva e de gestão do Sinase.

4.2. ESTADOS

Os Estados têm atribuições materiais: implantarão o sistema de atendimento socioeducativo.

A partir das diretrizes traçadas em âmbito nacional, cada Estado irá elaborar o Plano Estadual de programa socioeducativo. Nesse sentido, compete aos Estados:

- Formular, instituir, coordenar e manter Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União;
- Elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional;
- Criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação;

- Editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais;
- Estabelecer com os Municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto;
- Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos Municípios para a oferta regular de programas de meio aberto;
- Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional, nos termos previstos no inciso V do art. 88 do ECA (Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança e Assistência social);
- Garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de ato infracional;
- Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;
- Cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa privativa de liberdade.

Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, bem como deliberar sobre o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo.

Competem ao órgão a ser designado no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo as funções executivas e de gestão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo.

4.3. MUNICÍPIOS

Compete aos Municípios:

- Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;
- Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual, devendo ser submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;
- Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;
- Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;
- Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.

Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, de responsabilidade direta do município, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 11.107/05 (dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências), ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades, especialmente em conjunto com outros municípios ou com município e o Estado.

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, devendo deliberar especialmente acerca do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Competem ao órgão a ser designado no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo as funções executivas e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo.



Finalmente, destaque-se que, em razão de sua natureza jurídica, ao Distrito Federal cabem, cumulativamente, as competências dos Estados e dos Municípios.

5. PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

O Plano Nacional, elaborado pela União, deverá incluir:

a) um diagnóstico da situação do SINASE,
b) as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados no ECA.

Ademais, as normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo de adolescentes deverão constituir anexo do plano nacional.

Todos os entes políticos deverão elaborar um plano de atendimento socioeducativo (PAS), com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborando seus planos decenais correspondentes, em até 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional.

Os planos de atendimento socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados no ECA.

A fiscalização do cumprimento dos Planos de Atendimento Socioeducativos ficará a cargo do Poder Legislativo federal, estadual, distrital e municipal, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanhando a execução dos Planos de Atendimento Socioeducativo dos respectivos entes federados. Embora a lei silencie a respeito, evidente que também incumbe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento do Plano.

6. PROGRAMAS DE ATENDIMENTO

São executados por uma entidade de atendimento em uma unidade de atendimento.

Os programas de atendimento dos Estados e Distrito Federal deverão ser inscritos no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Da mesma forma, os Municípios inscreverão seus programas de atendimento, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

São requisitos obrigatórios para a inscrição de programa de atendimento no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, além da especificação do regime (art. 11):

- Exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;

- Indicação da estrutura material dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade;

- Regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:

a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores;

b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação;

c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;

- Política de formação dos recursos humanos;

- Previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;



- Indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e

- Adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.

O não cumprimento dos requisitos sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas sanções às entidades de atendimento, previstas no art. 97 do ECA (advertência, afastamento de seus dirigentes, fechamento ou interdição de unidade, interdição ou suspensão de programa, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, cassação do registro).

A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo:

- Profissionais da área da saúde;
- Profissionais da área da educação;
- Profissionais da área da assistência social.

Evidentemente, outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa.

O regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. O descumprimento da composição da equipe técnica sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no art. 97 do ECA.

Inclusive, a lei prevê como ato de improbidade administrativa a conduta de induzir ou concorrer de qualquer forma para o não cumprimento das disposições legais, vide seu art. 29.

6.1. DOS PROGRAMAS DE MEIO ABERTO

São considerados programas de meio aberto: liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Ambos são executados diretamente pelo município.

A prestação de serviços à comunidade é definida no art. 117 do ECA: “consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.”

A liberdade assistida, por sua vez, está prevista no art. 118 do ECA, sendo a medida adequada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A definição é um tanto genérica e causa dúvidas, daí porque explica a doutrina de EDUARDO ROBERTO ALCANTARA DEL-CAMPOS QUE

baseada no instituto norte-americano do *probation system*, consiste em submeter o adolescente, após sua entrega aos pais ou responsável, a uma vigilância e acompanhamentos discretos, à distância, com o fim de impedir a reincidência e obter a ressocialização. Na prática, consiste na obrigação de o adolescente infrator e seus responsáveis legais comparecerem periodicamente a um posto predeterminado e, ali, entrevistarem-se com os técnicos para informar suas atividades.

Compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida:

- selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida;
- receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa;
- encaminhar o adolescente para o orientador credenciado;
- supervisionar o desenvolvimento da medida; e

- avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção.

O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado, semestralmente, à autoridade judiciária e ao Ministério Público, para fins de controle e conhecimento.

Incumbe ainda à direção do programa de medida de prestação de serviços à comunidade selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do socioeducando e o ambiente no qual a medida será cumprida.

Se o Ministério Público impugnar o credenciamento, ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento regulamentado no ECA, devendo citar o dirigente do programa e a direção da entidade ou órgão credenciado.

6.2. DOS PROGRAMAS EM MEIO FECHADO

São programas em meio fechado a semiliberdade e a internação, cuja execução material fica a cargo do Estado.

O art. 15 da Lei do Sinase define alguns requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação:

- a comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência;
- a previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente;
- a apresentação das atividades de natureza coletiva;
- a definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no § 2º do art. 49 da lei; e
- a previsão de regime disciplinar nos termos do art. 72 da lei.

A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do Sinase, sendo terminantemente vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais.

A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor e o Ministério Público.

Preocupada com a eficiência da execução da medida socioeducativa, especialmente em razão de seu caráter pedagógico, determina o art. 17 da lei que, para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessária formação de nível superior compatível com a natureza da função; comprovada experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 (dois) anos e reputação ilibada.

7. FINANCIAMENTO

Os recursos do SINASE são oriundos de:

- Orçamento fiscal
- Seguridade social
- Outras fontes

Entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do SINASE. Então, os entes federados beneficiados com recursos do SINASE, ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas.



Os Conselhos de Direitos, nas 3 esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação.

Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo.

8. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Inúmeros são os princípios que orientam a execução das medidas socioeducativas, estando eles dispostos no art. 35 da lei:

- Princípio da legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;
- Princípio da excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;
- Princípio da prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas;
- Princípio da proporcionalidade em relação à ofensa cometida;
- Princípio da brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Princípio da individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;
- Princípio da mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;
- Princípio da não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e
- Princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.

Acerca da proibição de tratamento mais gravoso ao adolescente do que o conferido ao adulto, há uma série de decisões dos tribunais superiores. Destaque-se, por exemplo, caso em que o STF decidiu pela ilegalidade de imposição da medida socioeducativa de semiliberdade para o ato infracional análogo ao art. 28 da Lei de Drogas, já que isso implicaria em tratamento mais severo ao adolescente, em privação de liberdade, do que ao adulto, que no máximo será encaminhado à prestação de serviços à comunidade.

Ao lado dos princípios, enquanto normas de caráter fluido que permitem ampla gama de cognição do operador do direito, são positivados na lei alguns direitos e garantias aos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, vide art. 49.

Deste modo, são direitos e garantias do adolescente (art. 49):

- Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial;
- Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade (internação ou semiliberdade), exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência;
- Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença;
- Peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser respondido em até 15 dias;
- Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e das previsões de natureza disciplinar;



- Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação;
- Receber assistência integral à sua saúde;
- Ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos.

Ressalve-se que as garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas no ECA, também se aplicam integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo.

A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação da liberdade.

Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 121 do ECA (permissão de realização de atividade externa pela equipe técnica da entidade), a direção do programa de execução de medida de privação da liberdade poderá autorizar a saída, monitorada, do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, devidamente comprovados, de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente. Trata-se de instituto semelhante à permissão de saída existente na Lei de Execução Penal, mas no caso dos adolescentes cumprindo a medida, incumbe ao diretor do estabelecimento autorizar e comunicar ao juízo da infância.

A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público, privilegiando-se, desta feita, o contraditório.

8.1 PROCEDIMENTOS

Uma vez determinada em sentença a medida socioeducativa, seguir-se-á o processo de execução. A competência para processar e julgar os procedimentos de execução das medidas socioeducativas é do juízo da infância.

Ressalve-se que as medidas de proteção, de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, dispensando-se a instauração de um processo de execução.

Já para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o segredo de justiça, e com autuação das seguintes peças:

- Documentos de caráter pessoal do adolescente, especialmente os que comprovem sua idade;
- As indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente cópias da representação, da certidão de antecedentes, da sentença ou acórdão e de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.

Procedimento idêntico será observado na hipótese de medida aplicada em sede de remissão, como forma de suspensão do processo, mediante a constituição de procedimento próprio, ressaltando-se que não cabem em remissão a semiliberdade e nem internação.

O mandado de busca e apreensão do adolescente, para dar início ao cumprimento das medidas terá vigência máxima de 6 meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado, fundamentadamente.

Autuadas as peças da execução, o juiz encaminhará, imediatamente, cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida.

Em seguida, de posse do plano individual de atendimento, o juiz dará vista da proposta de ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para complementação do plano individual.

Caso haja necessidade, a impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo o juiz indeferi-la, se entender insuficiente a motivação. Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, o juiz designará, se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.

Regra geral, a impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário.

Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado.

8.2. PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

Como visto, o início da execução das medidas socioeducativas dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), especificamente para o caso de:

- Prestação de serviços à comunidade;
- Liberdade assistida;
- Semiliberdade;
- Internação.

As medidas de advertência e reparação do dano, por sua própria natureza, não depende do plano.

O objetivo do PIA, basicamente, é prever, registrar e gerir as atividades a serem desenvolvidas com o adolescente.

O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Sendo assim, o PIA deve contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, civil e criminal.

De acordo com o art. 54 da lei do Sinase, constarão do plano individual, no mínimo:

- Resultados da avaliação interdisciplinar;
- Objetivos declarados pelo adolescente;
- Previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;
- Atividades de integração e apoio à família;
- Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; e
- Medidas específicas de atenção à sua saúde.

No caso específico das medidas de semiliberdade ou de internação, o PIA será elaborado no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Neste caso, o plano individual conterá, ainda:

- Designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida;
- Definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar; e
- Fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas.

Já para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. O menor prazo nestes casos se justifica ante a menor complexidade das medidas, que não envolvem privação de liberdade e possuem menor espectro pedagógico.

Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente, podendo requisitar, ainda:

- Histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento ao estabelecimento de ensino;



- Resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento

- Resultados de acompanhamento especializado anterior.

Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual.

O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. Da mesma forma, deverá ser restrito o acesso aos relatórios subsequentes que dizem respeito ao cumprimento do PIA, ainda que não haja previsão legal expressa nesse sentido.

8.3. REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA OU PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA)

Consoante já estudado em capítulo atinente ao ato infracional e medidas socioeducativas, o ECA prevê que a medida de internação deve ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. Silencia a respeito das demais medidas.

Já que a Lei do Sinase visa justamente aprimorar o sistema de execução das medidas socioeducativas, houve por bem trazer no bojo de seu art. 42 a periodicidade com que deverão ser reavaliadas as medidas. Desta feita, dispôs que as medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses. Nada impede, porém, que seja realizada a reavaliação antes.

Poderão pedir que haja a reavaliação da medida socioeducativa, bem como do PIA, a qualquer tempo, independente de prazo mínimo:

- Direção do programa de atendimento
- Defensor
- Ministério Público
- Adolescente
- Seus pais ou responsável

Caso o juiz entenda necessário, poderá designar audiência no prazo máximo de 10 dias, cientificando-se todos os sujeitos acima.

Justificam o pedido de reavaliação, entre outros motivos (art. 43, §1º):

- Desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória;
- Inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual; e
- Necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente.

Atenção: a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave.

A autoridade judiciária poderá indeferir de pronto o pedido de alteração da medida socioeducativa, se entender insuficiente a motivação.

Há algumas peculiaridades quanto à substituição por medida mais gravosa. Esta substituição, semelhante a uma regressão de regime, ocorrerá somente em situações excepcionais, inclusive na hipótese de descumprimento reiterado de medida socioeducativa imposta, após o devido processo legal e deve ser:

- I - fundamentada em parecer técnico;
- II - precedida de prévia audiência

Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento,



assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar a transferência.

Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.

É vedado à autoridade judiciária, por expressa disposição do art. 45, §2º da Lei do Sinase:

- Determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa;
- Deixar de considerar os prazos máximos previsto no ECA (3 anos de internação, aplicável analogicamente às demais medidas);
- Deixar de considerar a liberação compulsória prevista no ECA (21 anos de idade).

Exceção: na hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução, ressalvado o caso dos 21 anos de idade.

É vedado ainda à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente (ao início da execução, de acordo com o STJ), a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.

8.4. DIREITO DE VISITA A ADOLESCENTE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO

A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa de internação observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento, sendo assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o direito à visita íntima.

Também é garantido aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade desses.

O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores.

8.5. EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

A medida socioeducativa será declarada extinta nos casos previstos no art. 46 da Lei do Sinase, que são:

- Pela morte do adolescente;
- Pela realização de sua finalidade;
- Pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva;
- Pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida;
- Nas demais hipóteses previstas em lei (atingimento do tempo máximo de duração previsto ou advento dos 21 anos, por exemplo).

No caso de o maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá ao juiz decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente.

De forma análoga, há entendimento doutrinário no sentido de que tal previsão do art. 46, §1º da Lei do Sinase também é cabível no bojo do curso da ação socioeducativa (processo de conhecimento), caso se vislumbre que não haverá qualquer finalidade pedagógica na atribuição de medida socioeducativa.

Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da medida socioeducativa.



8.6. REVISÃO JUDICIAL

O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente. A revisão judicial terá natureza jurídica de processo autônomo.

Uma vez postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, designará o juiz audiência no prazo máximo de 10 dias.

8.7. REGIMES DISCIPLINARES

Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios:

- Tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e indicação das correspondentes sanções;
- Proibição de sanções de isolamento, salvo, excepcionalmente, para garantir a segurança dos demais internos ou do próprio adolescente infrator, devendo ser comunicado ao defensor, ao Ministério Público e ao juiz em até 24 horas;
- Exigência da instauração formal de processo disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório;
- Obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de processo disciplinar;
- Sanção de duração determinada;
- Enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos para a extinção dessa;
- Enumeração explícita das garantias de defesa;
- Garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis; e
- Apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 integrantes, sendo 1, obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica.

O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha do ato cometido. Isso significa que a falta disciplinar pode ensejar a responsabilidade por novo ato infracional. Mais técnico seria o legislador se utilizasse o termo responsabilidade infracional.

Nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo.

Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. Tampouco será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta:

- I - por coação irresistível ou por motivo de força maior;
- II - em legítima defesa, própria ou de outrem.

9. JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PSICOSSOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente pela prática de ato infracional



equiparado ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP). 3. Indeferimento do pedido de progressão de medida socioeducativa para semiliberdade lastreado em fundamentação idônea, observados os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 4. O parecer psicossocial, que não se reveste de caráter vinculativo, é apenas um elemento informativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 122125, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014)

HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF), salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, bem como nos casos de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de decisões teratológicas. 2. É vedada a submissão de adolescente a tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto. 3. Em se tratando da criminalização do uso de entorpecentes, não se admite a imposição ao condenado de pena restritiva de liberdade, nem mesmo em caso de reiteração ou de descumprimento de medidas anteriormente aplicadas. Não sendo possível, por ato infracional análogo ao delito do art. 28 da Lei de drogas, a internação ou a restrição parcial da liberdade de adolescentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 119160/SP, Relator Min Roberto Barroso, 1ª Turma, data de julgamento 09/04/2014, STF)

³⁴DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EM ATOS INFRACIONAIS. A prática de ato infracional durante a adolescência pode servir de fundamento para a decretação de prisão preventiva, sendo indispensável para tanto que o juiz observe como critérios orientadores: a) a particular gravidade concreta do ato infracional, não bastando mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) a distância temporal entre o ato infracional e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito policial) no qual se deve decidir sobre a decretação da prisão preventiva; e c) a comprovação desse ato infracional anterior, de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência. RHC 63.855-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016, DJe 13/6/2016. Informativo n. 585.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 49, II, DO SINASE. O simples fato de não haver vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade em unidade próxima da residência do adolescente infrator não impõe a sua inclusão em programa de meio aberto, devendo-se considerar o que foi verificado durante o processo de apuração da prática do ato infracional, bem como os relatórios técnicos profissionais. O art. 49, II, da Lei n. 12.594/2012 (Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) dispõe que "São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei: II - ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência". No entanto, diante da necessidade de remanejamento para unidades que possuam vagas de grande

³⁴ Há julgados em sentido contrário.



quantidade de adolescentes infratores em cumprimento de medida de internação, percebe-se que a previsão contida no inciso II do art. 49 não pode ser aplicada indistintamente ou sem qualquer critério. Assim, não se mostra razoável colocar em programa de meio aberto adolescente ao qual foi aplicada corretamente a medida de internação, apenas pelo fato de não estar em unidade próxima a sua residência, deixando de lado tudo que foi verificado e colhido durante o processo de apuração, bem como os relatórios técnicos dos profissionais que estão próximos ao reeducando, identificando suas reais necessidades. Desse modo, entende-se que deve haver a relativização da regra ora em análise, devendo ser examinada caso a caso e verificada a imprescindibilidade da medida de internação, bem como a adequação da substituição da medida imposta por outra em meio aberto. A Quinta Turma do STJ, no julgamento do HC 316.435-MG (DJe 11/9/2015), por unanimidade, entendeu que, em casos excepcionais, deve-se relativizar a regra do art. 124, IV, do ECA, que dispõe que é direito do adolescente privado de liberdade "permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável". Vê-se que os dois dispositivos supracitados - art. 49, II, do SINASE e art. 124, VI, do ECA - tratam da mesma situação, qual seja, manter o adolescente em cumprimento de medida de internação em local próximo a sua residência. Conclui-se, portanto, que a regra prevista nos dois dispositivos deve ser aplicada de acordo com o caso concreto, observando-se as situações específicas do adolescente, do ato infracional praticado, bem como do relatório técnico e/ou plano individual de atendimento. HC 338.517-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016 – Informativo n. 576.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HIPÓTESE DE NÃO UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. O adolescente que cumpria medida de internação e foi transferido para medida menos rigorosa não pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução, ainda que cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpre medida socioeducativa. Dispõe o *caput* do art. 45 da Lei 12.594/2012 que: "Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo". Já em seu § 1º, tem-se que "É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução". Por sua vez, dispõe o § 2º que "É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema". Neste preceito normativo, foram traçadas as regras a serem seguidas no caso de superveniência de nova medida socioeducativa em duas situações distintas, quais sejam, por ato infracional praticado durante a execução da medida e por fato cometido antes do início do cumprimento desta. Veja-se que o § 1º do preceito aludido expressamente excepciona a aplicação de seu regramento nas hipóteses de superveniência de medida em razão de ato infracional que tenha sido "praticado durante a execução". Em seguida, em seu § 2º, o legislador fixa uma limitação à aplicação de nova medida extrema, sendo esta vedada em razão de atos infracionais "praticados anteriormente". Em uma interpretação sistemática na norma contida no § 2º, deve-se entender que esta vedação se refere à prática de ato infracional cometido antes do início da execução a que se encontra submetido o menor. Com efeito, o retorno do adolescente à internação após demonstrar que está em recuperação - que já tenha cumprido medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha apresentado méritos para progredir para medida em meio aberto - significaria um



retrocesso em seu processo de ressocialização. Deve-se ter em mente que, nos termos do ECA, em relação ao menor em conflito com a lei, não existe pretensão punitiva, mas educativa, considerando-se a "condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento" (art. 6º), sujeitos à proteção integral (art. 1º). Mister considerar, ainda, os princípios que regem a aplicação da medida socioeducativa extrema, quais sejam, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar do jovem em desenvolvimento (art. 121 do ECA), segundo os quais aquela somente deverá ser aplicada como *ultima ratio*, ou seja, quando outras não forem suficientes à sua recuperação. Conclui-se, pois, que o termo "anteriormente" contido no § 2º do art. 45 da Lei 12.594/2012 refere-se ao início da execução, não à data da prática do ato infracional que originou a primeira medida extrema imposta. HC 274.565-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/5/2015, DJe 21/5/2015 – Informativo n. 562.

QUESTÕES

1- Juiz de direito – TJMS/FCC (2020) A impugnação do Plano Individual de Atendimento, no âmbito da execução das medidas socioeducativas, conforme previsão expressa da Lei nº 12.594/2012 (Lei do Sinase),

- a) no que ultrapassa os aspectos meramente formais, deve ser fundamentada em laudo técnico.
- b) uma vez admitida, obriga a designação de audiência para oitiva do adolescente, seus pais e técnicos do programa.
- c) suspende o prazo de reavaliação obrigatória da medida socioeducativa até que seja decidido o mérito da impugnação.
- d) não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário.
- e) precede a homologação da guia de execução nas medidas socioeducativas privativas de liberdade.

2- Promotor de Justiça – MPCE/CEBRASPE (2020) Nos termos da Lei nº 12.594/2012, a função de fiscalização do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é exercida

- a) pela justiça da infância e da juventude.
- b) pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- c) pelo Ministério Público.
- d) pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
- e) pelo conselho tutelar.

3- Juiz Substituto – TJAL/FCC (2019) Segundo disposição expressa da Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE) e/ou Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), **deve** ser fundamentada em parecer técnico a decisão que

- a) substitui a medida socioeducativa mais branda por medida mais gravosa.
- b) declara extinta a medida socioeducativa pela realização de sua finalidade.
- c) autoriza as saídas externas de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade.
- d) impõe, em situações excepcionais, sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno.
- e) aplica medida socioeducativa de liberdade assistida a adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional.

4- Defensor Público – DPE-MA/FCC (2018) Sobre o regime disciplinar aplicável a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade, há previsão expressa nas



Regras Mínimas da ONU para Proteção de Jovens Privados de Liberdade e/ou na Lei nº 12.594/12 de que

- a) nenhum adolescente deve ter a seu cargo funções disciplinares, exceto no que se refere à supervisão de atividades sociais, educativas ou desportivas específicas ou em programas de autogestão.
- b) a apuração da falta disciplinar grave e a aplicação das respectivas sanções devem estar a cargo da autoridade judicial responsável pela fiscalização, supervisão e controle do estabelecimento de privação de liberdade.
- c) não será permitida a aplicação de sanções coletivas, exceto em casos de motim generalizado nos quais não seja possível individualizar a conduta de cada adolescente envolvido.
- d) pode ser dispensada a instauração formal de processo disciplinar para apuração de faltas leves cuja pena máxima prevista seja a advertência verbal.
- e) a suspensão das atividades de escolarização e profissionalização resultantes da aplicação de sanção disciplinar não podem ultrapassar o prazo máximo de 15 dias, exceto em casos de manifesta periculosidade atestada por laudo criminológico.

GABARITO

- 1. D
- 2. B
- 3. A
- 4. A



SÚMULAS SOBRE DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Súmula 605: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

Súmula 594:

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de crianças e adolescentes independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.

Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Súmula 492: “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.”

Súmula 383: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

Súmula 342: “No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.”

Súmula 338: “A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas.”

Súmula 301: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção *juris tantum* de paternidade.”

Súmula 265: “É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa.”

Súmula 108: “A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz.”

Súmula 01: “O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos.”

